課程名稱：刑法刑法16

00:00:12 - 00:00:12
好，我們接著來看第379頁，過失犯的

00:00:30 - 00:00:32
這邊最後一個小單元，叫做加重結果犯。

00:00:33 - 00:00:36
呃，加重結果犯，它又有翻譯成結果加重犯，一樣的意思。

00:00:37 - 00:00:39
那我習慣是講加重結果犯了，那你們要寫結果加重犯，當然也通。

00:00:41 - 00:00:43
加重結果犯是這樣，其實這個東西我們在很前面講

00:00:44 - 00:00:47
構成要件的時候啊,當時有跟同學講過,我們講說啊,如果立法者他把一個故意的A罪跟過失的B罪,兩罪綁在一起變成一個更重的C罪,這一種立法模式,我們叫做

00:02:00 - 00:02:00
加重結果犯

00:02:00 - 00:02:00
所以我們這邊以最常見的例子傷害致死罪來說

00:02:06 - 00:02:08
傷害致死罪277第二項

00:02:09 - 00:02:13
這個犯罪,如果能把它打回原形的話,它長什麼樣子

00:02:14 - 00:02:16
277第一項的故意傷害

00:02:16 - 00:02:19
加上276的過失致死

00:02:19 - 00:02:21
立法者覺得

00:02:21 - 00:02:25
這兩種犯罪你一起做的話，這個特別可惡，要判得特別重

00:02:26 - 00:02:30
所以立法者呢，就設置了這一種加重結果犯的立法模式

00:02:30 - 00:02:35
所以我們說加重結果犯，它其實就是一種重刑化思考之下的產物

00:02:35 - 00:02:35
因為你要看喔

00:02:36 - 00:02:40
原本行為人他做這種傷害致死的行為

00:02:41 - 00:02:43
行為人毆打被害人，原本只有想教訓他

00:02:44 - 00:02:46
結果不小心打得太重，被害人死掉了

00:02:47 - 00:02:48
原本的話會怎麼處理

00:02:49 - 00:02:52
一行為觸犯傷害罪，觸犯過失致死罪

00:02:53 - 00:02:55
那麼兩者想像競合從重處斷

00:02:55 - 00:02:58
那從重處斷的結果

00:02:58 - 00:02:59
就頂多五年以下嘛

00:02:59 - 00:02:59
他沒有

00:03:00 - 00:03:00
到很重嘛

00:03:01 - 00:03:07
可是如果有加重結果犯的話呢，那個刑度暴增，好像變成什麼無期徒刑還是什麼樣的選項

00:03:07 - 00:03:09
那個刑度會真的非常的重

00:03:09 - 00:03:14
所以我們講加重結果犯，它就是一種重刑化思維之下的產物

00:03:15 - 00:03:16
沒有加重結果犯

00:03:16 - 00:03:18
那原本AB兩罪怎麼做

00:03:18 - 00:03:20
通常就是想像競合嘛

00:03:20 - 00:03:20
對不對

00:03:20 - 00:03:20
當然就想像競合

00:03:21 - 00:03:23
那想像競合從重處斷結果

00:03:23 - 00:03:26
因為立法者還是覺得太輕

00:03:26 - 00:03:29
所以立法者呢，就設置了這一種加重結果犯

00:03:29 - 00:03:30
所以我們來看喔

00:03:30 - 00:03:32
加重結果犯的結構是這樣子

00:03:33 - 00:03:35
故意的基礎行為

00:03:35 - 00:03:36
加上過失的重結果

00:03:36 - 00:03:39
這兩者間具有特殊危險關係

00:03:39 - 00:03:42
而立法者在法有明文的情況之下

00:03:42 - 00:03:43
把它綁成一個罪

00:03:43 - 00:03:45
這就是加重結果犯的結構

00:03:46 - 00:03:49
所以啊，加重結果犯的那個重結果

00:03:49 - 00:03:51
不外乎就是兩種，死亡跟重傷

00:03:51 - 00:03:52
就是這兩種啊

00:03:53 - 00:03:55
傷害致死，傷害致重傷

00:03:55 - 00:03:59
還有像私行拘禁、強盜都有類似的規定

00:03:59 - 00:03:59
這個叫做

00:04:00 - 00:04:01
加重結果犯。

00:04:01 - 00:04:03
那加重結果犯的理由呢？

00:04:03 - 00:04:06
第二點，為什麼會有加重結果犯的設置？

00:04:06 - 00:04:10
當然啦,如果你要講立法者真正的想法的話,

00:04:10 - 00:04:12
他可能就是一種重刑化的思維,

00:04:12 - 00:04:16
那除了重刑化的思維之外呢,比較合理的理由啦,

00:04:16 - 00:04:17
叫做特殊風險,

00:04:17 - 00:04:20
叫做第二點這邊所說的,

00:04:20 - 00:04:22
叫做特殊危險關聯

00:04:22 - 00:04:23
也就是啊

00:04:23 - 00:04:29
通常做這一條罪，很容易導致被害人死亡或重傷的結果

00:04:29 - 00:04:32
所以立法者覺得說呢，這種行為你就是不准做

00:04:32 - 00:04:35
你做的如果也導致死亡或重傷的結果的話

00:04:35 - 00:04:36
那就變得特別可惡,

00:04:36 - 00:04:38
這個叫做特殊危險關係。

00:04:38 - 00:04:41
好，所以這個是我們講加重結果犯它的結構,

00:04:41 - 00:04:46
所以啊，從特殊危險關係跟加重結果犯常態上的結果，我們講兩類對吧?

00:04:46 - 00:04:48
要嘛死亡，要嘛重傷,

00:04:48 - 00:04:50
所以我們可以推導出什麼事？

00:04:51 - 00:04:52
加重結果犯，

00:04:54 - 00:04:56
通常是什麼犯罪會設置？

00:04:57 - 00:05:02
那種經驗上來說，可能會讓被害人死掉或重傷的犯罪，

00:05:02 - 00:05:06
那種犯罪才會有加重結果犯的設置。

00:05:06 - 00:05:06
知道嗎?

00:05:07 - 00:05:11
經驗上來說,可能會導致被害人死掉或重傷的犯罪,

00:05:11 - 00:05:15
那種犯罪基本上它才會有加重結果犯的設置喔。

00:05:15 - 00:05:17
所以我舉例來說,

00:05:18 - 00:05:19
像這種暴力型的犯罪,

00:05:20 - 00:05:24
傷害、重傷、搶奪、強盜、私行拘禁,

00:05:24 - 00:05:27
這種暴力型的犯罪，它就有加重結果犯的設置。

00:05:27 - 00:05:29
還有像是酒駕，

00:05:29 - 00:05:32
酒駕一般不會講那個叫暴力犯罪，

00:05:32 - 00:05:34
但是酒駕把人撞死或撞成重傷。

00:05:34 - 00:05:36
感覺不意外，新聞很常看到。

00:05:36 - 00:05:40
所以酒駕呢，它也會設有加重結果犯的規定。

00:05:40 - 00:05:45
那反過來說啊，這種犯罪如果本質上不會有造成被害人死亡或重傷的結果，

00:05:46 - 00:05:49
那這種犯罪它就不會有加重結果犯的設置。

00:05:49 - 00:05:52
比如說詐欺罪、誹謗罪。

00:05:52 - 00:05:54
這種本質上面有暴力的性質,

00:05:54 - 00:05:58
經驗上來說也不太會讓被害人死亡或重傷的犯罪,

00:05:58 - 00:06:00
它就不會有加重結果犯的設置。

00:06:00 - 00:06:00
所以啊,我們在不確定這一條犯罪有沒有加重結果犯的時候,我們通常會怎麼做啊?

00:06:07 - 00:06:07
很簡單,我們就想一想,這一條犯罪本質上是不是那種容易造成被害人死亡或重傷的犯罪,這個就是一個判斷的基準,當然照這個判斷的話,有一個犯罪是例外,請各位記得放火罪,這很特別。

00:06:25 - 00:06:28
放火罪，照理說他應該要有加重結果犯，對吧？

00:06:28 - 00:06:34
因為放火罪的話，放火去燒人家的房子，不小心把裡面的人燒死，這個不是很容易想像嗎？

00:06:34 - 00:06:35
對，沒有錯。

00:06:35 - 00:06:42
可是立法者卻沒有設置放火致死跟放火致重傷的犯罪，你說為什麼？

00:06:42 - 00:06:43
不知道。

00:06:43 - 00:06:47
對，真的不知道，立法者在放火罪沒有設置加重結果犯，所以這個東西呢，要請同學留意。

00:06:49 - 00:06:51
好，那我們就來看一下要件。

00:06:51 - 00:06:57
加重結果犯的要件呢，首先第一個叫做基礎行為要出於故意，也就是這個A罪要出於故意。

00:06:59 - 00:07:01
A罪出於故意的話，你說是直接故意或間接故意？

00:07:04 - 00:07:05
當然都可以，當然都可以。

00:07:06 - 00:07:09
但不管怎麼樣，基礎行為要出於故意，好。

00:07:12 - 00:07:14
那基礎行為要出於故意的話，我們就會延伸來講一個問題了。

00:07:17 - 00:07:19
這個是加重結果犯，萬年考點。

00:07:20 - 00:07:24
那麼加重結果犯當中，如果行為人的基礎犯罪未遂，可是重結果卻發生了。

備註：萬年考點，加重結果犯當中，如果行為人的基礎犯罪未遂，可是重結果卻發生了。

00:07:29 - 00:07:34
這樣的話還可以論加重結果犯嗎？基礎犯罪未遂，可是重結果卻發生的，比如說。

00:07:39 - 00:07:47
有個歹徒啊，在河堤的這個那個叫什麼？河濱公園那邊，隨機打劫晚上運動的民眾。

00:07:47 - 00:07:51
那這個歹徒就架著一個被害人，威脅給他交出財物。

00:07:52 - 00:07:57
歹徒在勒被害人脖子的時候呢，不小心勒太久，造成被害人窒息而死。

00:07:57 - 00:08:00
結果被害人死後啊，歹徒對那個被害人打劫成功。

00:08:00 - 00:08:08
結果發現這個被害人呢，口袋除了一串鑰匙跟一包面紙之外，連手機都沒有帶，身上沒有任何值錢的財物，歹徒只好敗興而歸。

00:08:09 - 00:08:12
這樣的案例當中很明顯，強盜是未遂，可是強盜罪的被害人呢，他卻死掉了，所以我們會問，基礎犯罪未遂，可是重結果卻發生的情況，還可以論加重結果犯嗎？

00:08:22 - 00:08:24
好，這個問題，有下面三說。

00:08:25 - 00:08:27
第一說是同學你一定要會的。

00:08:28 - 00:08:32
第一說叫做以基礎犯罪有沒有罰未遂來決定。

00:08:32 - 00:08:34
為什麼說這個你一定要會呢？

00:08:34 - 00:08:42
因為這個說法是實務見解，實務的思維非常簡單，基礎犯罪有罰未遂的話，那因為基礎犯罪的未遂是可以成罪的。

00:08:42 - 00:08:48
所以這種情況，這種結果就算實現了，沒關係，還是可以論加重結果犯。

00:08:48 - 00:08:53
好，那反過來，如果基礎犯罪沒有未遂的話呢？

00:08:53 - 00:08:59
那你想，基礎犯罪不罰未遂，而基礎犯罪在未遂的情況之下，重結果卻發生了。

00:09:00 - 00:09:02
這個時候啊，怎麼論加重結果犯？

00:09:02 - 00:09:03
你看黑板吧。

00:09:03 - 00:09:07
我講加重結果犯它是一種A加B等於C的結構。

00:09:07 - 00:09:08
A加B等於C哦。

00:09:09 - 00:09:10
那你想，以傷害罪為例。

00:09:12 - 00:09:13
傷害罪沒有罰未遂。

00:09:14 - 00:09:16
你毆打被害人，然後打了好幾拳都沒有打到。

00:09:17 - 00:09:19
結果被害人自己從頂樓摔下去死掉，大概這種情況。

00:09:21 - 00:09:22
你揮好幾拳啊，他都閃過啊。

00:09:22 - 00:09:24
結果他自己從頂樓摔下去死掉。

00:09:25 - 00:09:28
這樣的情況之下，傷害未遂，重結果卻發生。

00:09:28 - 00:09:30
他可能傷害未遂不罰。

00:09:31 - 00:09:33
對啊，傷害未遂不罰的話，那A罪是無罪的。

00:09:34 - 00:09:36
A罪無罪的話，你必要怎麼等於C？

00:09:36 - 00:09:38
簡單的數學公式嘛。

00:09:38 - 00:09:39
A加B等於C,那結果我今天A不存在。

00:09:39 - 00:09:42
你要怎麼把B等於C,除非A本來就是零,但不是啊,對不對?

00:09:42 - 00:09:47
所以我們講實務的說法就是這樣,看基礎犯罪有沒有罰未遂。

00:09:47 - 00:09:55
基礎犯罪有罰未遂的話,那這個時候基礎犯罪未遂,這種結果發生,可以成立加重結果犯,反之是不行的,這是實務見解。

00:09:59 - 00:09:59
再來呢。

00:10:00 - 00:10:00
而是我們叫做以基礎行為的性質來決定。

00:10:04 - 00:10:05
這個是學界通說。

00:10:06 - 00:10:07
一是實務，二是學界通說。

00:10:09 - 00:10:10
二的話是看什麼的。

00:10:10 - 00:10:16
來，他把加重結果犯分成兩類，行為續生跟結果續生這兩類。

00:10:16 - 00:10:25
這個分類很重要，因為我們等一下再看到那個特殊危險關係的時候，又會用到這個問題，所謂行為續生跟結果續生的犯罪。

00:10:26 - 00:10:27
這一組分類什麼意思呢？

00:10:27 - 00:10:30
來，什麼叫行為續生？什麼叫做結果續生？

00:10:31 - 00:10:32
概念上是這樣。

00:10:33 - 00:10:34
同樣是加重結果犯。

00:10:35 - 00:10:38
有些重結果是來自於A罪的行為。

00:10:39 - 00:10:43
而有些重結果是來自B罪的，來自A罪的結果。

00:10:43 - 00:10:46
這是所謂的行為續生跟結果續生。

00:10:46 - 00:10:49
再講一次喔，同樣是B罪這個加重結果。

00:10:49 - 00:10:52
有些犯罪的重結果是來自A罪的行為。

00:10:52 - 00:10:55
而有些犯罪的重結果是來自於A罪的結果。

00:10:55 - 00:10:59
這是我們所稱的行為續生跟結果續生。

00:10:59 - 00:10:59
好。

00:11:00 - 00:11:02
我舉個例子，來各位搶奪罪。

00:11:03 - 00:11:08
搶奪罪的行為是那個強暴脅迫的暴力行為。

00:11:08 - 00:11:10
應該說威嚇行為的。

00:11:10 - 00:11:13
結果是什麼呢？

00:11:13 - 00:11:13
財產被拿走。

00:11:14 - 00:11:15
瞭解吧？

00:11:15 - 00:11:17
搶盜罪的行為是這個暴力的威嚇行為。

00:11:17 - 00:11:20
強盜罪的結果是被害人的財產被拿走。

00:11:20 - 00:11:24
那你覺得強盜罪的被害人要死掉,通常是因為行為還是因為結果?

00:11:25 - 00:11:26
行為吧,對不對?

00:11:26 - 00:11:29
當然啦,因為暴力威嚇而死,這個叫常見嘛。

00:11:30 - 00:11:32
你說被害人的財產被拿走,然後他就死了。

00:11:33 - 00:11:34
聽起來超怪,對不對?

00:11:34 - 00:11:36
所以強盜罪叫什麼續生?

00:11:36 - 00:11:37
行為續生,OK嗎?

00:11:37 - 00:11:39
強盜罪是一種行為續生。

00:11:39 - 00:11:40
好,那傷害罪呢?

00:11:41 - 00:11:43
傷害罪是行為續生還是結果續生?

00:11:44 - 00:11:46
傳統上傾向認為它是結果續生。

00:11:46 - 00:11:47
結果,為什麼?

00:11:48 - 00:11:50
因為我們講傷害罪的被害人會怎麼死掉?

00:11:50 - 00:11:53
我們常講一句話啊,傷重不治,傷重不治,對不對?

00:11:53 - 00:11:55
所以傷害罪的被害人會怎麼死?

00:11:56 - 00:11:57
傷害的那個結果。

00:11:58 - 00:11:59
傷得很重嘛,那個結果。

00:12:00 - 00:12:02
導致被害人因此死掉,傷重不治嘛,對不對?

00:12:04 - 00:12:08
所以傷害罪是一種什麼呢?結果續生的犯罪,瞭解嗎?傷害罪,它就是一種結果續生的犯罪。

00:12:11 - 00:12:17
所以我們講,那個什麼,那個強盜罪是行為續生,而傷害罪是結果續生。

00:12:18 - 00:12:20
所以呢,為什麼要講這個東西?

00:12:21 - 00:12:29
因為學者說,如果一個加重結果犯是行為續生的話,基礎犯罪的行為本身就可以導致重結果了。

00:12:30 - 00:12:33
所以這個加重結果犯的成立要不要基礎犯罪?

00:12:33 - 00:12:36
不用啊,未遂也可以啊,因為行為就可以導致的嘛,對不對?

00:12:36 - 00:12:42
所以行為續生的加重結果犯,不需要基礎犯罪既遂。

00:12:42 - 00:12:47
可是結果續生的話呢,因為那個重結果是由犯罪的結果所產生的嘛。

00:12:48 - 00:12:51
所以結果續生的加重結果犯呢。

00:12:53 - 00:12:54
結果續生的那一種。

00:12:55 - 00:12:56
要不要基礎犯罪?

00:12:56 - 00:12:56
既遂?

00:12:58 - 00:13:00
結果發現,結果續生當然要。

00:13:00 - 00:13:02
當然要,行為續生的才不用,結果續生的話呢。

00:13:03 - 00:13:05
當然要基礎犯罪有既遂。

00:13:05 - 00:13:07
好，所以這個是第二說，學界的通說。

00:13:08 - 00:13:10
那第三說，這個是一個現在比較少數的說法。

00:13:11 - 00:13:14
說用法條的編排順序來決定。

00:13:15 - 00:13:17
這個是很久以前黃仲金老師提出的看法。

00:13:18 - 00:13:23
因為黃老師說，大部分的加重結果犯，它的立法都是這樣。

00:13:24 - 00:13:30
都是啊，加重結果犯的項次在前，未遂犯的項次在後。

00:13:30 - 00:13:34
所以這一種立法的話呢，因為加重結果犯在前，未遂在後。

00:13:34 - 00:13:40
所以這一種立法來講的話，要成立加重結果犯，就必須這個基礎犯罪有既遂。

00:13:41 - 00:13:42
因為未遂犯在後面嘛。

00:13:42 - 00:13:43
加重結果犯在前面嘛。

00:13:43 - 00:13:46
所以這種的話呢,就必須基礎犯罪有既遂。

00:13:47 - 00:13:50
那反過來說,你看,像性犯罪的加重結果犯。

00:13:50 - 00:13:51
226條第一項。

00:13:52 - 00:13:53
他就沒有這樣子立法啊。

00:13:54 - 00:13:55
他就說,犯221。

00:13:57 - 00:13:59
222的犯罪，他沒有指定第幾項。

00:14:00 - 00:14:00
吧

00:14:00 - 00:14:03
所以這種加重結果犯就不用基礎犯罪既遂。

00:14:04 - 00:14:05
這個是黃榮堅老師的看法。

00:14:05 - 00:14:06
我覺得是說法聽起來超怪。

00:14:07 - 00:14:08
呃，確實喔。

00:14:08 - 00:14:15
我每次告訴我說法都會想說奇怪，立法者在安排加重結果犯的立法模式的時候，應該不會想的那麼深遠。

00:14:15 - 00:14:16
應該不會吧。

00:14:17 - 00:14:19
對啊，我們立委的素質有那麼強嗎？

00:14:19 - 00:14:23
就就用加重結果犯加重結果犯的項次在前喔。

00:14:23 - 00:14:24
未遂犯在後。

00:14:25 - 00:14:26
所以由此可以推論出，

00:14:26 - 00:14:28
這一條罪的加重結果犯的成立，

00:14:28 - 00:14:30
必須要基礎犯罪。

00:14:30 - 00:14:31
所以有既遂？

00:14:31 - 00:14:33
你覺得傅崑萁會問這種問題嗎？

00:14:34 - 00:14:35
應該可以想像吧，對啊，就你覺得傅崑萁會嗎？

00:14:37 - 00:14:38
沈伯洋會啦。

00:14:38 - 00:14:40
我相信，傅崑萁應該不會吧，對啊。

00:14:41 - 00:14:44
我們立法者安排這個項次，他真的有這種深遠的意涵嗎？

00:14:45 - 00:14:47
我相信啦，因為這個是黃榮堅老師的說法。

00:14:48 - 00:14:50
我相信以黃榮堅老師的智慧，他不可能沒有想過這個問題。

00:14:51 - 00:14:56
所以我會覺得黃榮堅老師會主張這個說法的理由其實只有一個，因為他不喜歡加重結果犯。

00:14:56 - 00:14:59
所以他才會想要這個方式，讓加重結果犯變得難成。

00:15:00 - 00:15:01
我個人會這樣啦，可能是這樣。3

00:15:02 - 00:15:04
不然我覺得黃老師是個有智慧的人。

00:15:05 - 00:15:07
他不可能把問題想得那麼膚淺。

00:15:07 - 00:15:08
我覺得應該不會。

00:15:08 - 00:15:12
所以他應該只是用這個方式呢,來加重結果犯變得不容易成立。

00:15:12 - 00:15:13
我個人猜這個啦,可能是這樣。

00:15:14 - 00:15:16
所以這裡的話呢，主要記得的是一跟二。

00:15:16 - 00:15:20
因為三這個說法到黃老師退休之後，比較少人在提，所以主要記得呢，是一跟二。

00:15:23 - 00:15:25
一的話就是看基本犯罪，有沒有法未遂。

00:15:26 - 00:15:29
而二的話呢，看的是所謂行為續生跟結果續生。

00:15:30 - 00:15:30
好。

00:15:30 - 00:15:32
右邊這一題我們來看一下。

00:15:32 - 00:15:33
這一題超難。

00:15:33 - 00:15:34
真的，這一題超難。

00:15:36 - 00:15:38
我寫一下這題怎麼寫。

00:15:38 - 00:15:39
我寫一下它的架構。

00:17:40 - 00:17:41
好，我們看喔，

00:17:42 - 00:17:43
這一題在考的，

00:17:43 - 00:17:45
就是我剛說的問題，

00:17:45 - 00:17:46
基礎犯罪即未遂，

00:17:46 - 00:17:48
可是重結果卻發生。

00:17:48 - 00:17:50
這種題目其實我們以前看過。

00:17:50 - 00:17:52
記不記得我們之前在看結合犯的時候，

00:17:52 - 00:17:53
看到一個題目是，

00:17:54 - 00:17:56
那個行為人有反社會人格的特質，

00:17:56 - 00:17:57
然後他看到有一個老人。

00:17:58 - 00:17:59
他就想去搶那個老人的錢。

00:18:00 - 00:18:00
越獄啊，我們可不可以判他偷囚服？

00:18:00 - 00:18:00
不可以。

00:18:03 - 00:18:04
不然你要他去裸體越獄喔，不可能嘛。

00:18:05 - 00:18:07
從竊盜越獄一定要穿囚服啊，不然呢，所以那個東西就不是所有圖的對象。

00:18:10 - 00:18:13
同樣的,在這種容器物的持有也是喔。

00:18:14 - 00:18:16
我們講說在這種容器物的持有當中,

00:18:17 - 00:18:19
除非行為人對容器也有興趣,

00:18:20 - 00:18:26
否則啊,如果取得容器,就只是一個取得內容物的過程所必要的手段的話,

00:18:27 - 00:18:28
那我們會說呢,

00:18:29 - 00:18:32
行為人的所有圖，僅止於哪一個部分？

00:18:33 - 00:18:36
內容物，而不及於容器，OK嗎？

00:18:36 - 00:18:38
所以我們來看喔，括號一這邊。

00:18:39 - 00:18:42
甲拿走手提包的行為，

00:18:42 - 00:18:46
對手提包的本體會不會論搶奪罪？

00:18:46 - 00:18:50
客觀上是去實現搶奪手提包，主觀上有故意沒有錯。

00:18:50 - 00:18:51
可是他沒有佔有意圖啦。

00:18:52 - 00:18:55
因為他對那個手提包根本沒有興趣，他要的是裡面的錢，知道嗎？

00:18:56 - 00:18:59
所以這個部分，他因為欠缺佔有意圖的關係，所以不成立搶奪罪。

00:19:00 - 00:19:03
那麼甲對想像中的現金呢？

00:19:03 - 00:19:05
這個變搶奪未遂。

00:19:05 - 00:19:06
這個變未遂喔，為什麼？

00:19:07 - 00:19:08
因為客觀上沒有錢啊。

00:19:08 - 00:19:11
但主觀上覺得應該有錢吧。

00:19:11 - 00:19:14
所以這個部分變成搶奪未遂，355第三項。

00:19:14 - 00:19:16
這個變成搶奪未遂，好，所以你看，

00:19:18 - 00:19:19
搶奪未遂，啊結果被害人卻死掉了，

00:19:21 - 00:19:22
是不是回到前面的三說？

00:19:24 - 00:19:24
沒錯，

00:19:24 - 00:19:25
就在考這個東西。

00:19:25 - 00:19:27
來，我們跑一遍看看。

00:19:28 - 00:19:30
這邊如果採實務見解可不可以論？

00:19:31 - 00:19:32
我採實務見解，可以，為什麼？

00:19:33 - 00:19:36
因為採實務的話，搶奪有罰未遂吧，沒有錯啊，對啊，可以啊。

00:19:37 - 00:19:39
那如果採學者的通說呢，區分行為續生跟結果續生。

00:19:42 - 00:19:44
那搶奪是行為還是結果續生？

00:19:44 - 00:19:45
行為嘛，對不對？

00:19:45 - 00:19:47
它是一種行為續生的犯罪，所以當然也可以成立未遂。

00:19:49 - 00:19:50
除非呢，你採黃榮堅老師的看法。

00:19:51 - 00:19:55
因為搶奪罪的話，加重結果犯像是既遂，未遂犯像是債務。

00:19:56 - 00:19:57
所以這個時候，

00:19:57 - 00:19:59
可不可以論加重結果犯？

00:19:59 - 00:20:00
這應該是第二講。

00:20:00 - 00:20:01
才對，不是第三項。

00:20:03 - 00:20:04
如果採黃老師的看法

00:20:04 - 00:20:10
那因為立法技術的關係,所以這種情況沒辦法論加重結果犯,差別在這邊。

00:20:11 - 00:20:15
所以黃老師那說還是要寫啦,因為很多時候一跟二的結論可能會一樣。

00:20:15 - 00:20:18
你要寫這個第三說,才能彰顯出差異,知道嗎?

00:20:19 - 00:20:23
就好像那個不能未遂一樣,不能未遂的客觀危險說只是現在很少人在採。

00:20:24 - 00:20:25
可是你要寫為什麼？

00:20:25 - 00:20:28
因為具體危險說跟重大無知說，大部分案例都會一樣啊。

00:20:28 - 00:20:33
所以你必須要把客觀危險說寫進去，你才能彰顯說，因為這個問題是有意義的，知道吧？

00:20:34 - 00:20:35
好，所以這一題是這樣。

00:20:35 - 00:20:37
那這一題我說它很難啊。

00:20:37 - 00:20:38
我跟各位講

00:20:38 - 00:20:42
如果時間回到十幾年前，我在讀大學的時候

00:20:42 - 00:20:45
假設我在大學的時候，我看到這一題

00:20:46 - 00:20:48
我大學的時候我覺得刑法，我就唸得不錯。

00:20:49 - 00:20:50
真的啦，我大學的時候就很喜歡刑法。

00:20:51 - 00:20:55
所以我覺得我當時大學的時候的刑法水準應該是遠遠超過班上同學的。

00:20:56 - 00:20:58
大學時的如果看到這一題

00:20:59 - 00:21:00
老實說我寫不出這些東西。

00:21:01 - 00:21:03
大學時的我看到這一題

00:21:03 - 00:21:06
我只會覺得說，搶人家的皮包，皮包裡面有沒有東西應該不重要吧。

00:21:07 - 00:21:09
那就搶到皮包，那不是搶奪既遂嗎？

00:21:10 - 00:21:11
然後人死了，就搶奪致死啊，這題我是跑考的。

00:21:12 - 00:21:14
換作是我大學時候，我可能會這樣想。

00:21:15 - 00:21:18
因為我大學時候還不流行討論什麼所有意圖的對象。

00:21:18 - 00:21:19
當時不流行討論這個東西啦。

00:21:20 - 00:21:22
所以當時我可能會覺得說，對啊，就搶奪既遂，還有什麼好說的。

00:21:23 - 00:21:25
然後後來才知道說，原來有這些東西。

00:21:25 - 00:21:25
好，所以這一題

00:21:26 - 00:21:28
它考的有點要轉彎了。

00:21:28 - 00:21:29
基礎犯罪未遂

00:21:30 - 00:21:32
若結果卻發生的,該怎麼論罪?

00:21:32 - 00:21:33
你看身障特考

00:21:34 - 00:21:37
身心障礙的考生好可憐,然後被迫寫那麼難的東西。

00:21:38 - 00:21:39
真的啊,身障通常都考得很難啊。

00:21:42 - 00:21:42
好,所以這個是第一個。

00:21:44 - 00:21:45
再來第二個要件

00:21:45 - 00:21:47
重結果要出於過失。

00:21:48 - 00:21:49
重結果要是過失的哦。

00:21:50 - 00:21:54
曾經有學說重結果不用過失，只要客觀上可預見就夠。

00:21:55 - 00:21:56
但現在不採這說法了。

00:21:57 - 00:21:59
現在我們都說重結果要過失。

00:22:00 - 00:22:00
也就是行為人對重結果要可以成立一個完整的過失犯才算，懂嗎？

00:22:05 - 00:22:08
所以重結果要是過失的吼。

00:22:10 - 00:22:12
所以啊，各位，我舉個例子喔。

00:22:12 - 00:22:14
行為人出於傷害故意毆打被害人。

00:22:15 - 00:22:17
被害人被打之後,

00:22:17 - 00:22:20
他竟然不去就醫。

00:22:21 - 00:22:23
被害人被打之後，內出血喔。

00:22:23 - 00:22:25
他很不舒服喔，他不去看醫生。

00:22:26 - 00:22:29
因為他是那種奇怪的民間信仰的信徒。

00:22:29 - 00:22:32
他相信那個神明護體會保佑他。

00:22:33 - 00:22:36
他就一直在家裡跟那個神明祈求做一些奇怪的法事，然後後來那個人掛了。

00:22:38 - 00:22:40
行為人會不會成立傷害致死罪？

00:22:40 - 00:22:42
不會，因為行為人對那個加重結果沒有過失。

00:22:43 - 00:22:45
那個加重結果叫被害人自我負責，瞭解嗎？

00:22:45 - 00:22:51
所以我們講加重結果要有過失，意思就是那個加重結果要可以成立完整的過失犯，這樣才算。

00:22:52 - 00:22:54
好，所以我們來看到382頁這一題。

00:22:55 - 00:22:57
去年地特法廉的題目。

00:23:54 - 00:23:55
這一題是這樣。

00:23:57 - 00:23:58
這一題是去年的時事。

00:23:58 - 00:24:00
去年九月吧，發生在土城，就是我不知道你們記不記得。

00:24:00 - 00:24:01
不是只有過失而已，

00:24:01 - 00:24:02
他根本是故意，

00:24:02 - 00:24:04
所以這一題變成是妨害公務，

00:24:04 - 00:24:06
跟什麼呢，跟殺人的想像競合。

00:24:07 - 00:24:08
那個叫殺人故意,

00:24:08 - 00:24:09
那個不叫加重結果犯喔,

00:24:10 - 00:24:13
所以這個題目在考驗的是對題目的事實認定喔。

00:24:15 - 00:24:15
好,

00:24:15 - 00:24:16
接下來我們來看到第三點,

00:24:17 - 00:24:23
基礎行為跟加重結果間的特殊危險關係,就是中間這一條線。

00:24:23 - 00:24:26
我們講說啊,要成立加重結果犯的話,

00:24:26 - 00:24:31
必須基礎行為跟加重結果之間存在著特殊的危險關係。

00:24:32 - 00:24:36
所以像比如說殺人罪的被害人,他通常可能是要傷重不治而死,

00:24:36 - 00:24:40
而不能是什麼,被害人拒絕就醫啊或什麼的,不能是這樣子喔。

00:24:40 - 00:24:43
所以這個是我們講特殊危險關係的概念。

00:24:43 - 00:24:46
過去啊,以前在德國發生一個非常奇怪的案例,

00:24:47 - 00:24:50
就是行為人他持那個槍託去毆打被害人,

00:24:50 - 00:24:51
你想像喔,

00:24:51 - 00:24:54
那個人有槍,槍裡有子彈,但他不想浪費子彈,

00:24:54 - 00:24:56
他就拿那個槍，這樣敲被害人的頭，

00:24:56 - 00:24:59
結果敲一敲啊，那槍走火，被害人被子彈打死。

00:24:59 - 00:25:21
超莫名其妙的案例，

00:25:21 - 00:25:42
以前德國真的發生過

00:25:42 - 00:25:46
這一種案例，就是我們講沒有特殊危險關係的情形。

00:25:46 - 00:25:47
你拿槍去敲人家的頭。

00:25:48 - 00:25:51
被害人典型的死亡結果可能是顱內出血而死,

00:25:51 - 00:25:53
結果竟然子彈走火，把人打死。

00:25:54 - 00:25:58
這種情況，就是我們說的，沒有特殊危險關係的情形。

00:25:59 - 00:26:00
還有，像比如說擄人勒贖也有致死的規定。

00:26:00 - 00:26:00
或者比如說歹徒在被勾結的時候，那個人不小心被警察打死，這種情況也不算是特殊危險，也不算。

00:26:10 - 00:26:17
好，所以我們講說呢，特殊危險關係就是說，這個危險要來自於基礎犯罪的典型危險，結果要來自於基礎犯罪的典型危險。

00:26:18 - 00:26:19
好，那接下來有個問題來了。

00:26:20 - 00:26:23
我們要怎麼判斷基礎犯罪的典型危險呢？

00:26:24 - 00:26:28
所以這裡啊，又回到剛剛的問題，所謂行為續生跟結果續生的犯罪。

00:26:29 - 00:26:32
這一條罪的典型危險是什麼？

00:26:32 - 00:26:38
我們還是要回歸加重結果犯的本質，就是我們要去看呢，這一條罪是一個行為續生或結果續生的犯罪。

00:26:38 - 00:26:42
進而可以推論出那這一條罪的典型危險是什麼東西。

00:26:43 - 00:26:44
像比如說啊。

00:26:45 - 00:26:48
（二）這邊，我們直接來看下面這個情節問題。

00:26:49 - 00:26:51
我們要怎麼判斷各罪的典型危險？

00:26:52 - 00:26:58
或者是說各罪的典型危險，推導出的特殊危險關係，可以排除掉什麼樣的案例呢？

00:26:59 - 00:27:01
好，我們以這個強盜為例。

00:27:02 - 00:27:05
剛剛我們說強盜造成什麼危險，行為危險，對不對？

00:27:06 - 00:27:14
所以我們可以由此推論，強盜罪被害人死亡的重結果，要來自於什麼呢？強暴脅迫的取財行為，這才可以喔。

00:27:16 - 00:27:20
強盜罪的典型危險，不能來自於被害人的財產被拿走喔。

00:27:21 - 00:27:23
你說，被害人財產被拿走會死掉嗎？

00:27:23 - 00:27:24
有啊，有可能啊。

00:27:25 - 00:27:27
你搶奪被害人的後揹包。

00:27:27 - 00:27:29
結果被害人有氣喘病。

00:27:30 - 00:27:34
一小時後被害人氣喘病發作了，他後背包被搶走，他沒有藥物，所以他人死掉了。

00:27:35 - 00:27:36
不是不可能嘛。

00:27:37 - 00:27:40
但是因為我們講，強盜罪是一個行為危險的犯罪。

00:27:41 - 00:27:45
而這個案例當中，被害人的死亡結果，確實來自於強盜的結果。

00:27:45 - 00:27:47
所以這個就叫做不符合特殊危險關係，不符合特殊危險關係。

00:27:50 - 00:27:51
好像強盜罪是這樣子。

00:27:53 - 00:27:54
再來我們翻過來。

00:27:55 - 00:27:56
384頁。

00:27:56 - 00:27:58
私行拘禁罪，來，那私行拘禁的典型危險是什麼？

00:28:03 - 00:28:05
我們想啊，我們人能活在這個世界上，一切的生存其實都是仰賴外界的補給。

00:28:10 - 00:28:15
真的啊，我們每天要喝水，水你怎麼無中生有？水是自然水公司提供的嘛。

00:28:16 - 00:28:18
你要吃東西，要食物，食物怎麼來的？

00:28:19 - 00:28:21
你不可能叫你種菜又養豬嘛。

00:28:21 - 00:28:24
所以食物怎麼來的，你要跟人家買食材啊，對不對？

00:28:24 - 00:28:27
所以我們生活的一切都仰賴於外界的補給。

00:28:27 - 00:28:32
進而，一個人被私行拘禁，關在特定的小房間當中。

00:28:32 - 00:28:34
對他產生的風險是什麼？

00:28:34 - 00:28:36
斷絕生存的補給而死掉，對，沒有錯。

00:28:37 - 00:28:39
所以私行拘禁的典型危險就是，被害人跟外界的聯絡被阻斷之後，

00:28:42 - 00:28:46
被害人會因為喪失生存的補給而死，所以喪失飲食、飲水，

00:28:49 - 00:28:50
或者是喪失藥物而死。

00:28:51 - 00:28:54
這都是私行拘禁的典型危險。

00:28:54 - 00:28:56
好，除了這一點之外，還有一個東西喔。

00:28:58 - 00:29:00
那被害人被拘禁之後,

00:29:00 - 00:29:05
是不是也有可能，會想逃跑而死掉？對，沒有錯。

00:29:06 - 00:29:09
所以會想逃跑，這也是被囚禁的人的本能。

00:29:10 - 00:29:17
那也影響，如果被囚禁的人，他被拘禁之後，他想試圖逃跑。

00:29:18 - 00:29:20
逃跑的過程當中不慎摔死。

00:29:21 - 00:29:22
這也是典型危險，知道嗎？

00:29:22 - 00:29:23
這個也算。

00:29:24 - 00:29:27
來，那個住29號，我們看一下黃惠婷老師的說法。

00:29:28 - 00:29:30
黃老師卻也認為說，對

00:29:30 - 00:29:30
沒有錯。

00:29:30 - 00:29:35
被害人被囚禁之後，因為逃跑的過程而生的死亡結果。

00:29:35 - 00:29:38
對，這個東西確實是典型危險。

00:29:39 - 00:29:42
除非啦，被害人用顯然不理智的方式逃跑。

00:29:43 - 00:29:44
比如說，

00:29:44 - 00:29:48
他從14層樓的高樓，要跳樓逃生。

00:29:49 - 00:29:54
他拿了一把小陽傘，他覺得他那個小陽傘可以充當降落傘，這種。

00:29:55 - 00:29:56
這個就是顯然不理智的方式。

00:29:56 - 00:29:59
或者他覺得他是蜘蛛人，他可以不需要任何的工具，

00:30:00 - 00:30:02
就攀爬外牆而逃生，除非是採用這種顯然不理智的方式去逃。

00:30:05 - 00:30:13
否則啊，被害人在逃跑過程當中，所受的結果，那也是私行拘禁的典型危險哦，這也算哦。

00:30:14 - 00:30:17
好，那再來，交通危險的犯罪。

00:30:18 - 00:30:19
我們講喔。

00:30:19 - 00:30:21
交通危險的犯罪。

00:30:22 - 00:30:24
牠也是什麼呢？

00:30:24 - 00:30:24
怎麼講啊？

00:30:25 - 00:30:28
他也有加重危險犯，也有加重結果犯。

00:30:28 - 00:30:35
那這個加重結果啊，也必須要是來自於交通行為的典型危險，這個才算喔。

00:30:36 - 00:30:43
當然啦，交通危險犯，要產生加重結果，然後又不具有特殊因果關係，這一種案例可能比較難想像。

00:30:43 - 00:30:46
我們把重點放在括號四的傷害罪。

00:30:46 - 00:30:51
因為考試考特殊因果關係，最喜歡考的就是款號四那個傷害罪。

00:30:52 - 00:30:57
各位，傷害罪是哪一種危險，行為危險、行為續生還是結果續生？

00:30:58 - 00:31:01
行為續生結果續生又叫做

00:31:01 - 00:31:02
行為危險

00:31:02 - 00:31:02
結果危險。

00:31:03 - 00:31:04
一樣的意思。

00:31:04 - 00:31:05
早期黃老師是翻

00:31:05 - 00:31:05
行為危險

00:31:05 - 00:31:07
跟結果危險，然後後來許多人當老師是翻

00:31:07 - 00:31:07
行為續生

00:31:07 - 00:31:09
跟結果續生，好不管。

00:31:09 - 00:31:13
傷害罪是行為續生還是結果續生的犯罪？

00:31:14 - 00:31:15
我們傳統都講結果續生，對不對？

00:31:16 - 00:31:17
可是其實你知道嗎？

00:31:17 - 00:31:19
也有人說傷害罪兩個都有。

00:31:19 - 00:31:22
他既是行為續生，也是結果續生。

00:31:22 - 00:31:23
有喔，有這個說法喔。

00:31:23 - 00:31:26
因為有學者會說，其實傷害罪是這樣。

00:31:27 - 00:31:29
傷害罪對，它是結果續生沒有人反對。

00:31:29 - 00:31:34
可是有人會說沒有啊，傷害罪其實也有行為續生的成分。

00:31:34 - 00:31:35
也有喔，為什麼？

00:31:37 - 00:31:39
因為有人會說，我們以傷害罪為例。

00:31:41 - 00:31:44
傷害，被害人傷重不治而死，對，這個是符合我們一般的經驗。

00:31:46 - 00:31:47
可是你要想喔，

00:31:48 - 00:31:51
人被打之後，不是每個人都會乖乖被打嗎？

00:31:52 - 00:31:55
人被打之後，很容易產生這個二擇一的反應嗎？

00:31:56 - 00:31:57
要麼打回去嘛，要麼逃跑嘛，對不對？

00:31:59 - 00:32:00
所以另外一種理論

00:32:00 - 00:32:00
觀點是

00:32:01 - 00:32:09
被害人在被毆打之後，他如果是在反抗或脫逃的過程當中，所生的死亡結果

00:32:10 - 00:32:12
那也是傷害罪的典型危險

00:32:12 - 00:32:13
合理，對吧

00:32:13 - 00:32:16
人被打，被害人被打，會想逃，會想反擊，一樣很正常啊

00:32:17 - 00:32:19
所以逃跑或反擊當中所生的死亡結果呢

00:32:19 - 00:32:22
這也是傷害罪的典型危險

00:32:23 - 00:32:28
所以傳統上固然認為傷害罪是一種結果續生的犯罪

00:32:28 - 00:32:35
可是也有新學說說沒有啦，傷害罪點可以都有，既是行為續生，又是結果續生

00:32:36 - 00:32:38
這個用語，我括號有寫

00:32:39 - 00:32:41
最早這個問題是出現在王皇玉老師的文章

00:32:41 - 00:32:47
王皇玉老師把那個傷害罪是結果續生的觀點，叫做狹義說

00:32:48 - 00:32:52
那認為傷害罪既是行為續生，也是結果續設的觀點

00:32:53 - 00:32:55
我們叫它廣義說

00:32:55 - 00:32:55
知道嗎

00:32:55 - 00:32:56
有這兩說

00:32:56 - 00:33:00
那請各位記得，狹義說、廣義說只能用在傷害罪

00:33:01 - 00:33:02
你

00:33:02 - 00:33:03
不要把它拿去別的犯罪

00:33:03 - 00:33:05
比如說私行拘禁，沒有喔

00:33:05 - 00:33:07
私行拘禁他本來就

00:33:08 - 00:33:10
可以包含被害人逃跑當中的死亡結果

00:33:11 - 00:33:11
那本來就可以的，知道嗎

00:33:12 - 00:33:16
我們探討這個問題，狹義廣義說，這是傷害罪自己的問題喔

00:33:16 - 00:33:18
你不要把它拿去用在別的地方，知道吧？

00:33:18 - 00:33:19
這個請各位小心喔。

00:33:22 - 00:33:23
我們來看一個題目。

00:33:24 - 00:33:25
這一題我們以前看過啊，那個...

00:33:25 - 00:33:27
賣西瓜那一題。

00:33:33 - 00:33:36
這一題我們應該是放在犯罪參與這邊吧

00:33:36 - 00:33:37
107那一題啊，那個

00:33:39 - 00:33:41
29頁44題

00:34:34 - 00:34:38
這一題當中啊，我上禮拜其實有大略提到，我當時怎麼說的還記得嗎？

00:34:39 - 00:34:41
我說啊,被害人怎麼死的啊?

00:34:42 - 00:34:44
顱內出血而死,對不對?

00:34:44 - 00:34:46
可是被害人當初是哪受傷啊?

00:34:47 - 00:34:48
手部受傷。

00:34:48 - 00:34:52
他用手去擋西瓜刀,他的手被刀子砍傷,結果他倒地之後頭部撞擊地面,顱內出血而死。

00:34:56 - 00:34:58
有沒有感覺超不尋常的？

00:34:59 - 00:35:00
也不能說超不尋常啦。

00:35:00 - 00:35:05
應該說就是被害人受傷的部位，跟他死亡的結果根本是兩個不同的東西嘛，對不對？

00:35:06 - 00:35:09
所以這一題當中，可不可以成立傷害致死？

00:35:09 - 00:35:12
那就是我們前面說行為續生跟結果續生的觀點。

00:35:13 - 00:35:17
如果我們認為說傷害致死，所以是一種結果續生的犯罪。

00:35:19 - 00:35:22
那這個死亡結果很顯然不是來自於這個傷害結果啊，對不對？

00:35:23 - 00:35:25
所以不能這樣起訴法辦。

00:35:25 - 00:35:27
但如果我們在廣義說呢？

00:35:27 - 00:35:30
可以啊，反抗的過程、逃跑的過程所生的死亡結果都算。

00:35:30 - 00:35:31
都算嘛，對不對？

00:35:31 - 00:35:31
所以是可以的。

00:35:32 - 00:35:33
OK，所以我們回到課本。

00:35:33 - 00:35:37
課本上面那個傷害罪的狹義說。

00:35:38 - 00:35:41
狹義說，你可以寫一下，就是限於傷重不治才算。

00:35:42 - 00:35:43
簡單講這個意思，知道嗎？

00:35:43 - 00:35:49
狹義說，我們以這個傷害致死來講的話，就是要限傷重不致死才算。

00:35:50 - 00:35:54
那廣義說的話呢，傷重不致死，固然算。

00:35:54 - 00:35:56
然後再加上什麼？

00:35:56 - 00:35:59
逃跑或反抗的過程所生的死亡結果，知道嗎？

00:36:00 - 00:36:06
一個認為要傷重不致死才算，另外一個說呢，逃跑或反擊的過程所受的總結果，通通都算，好，所以這個是兩說不同的看法。

00:36:30 - 00:36:32
接下來386頁。

00:36:32 - 00:36:34
那個最難的特殊關係我們看完了。

00:36:34 - 00:36:35
剩下兩個就簡單。

00:36:36 - 00:36:41
386頁第四點這個問題，加重結果的被害人。

00:36:41 - 00:36:45
你看哦,一般的加重結果犯,A、B兩式的被害人是同一個人嗎?

00:36:46 - 00:36:49
行為人毆打甲,然後甲後來死掉,對不對?

00:36:49 - 00:36:50
通常都是這樣子嗎?

00:36:50 - 00:36:52
行為人搶到甲,然後後來甲死掉。

00:36:52 - 00:36:54
這個是最常見的情況。

00:36:54 - 00:36:59
那有一種情況是說，行為人對甲搶匪，行為人毆打甲搶匪，結果死掉的人竟然是乙。

00:37:00 - 00:37:03
這樣的情況還可以成立加重結果犯嗎？

00:37:03 - 00:37:05
好，這個跟法條的規定有關。

00:37:05 - 00:37:09
你看喔，一般的加重結果犯，他只有講致死或致重傷。

00:37:09 - 00:37:12
他沒有說要誰死或誰重傷，沒有。

00:37:12 - 00:37:18
所以那種一般的加重結果犯，死亡或重傷的人，可不可以是第三人？

00:37:18 - 00:37:19
可以。

00:37:19 - 00:37:22
知道嗎？確實可以，但如果是特別的呢？

00:37:23 - 00:37:26
比如說像性犯罪，又來的226，第一項。

00:37:29 - 00:37:32
性犯罪的加重結果犯。

00:37:32 - 00:37:34
他有寫要致死於死，致死於重傷。

00:37:34 - 00:37:35
有啊，被害人啊，對不對？

00:37:36 - 00:37:39
所以性犯罪的加重結果犯。

00:37:39 - 00:37:44
他的基礎犯罪跟重結果的被害人，就必須要是同一個人喔。

00:37:44 - 00:37:46
如果是不同一個人的話。

00:37:46 - 00:37:48
沒辦法論加重結果犯。

00:37:48 - 00:37:50
大家好，這個是性犯罪的部分。

00:37:50 - 00:37:51
好。

00:37:51 - 00:37:57
那反過來我剛剛說，因為一般的加重結果犯，他並沒有特別講說，要不要是同一個人。

00:37:57 - 00:37:59
所以不同人的情況。

00:38:00 - 00:38:03
A罪的被害人是甲，B罪的被害人是乙，這種不同人的情況，我們不會以此否定加重結果犯的成立是沒有錯。

00:38:09 - 00:38:15
可是在A罪跟B罪的被害人是不同的情況之下，能不能符合加重結果犯的其他要件。

00:38:16 - 00:38:17
那是另外一個問題喔，瞭解吧。

00:38:18 - 00:38:22
我們不會因為兩罪的被害人不一樣，就否定加重結果犯的成立。

00:38:22 - 00:38:29
可是這種兩罪的被害人是不同人的情形，很多時候根本沒有辦法滿足加重結果犯的其他要件。

00:38:30 - 00:38:31
我說明一下吧，我舉個例子。

00:38:32 - 00:38:34
行為人去毆打A。

00:38:35 - 00:38:40
結果他的女朋友在旁邊看到啊，嚇死了，最後心臟麻痺死掉。

00:38:41 - 00:38:42
是怎麼論傷害致死？

00:38:42 - 00:38:43
不可能有過失，對不對？

00:38:43 - 00:38:44
所以這種情況不可能論。

00:38:45 - 00:38:47
當然被害人是第三人情況。

00:38:47 - 00:38:48
也不見得永遠不可能論啊。

00:38:50 - 00:38:52
你看我下面這個括號二。

00:38:53 - 00:38:55
假車禍真搶盜的案例，你看。

00:38:55 - 00:39:00
汽車駕駛甲,見機車騎士乙的坐墊上,放著好幾萬塊錢。

00:39:00 - 00:39:01
因為大衝。

00:39:01 - 00:39:03
甲故意擦撞乙的機車。

00:39:03 - 00:39:06
把乙撞倒之後,趁機拿走現金。

00:39:06 - 00:39:07
這就是強盜啊,不用懷疑啊。

00:39:08 - 00:39:10
強暴致使不能抗拒取得他人之物嗎？

00:39:10 - 00:39:11
結果。

00:39:11 - 00:39:13
那個機車騎士胸前背著一個嬰兒。

00:39:14 - 00:39:17
被撞倒之後，嬰兒頭部著地，嬰兒死掉了。

00:39:17 - 00:39:19
這一種情況，可不可以講到致死？

00:39:20 - 00:39:21
他強盜騎士，結果騎士胸前的嬰兒死掉了。

00:39:24 - 00:39:25
有沒有說關係，這個是有的喔，知道吧。

00:39:26 - 00:39:31
所以我們講，加重結果的被害人是第三人的情形，我們不會單純因為人不同，就否定加重結果犯的成立。

00:39:36 - 00:39:41
只是這種情況，要論加重結果犯，你還是要看別的要件能不能符合，知道吧。

00:39:41 - 00:39:43
因為這種情況其實蠻罕見的啦。

00:39:45 - 00:39:46
那至於我們包括其他參與犯。

00:39:47 - 00:39:48
這個去年43有考。

00:39:49 - 00:39:50
對，去年43就考這個東西。

00:39:50 - 00:39:54
在考說，加重結果犯的被害人

00:39:55 - 00:39:58
有沒有包括其他的參與者，尤其是共同正犯。

00:39:59 - 00:40:00
這是黃惠庭老師。

00:40:00 - 00:40:01
這是10年前的文章啦。

00:40:01 - 00:40:03
去年那一份再考的沒錯，

00:40:03 - 00:40:04
就是黃老師的考點。

00:40:05 - 00:40:06
當然是不是他出的我不知道。

00:40:06 - 00:40:07
但我很確定，

00:40:08 - 00:40:10
這就是黃老師文章特有的考點。

00:40:13 - 00:40:14
加重結果的被害人，

00:40:14 - 00:40:16
如果是同夥可不可以？

00:40:17 - 00:40:18
我舉一個例子是這樣。

00:40:19 - 00:40:22
多人在路上聚眾飆車,

00:40:22 - 00:40:23
他們把公路當賽道,

00:40:24 - 00:40:25
在路上聚眾飆車,

00:40:25 - 00:40:26
這裡涉及什麼行為呢?

00:40:26 - 00:40:27
叫刑法185,

00:40:28 - 00:40:29
妨害公眾往來安全罪

00:40:29 - 00:40:31
多人在路上聚眾飆車

00:40:31 - 00:40:34
結果這一群在路上聚眾飆車的人啊

00:40:35 - 00:40:37
他們其中同夥一個人出了車禍

00:40:38 - 00:40:40
出車禍之後那個人被拋飛車外

00:40:40 - 00:40:41
然後卵蛋爆掉

00:40:41 - 00:40:42
簡單講是這樣哈

00:40:42 - 00:40:44
我請你等下警訊筆錄不要這樣出啊

00:40:44 - 00:40:46
出到那個飆車飆到卵蛋都沒了

00:40:46 - 00:40:47
來各位

00:40:48 - 00:40:49
這樣的案例當中,

00:40:49 - 00:40:53
那個那個那個懶覺爆掉的人啊,

00:40:53 - 00:40:54
他受重傷嘛,

00:40:55 - 00:40:58
那其他的同夥要不要對185的加重結果犯?

00:41:00 - 00:41:04
要不要論那個妨害公眾往來致重傷的加重結果犯?

00:41:05 - 00:41:05
誰重傷？

00:41:05 - 00:41:06
他同夥重傷啊，

00:41:06 - 00:41:06
對不對？

00:41:07 - 00:41:08
學者跟實務都認為說不論，

00:41:09 - 00:41:09
不論。

00:41:09 - 00:41:10
為什麼？

00:41:10 - 00:41:11
因為第一個，

00:41:11 - 00:41:17
如果你說加重結果犯的被害人包括同夥的參與者的話，

00:41:17 - 00:41:17
嘿，

00:41:18 - 00:41:19
那那個懶覺爆掉的人，

00:41:20 - 00:41:20
他也是共犯,

00:41:20 - 00:41:21
他也是共同正犯,

00:41:22 - 00:41:24
那他是不是要為自己的懶覺爆掉,

00:41:24 - 00:41:25
也成立加重結果犯?

00:41:26 - 00:41:26
超怪,

00:41:26 - 00:41:26
對吧？

00:41:27 - 00:41:28
自己的懶覺沒了,

00:41:28 - 00:41:29
然後還要因此而加重,

00:41:29 - 00:41:29
變加重結果犯,

00:41:30 - 00:41:30
超荒謬。

00:41:30 - 00:41:30
對不對？

00:41:31 - 00:41:31
這是第一個問題。

00:41:31 - 00:41:32
對啊。

00:41:32 - 00:41:34
所以當然不包括啊。

00:41:34 - 00:41:35
因為這樣交互規則的結果。

00:41:36 - 00:41:39
可能會讓行為人要為自己的重傷也一起論罪也,

00:41:39 - 00:41:40
超怪嘛,

00:41:40 - 00:41:41
再來第二個問題是,

00:41:43 - 00:41:43
既然他是同夥,

00:41:44 - 00:41:45
他一起做這個事,

00:41:46 - 00:41:47
那就應該講被害人自我負責啊,

00:41:48 - 00:41:48
對不對?

00:41:49 - 00:41:50
一起去飆車,

00:41:50 - 00:41:51
那這個懶覺爆掉的人,

00:41:51 - 00:41:53
他應該也自己要承擔這個危險啊,

00:41:53 - 00:41:55
所以我們基於被害人自我負責原則呢,

00:41:55 - 00:41:56
會認為說,

00:41:56 - 00:41:59
其他的同夥對於這個重傷的人呢,

00:42:00 - 00:42:01
根本不會有過失,

00:42:01 - 00:42:03
被害人自我負責。

00:42:03 - 00:42:04
阻卻客觀可責性,

00:42:04 - 00:42:05
瞭解喔。

00:42:05 - 00:42:06
所以學說上來說呢,

00:42:06 - 00:42:08
加重結果犯的被害人,

00:42:08 - 00:42:11
不包括同夥的參與者,

00:42:11 - 00:42:12
不包括。

00:42:13 - 00:42:14
好,

00:42:14 - 00:42:16
最後啊，法律要有加重其刑的明文,

00:42:16 - 00:42:17
就像我剛剛說的,

00:42:18 - 00:42:20
這個加重結果犯啊,

00:42:20 - 00:42:21
有沒有通常很好判斷，

00:42:22 - 00:42:26
通常就是你看這個犯罪本質上會不會有讓被害人死亡或重傷的風險。

00:42:27 - 00:42:28
那各位啊，

00:42:28 - 00:42:30
如果法律沒有加重其刑的明文，

00:42:30 - 00:42:31
怎麼辦？

00:42:31 - 00:42:31
好,

00:42:31 - 00:42:32
很簡單,

00:42:32 - 00:42:33
那因為沒有加重結果犯嘛,

00:42:34 - 00:42:35
所以我們就怎麼樣?

00:42:35 - 00:42:38
回歸55條的想像競合去處理

00:42:38 - 00:42:39
就是這樣子喔。

00:42:40 - 00:42:41
所以我們講喔,

00:42:41 - 00:42:42
放火罪沒有加重結果犯,

00:42:43 - 00:42:45
想像上來說,

00:42:45 - 00:42:47
確實有可能放火致死,

00:42:47 - 00:42:48
比如說你想，

00:42:49 - 00:42:52
行為人要放火去燒被害人的透天，

00:42:52 - 00:42:53
洩恨。

00:42:54 - 00:42:56
那這個行為人他在放火前，

00:42:56 - 00:42:57
他挑的是晚上。

00:42:57 - 00:42:58
他有特別看

00:42:58 - 00:43:26
人家家裡的燈

00:43:26 - 00:43:40
是暗的

00:43:40 - 00:43:41
應該沒有人在家

00:43:41 - 00:43:43
所以他就放火去燒這棟透天。

00:43:43 - 00:43:44
結果

00:43:44 - 00:43:45
火勢引燃之後，

00:43:45 - 00:43:46
竟然呢，

00:43:47 - 00:43:49
被害的小孩被燒死。

00:43:50 - 00:43:50
原來啊，

00:43:50 - 00:43:51
當時晚上七點多，

00:43:52 - 00:43:53
全家人外出吃飯,

00:43:53 - 00:43:55
那小孩說他身體不舒服,

00:43:55 - 00:43:56
說他想自己在家睡覺。

00:43:57 - 00:43:57
所以燈是關著的,

00:43:58 - 00:43:59
結果小孩就被燒死了。

00:44:16 - 00:44:21
第二項，這個條文叫做妨害性自主致被害人羞憤自殺。

00:44:22 - 00:44:25
我們要問的是這個條文，它是加重結果犯嗎？

00:44:25 - 00:44:29
第二項，妨害性自主致被害人羞憤自殺。

00:44:31 - 00:44:36
先跟同學講結論，通說跟實務都說他不是加重結果犯。

00:44:36 - 00:44:37
當然不是。

00:44:37 - 00:44:42
為什麼，因為這條罪，如果你用加重結果犯的結構去看它的話，這一條罪不可能會成立。

00:44:43 - 00:44:44
對啊，當然不可能啊。

00:44:44 - 00:44:48
因為在法律上的說法，自殺叫被害人的選擇。

00:44:49 - 00:44:54
那既然自殺是被害人的選擇的話，那個在法律上就叫做什麼呢，被害人自我負責。

00:44:55 - 00:44:57
行為人不可能對這個結果有過失。

00:44:57 - 00:44:57
知道吧,不可能。

00:44:58 - 00:44:59
所以這一條罪,

00:45:00 - 00:45:06
226條第二項,如果你要從加重結果犯的邏輯去思考的話,這一條沒有意義,它不可能會成立,知道嗎?

00:45:07 - 00:45:11
所以從立法意思來講,這一條罪當然不是加重結果犯。

00:45:12 - 00:45:14
他叫什麼呢,特殊結果責任。

00:45:15 - 00:45:19
也就是對被害人死亡的重結果，行為人不用有故意，也不用有過失。

00:45:20 - 00:45:22
只要中間有條件因果關係，那就夠了。

00:45:23 - 00:45:24
這是通說實務的理解。

00:45:25 - 00:45:28
只要行為人對這個被害人自殺的加重結果，

00:45:29 - 00:45:33
呃，客觀上有因果關係的存在，也就是實務說的。

00:45:33 - 00:45:40
只要能證明被害人的自殺是源自於行為人的性侵，而不是其他原因。

00:45:41 - 00:45:42
這就夠了，知道嗎，這個夠了。

00:45:42 - 00:45:43
好，最後舉個例子。

00:45:45 - 00:45:46
假設，

00:45:46 - 00:45:47
陸伯言。

00:45:48 - 00:45:50
他在十年前念大學的時候,

00:45:51 - 00:45:53
十年前，十年前他畢業了，好不確定，十幾年前。

00:45:55 - 00:45:59
假設陸伯言他在十幾年前念大學的時候啊，性侵他們班的女同學。

00:46:00 - 00:46:04
好，性侵完之後啊，這個女生因此而罹患憂鬱症。

00:46:04 - 00:46:09
經常要去精神科求診，也有跟這個心理師談話。

00:46:09 - 00:46:10
後來呢

00:46:11 - 00:46:13
這個十年來啊，

00:46:13 - 00:46:17
這個女生一直處於精神崩潰的邊緣，

00:46:17 - 00:46:19
一直吃精神科的藥，

00:46:19 - 00:46:21
心理狀態一直不是很好。

00:46:22 - 00:46:24
十年後的某一天，這個女生自殺了。

00:46:25 - 00:46:30
那從諮商心理師，還有從精神科醫師的談話記錄來看。

00:46:30 - 00:46:33
那我們都可以確定，這個女生會自殺，沒有別的原因。

00:46:34 - 00:46:39
他跟家人沒有失和，他也沒有面臨財務困境，他也沒有面臨感情困擾什麼的都沒有，他會自殺，很確定。

00:46:41 - 00:46:44
就是來自於十年前的那件性侵案。

00:46:45 - 00:46:47
那陸伯言要不要對226條？

00:46:47 - 00:46:48
要。

00:46:48 - 00:46:49
對，要，因為有關。

00:46:50 - 00:46:50
對,沒錯,就是這樣。

00:46:51 - 00:46:52
這就是這條罪立法者的思考。

00:46:53 - 00:46:57
所以這一條罪的戰場不在解釋論,在立法院。

00:46:57 - 00:47:00
十個學者有九個都會說這條要刪掉。

00:47:01 - 00:47:04
剩下一個沒有表態的,也不會支持這條罪。

00:47:04 - 00:47:05
就只是單純沒有興趣，就這樣而已。

00:47:06 - 00:47:09
如果你真的問這個沒有表態的學者說你支持這條罪嗎？

00:47:09 - 00:47:11
我想學者也會說，就是不支持啦。

00:47:11 - 00:47:12
這個犯罪不好啦。

00:47:13 - 00:47:14
好，為什麼這個犯罪不好？

00:47:15 - 00:47:16
因為第一個

00:47:16 - 00:47:19
我們說好的，民法有沒有無過失責任啊?

00:47:21 - 00:47:22
同學問我一件事。

00:47:22 - 00:47:25
民事的損害賠償責任有無過失責任，但刑事沒有，為什麼？

00:47:27 - 00:47:28
好，我們講一下啊。

00:47:30 - 00:47:32
至少我以前學的民法是這樣說的。

00:47:32 - 00:47:35
就是為什麼民事的侵權行為會有無過失責任？

00:47:37 - 00:47:40
因為那些被課與無過失責任的侵權行為者，

00:47:41 - 00:47:45
往往是一些什麼企業經營者之類，那個經濟上比較強勢的人。

00:47:45 - 00:47:47
那民法上的思維是說，

00:47:47 - 00:47:50
那你們是作為企業經營者，

00:47:50 - 00:47:53
被你們傷害的可能是消費者，經濟相對弱勢。

00:47:54 - 00:47:57
那你們可以透過這個責任保險來分攤你們的風險嘛。

00:47:58 - 00:47:59
所以民事上可以無過失責任。

00:48:00 - 00:48:01
背後是有這樣的想法。

00:48:02 - 00:48:03
那反過來。

00:48:04 - 00:48:06
為什麼刑法不會有無過失責任？

00:48:07 - 00:48:11
因為刑法的目的不是為了，不是為了補償被害人嘛。

00:48:11 - 00:48:14
在刑法上，如果有無過失責任。

00:48:14 - 00:48:16
這對犯罪預防沒有任何的好處。

00:48:17 - 00:48:20
假設刑法上無過失責任的話,那個叫純粹的報復。

00:48:21 - 00:48:23
這件事跟你有關,所以我要抓你去關,我看你不爽,就是這樣。

00:48:24 - 00:48:29
那我們是不是說過,從現代的刑法思想來講,報復不是刑法的功能啊。

00:48:30 - 00:48:32
報復那個是人的一種很野蠻的形態。

00:48:32 - 00:48:34
我們不會說刑法有這樣的功能,不會。

00:48:34 - 00:48:36
所以為什麼刑法沒有過失責任？

00:48:37 - 00:48:41
因為要一個人對無可預見的犯罪結果負擔刑事責任，

00:48:42 - 00:48:45
這對犯罪預防來說，沒有任何的意義。

00:48:45 - 00:48:47
這就是純粹的報復，理解吧？

00:48:47 - 00:48:49
所以我們從刑法的觀點來講。

00:48:50 - 00:48:52
第二項這個條文。

00:48:52 - 00:48:57
他會違反行為非出於故意或過失不法的原則。

00:48:58 - 00:49:01
這一條本質上根本是無過失責任的。

00:49:01 - 00:49:02
有沒有想過？

00:49:02 - 00:49:04
所以沒錯，這一條本質上根本是無過失責任。

00:49:04 - 00:49:06
所以這一條甚至有危險的疑慮。

00:49:07 - 00:49:09
可是你現在說他危險也沒用啊。

00:49:09 - 00:49:11
因為憲法法庭被藍白癱瘓了。

00:49:11 - 00:49:13
對啊，所以你能怎麼說，對啊。

00:49:13 - 00:49:15
但至少學理上認為說他是危險的。

00:49:16 - 00:49:16
好。

00:49:17 - 00:49:19
除了刑法本身的理由之外。

00:49:20 - 00:49:21
第二個。

00:49:21 - 00:49:23
我們要從刑法來談這一條罪背後的問題。

00:49:25 - 00:49:28
除了刑法本身的問題之外，這一條罪背後的價值觀也有問題。

00:49:29 - 00:49:30
怎麼說？

00:49:31 - 00:49:32
來，我們想像一個社會。

00:49:34 - 00:49:36
我跟你們講，這一條背後就是一種貞操思想。

00:49:37 - 00:49:38
真的，他就是貞操思想。

00:49:40 - 00:49:41
我常講，我們想像一個社會。

00:49:42 - 00:49:44
這個社會沒有任何的貞操實想。

00:49:46 - 00:49:53
在這個社會當中，女生啊，對女生來講，第一次性關係到底是跟誰發生的，一點都不重要。

00:49:55 - 00:49:59
在這個社會裡面，女生的第一次性關係是跟誰發生的。

00:50:00 - 00:50:00
就如同這個女生第一次把期待的對象是誰一樣

00:50:03 - 00:50:05
搞不好沒幾天就忘了，根本就不重要

00:50:06 - 00:50:10
那你想喔,在一個完全沒有貞操思想的社會之下

00:50:11 - 00:50:16
被性侵的女生,他所承受的心理痛苦,應該也會低得很多吧

00:50:17 - 00:50:18
應該可以想像吧,對不對

00:50:19 - 00:50:25
換句話講,在這個社會當中,為什麼女生被性侵之後,會承受那麼強烈的心理痛苦

00:50:25 - 00:50:29
其實有很大程度的因素跟貞操思維有關

00:50:30 - 00:50:39
很多被性侵的女生在被性侵之後，都會自我檢討說，奇怪，我是不是做了什麼錯事才會被性侵害，是不是我穿得太少了，是不是我太沒有警覺性之類的

00:50:40 - 00:50:42
女生還會有一切這種的思考

00:50:43 - 00:50:46
或者甚至有些女生會說我被性侵，我是不是髒掉了

00:50:46 - 00:50:49
真的我今年還在D卡上看到這種文

00:50:49 - 00:50:52
女生會有這種思想，當然跟貞操思維有關

00:50:53 - 00:50:57
你不要寫貞操思維好像到現在已經不見的,沒有啦,只是臺灣社會還是很保守

00:50:58 - 00:50:59
臺灣社會一直到現在

00:50:59 - 00:51:02
其實還是有貞操思想在

00:51:02 - 00:51:04
只是那個貞操思想可能是另外一個面貌而已

00:51:05 - 00:51:09
古老版的貞操思想是說老婆要是處女

00:51:09 - 00:51:11
現在臺灣的男生可能比較沒有這個想法，沒錯

00:51:12 - 00:51:14
可是其實還是有類似版本的想法

00:51:14 - 00:51:16
就像我常在D卡上看到一種文

00:51:18 - 00:51:20
很多男生偶然得知

00:51:20 - 00:51:23
自己的女朋友曾經以前約過炮

00:51:23 - 00:51:25
或者以前曾經有墮過胎，然後男生就崩潰了，上網討拍

00:51:28 - 00:51:29
我每次在D卡上看到這種文

00:51:30 - 00:51:32
我心中就是四個字，笑該你屁事

00:51:32 - 00:51:33
真的，這個是我的想法

00:51:34 - 00:51:36
以前我類似的文的時候，有同學問我，老師啊

00:51:37 - 00:51:41
如果你知道你的女朋友以前有約過炮，你真的能接受嗎？

00:51:41 - 00:51:42
我就回那到底甘我屁事啊？

00:51:43 - 00:51:45
一個女生在單身的時候難道沒有性自由嗎？

00:51:46 - 00:51:48
對啊，她單身的時候要跟誰約，幹我什麼事？

00:51:49 - 00:51:51
她跟我交往之後不要再約不就好了嗎？

00:51:51 - 00:51:52
我的觀念是這樣子啊，所以

00:51:53 - 00:51:54
你們想一想喔

00:51:55 - 00:52:00
有些男生不能接受自己的女朋友曾經墮過胎，曾經約過炮

00:52:01 - 00:52:03
這個想法不就是貞操思想嗎？

00:52:04 - 00:52:05
古代版的貞操思想是

00:52:05 - 00:52:08
老婆要是處女，婚前不可以有任何性經驗。

00:52:09 - 00:52:10
現代版的貞操思想是，

00:52:11 - 00:52:13
女生在跟自己有這段關係前，

00:52:13 - 00:52:15
不能有太放蕩的性行為。

00:52:15 - 00:52:16
那那個本質不是一樣的嗎？

00:52:17 - 00:52:19
都是在講說女生不能隨便啊,

00:52:19 - 00:52:20
對啊,那個就是一樣的思想啊。

00:52:21 - 00:52:22
所以貞操思想沒有不見,

00:52:22 - 00:52:23
它依然還活著,

00:52:24 - 00:52:26
只是繼續用不同的面貌展現而已。

00:52:26 - 00:52:27
真的。

00:52:28 - 00:52:28
甚至，

00:52:29 - 00:52:30
你們不要覺得我們臺灣很開放，

00:52:31 - 00:52:34
其實臺灣社會到現在還是有很多很保守的性觀念存在，

00:52:35 - 00:52:37
只是你們可能沒有意識到那是保守的觀念。

00:52:38 - 00:52:41
像比如說很多人說女生懷孕，男生要負責。

00:52:42 - 00:52:43
那就是保守的想法。

00:52:44 - 00:52:46
你們有想過這件事，什麼叫負責？

00:52:47 - 00:52:49
做錯事的人才要負責嘛。

00:52:50 - 00:52:51
對啊，做錯事的人才要負責啊。

00:52:51 - 00:52:55
那一對男女發生性行為之後，女生意外懷孕，

00:52:56 - 00:52:57
為什麼會是男生做錯事？

00:52:58 - 00:53:01
除非當初的危險性行為是沒有經過女生同意的，

00:53:01 - 00:53:02
除非是這樣。

00:53:03 - 00:53:04
不然沒有人做錯事啊。

00:53:04 - 00:53:06
這不就是個不可歸責於雙方的意外嗎?

00:53:07 - 00:53:08
對啊，這沒有人做錯事啊。

00:53:08 - 00:53:10
那男生有什麼好負責的。

00:53:11 - 00:53:12
你知道這個思想從哪來的嗎？

00:53:12 - 00:53:15
這個思想就是從貞操思維的時代來的。

00:53:15 - 00:53:17
你們想一想，在五六十年前那個社會，

00:53:18 - 00:53:19
當時那個社會，

00:53:20 - 00:53:22
男性普遍有處女情結，

00:53:22 - 00:53:24
非處女不娶，這是第一個。

00:53:25 - 00:53:26
再來在當時那個社會當中，

00:53:28 - 00:53:29
沒有合法的墮胎管道。

00:53:30 - 00:53:33
因為當時沒有優生保健法。

00:53:33 - 00:53:36
然後在當時這個社會之下，農業社會為主，

00:53:37 - 00:53:38
社會相對封閉。

00:53:38 - 00:53:40
你要墮胎，你可能去你家附近的密醫墮胎。

00:53:41 - 00:53:42
那個消息很容易傳開。

00:53:43 - 00:53:47
所以以前那個社會之下,如果女生意外懷孕去墮胎,

00:53:47 - 00:53:49
那個事情可能很容易被大家知道。

00:53:50 - 00:53:53
然後以前有貞操思想,男生不會想娶墮過胎的女生,

00:53:53 - 00:53:54
再加上還有一個關鍵因素,

00:53:55 - 00:53:57
以前那個年代女生的教育程度低,

00:53:58 - 00:54:00
很少有什麼自主工作,

00:54:00 - 00:54:00
去賺錢的能力。

00:54:00 - 00:54:00
所以在那個年代當中

00:54:02 - 00:54:06
一個有過性經驗，甚至有過墮胎經驗的女生，她在婚姻市場的價值幾乎是零。

00:54:09 - 00:54:10
沒有人要娶他。

00:54:11 - 00:54:13
那他是不是一輩子只能靠他的娘家養？

00:54:14 - 00:54:19
所以為什麼以前會有說，男生讓女生意外懷孕，男生要娶她以示負責這個說法。

00:54:19 - 00:54:21
是起源於那個時代背景來的。

00:54:21 - 00:54:24
我聽說有一種比喻，叫做拆封式同捆購買。

00:54:24 - 00:54:25
沒錯,就是那個時代的思維。

00:54:26 - 00:54:27
可是現在不是耶。

00:54:27 - 00:54:29
現在時代已經完全不一樣了。

00:54:30 - 00:54:33
男生跟女生發生性關係,然後女生意外懷孕,奇怪,為什麼不說男生？

00:54:34 - 00:54:37
如果男生沒有給我們女生什麼承諾的話

00:54:37 - 00:54:38
為什麼不說

00:54:38 - 00:54:43
那女生同意要跟男生進行危險性行為，女生就應該自己承擔意外懷孕而墮胎的風險。

00:54:44 - 00:54:45
我覺得不是應該這樣講才對嗎？

00:54:45 - 00:54:51
所以那種什麼女生懷孕男生負責的想法，我覺得那個也是一個很封建時代的思想啦。

00:54:51 - 00:54:53
就是跟貞操思維有關啦。

00:54:53 - 00:54:56
所以我就說，真操性思維你不要以為它不見了。

00:54:56 - 00:54:57
到現在依然存在

00:54:58 - 00:55:00
只是用不同的面貌繼續存在而已。

00:55:00 - 00:55:01
真的。

00:55:01 - 00:55:01
所以

00:55:02 - 00:55:04
226條第二項的背後

00:55:05 - 00:55:06
就是在保護

00:55:06 - 00:55:08
就是在保護這種貞操思想。

00:55:09 - 00:55:10
透過這個條文

00:55:10 - 00:55:12
一般人看到這個條文會是什麼感覺

00:55:13 - 00:55:16
會覺得說，女生被性侵之後會羞憤自殺，好像還蠻合理的啊。

00:55:17 - 00:55:21
所以這個條文就怎麼樣，間接鞏固的那一種性別上的想法。

00:55:22 - 00:55:25
像我講個去年的時事，麥當勞性侵案。

00:55:27 - 00:55:30
我還蠻多同溫層的學生啊朋友啊會

00:55:30 - 00:55:31
去抵制麥當勞。

00:55:31 - 00:55:33
我對抵制麥當勞沒有太大的興趣啦。

00:55:35 - 00:55:36
聽清楚，我

00:55:36 - 00:55:37
不是支持性侵犯，絕對不是。

00:55:38 - 00:55:40
而是我不喜歡這種社會氛圍。

00:55:41 - 00:55:41
因為

00:55:42 - 00:55:44
我確實同意，在

00:55:44 - 00:55:47
現在這個社會氛圍之下，女生被性侵可能會承受很大的痛苦。

00:55:48 - 00:55:51
可是對我來說，我們應該要改變的是

00:55:51 - 00:55:53
消除這個貞操思想。

00:55:53 - 00:55:59
我就說了，假設一個社會當中沒有任何貞操思想的話，那女生被性侵應該也不會那麼痛苦。

00:56:00 - 00:56:03
我們要營造的應該是一個消除貞操思想,不要把性看得那麼重要的社會。

00:56:06 - 00:56:09
如果我們有一個這樣的社會,那女生就不會那麼痛苦了。

00:56:09 - 00:56:16
而不是呢,我們站在既有的社會結構之下,一直譴責男生,然後一直說對女生很痛苦,我不喜歡那樣的思維。

00:56:17 - 00:56:23
所以對我來說啦,面對這種性侵害的案件,我會思考的是根本社會結構的問題。

00:56:23 - 00:56:30
如果我們沒有貞操思想,如果女生對於性經驗跟誰看得不是那麼重要,那女生被性侵應該就不會那麼痛苦了。

00:56:30 - 00:56:32
所以回到26條二項,我會覺得

00:56:33 - 00:56:35
這個條文應該要刪掉,不止我啦,其他學界也是,認為說這個條文應該要刪掉,為什麼?

00:56:39 - 00:56:47
因為這個條文背後所表彰的思想就是女生被性侵,她會羞憤很合理,所以侵害人的刑責要加重。

00:56:47 - 00:56:55
那我就說了,該有的思考是這個女生被性侵後羞憤的想法,那是來自父權思維的產物。

00:56:55 - 00:56:58
父權思維應該是要移除才對,而不是用法律

00:57:00 - 00:57:01
去維護他。

00:57:01 - 00:57:05
用法律去鞏固他說對，女生你覺得性侵被性侵很合理，不應該是這樣子哦。

00:57:07 - 00:57:08
好。

00:57:08 - 00:57:14
所以這個性侵的問題，26條第二項，我就說呢，這個規定十個學者，九個都說他要刪掉了。

00:57:15 - 00:57:16
我再多講個警句，真的啦。

00:57:16 - 00:57:19
現在的社會你不要以為說男女很平等，現在這個社會其實父權觀念，或者是那種傳統觀念，其實還是很深。

00:57:24 - 00:57:29
像比如說很多女生會覺得說在男女關係當中，男生多付一點錢是應該的。

00:57:30 - 00:57:31
很多女生有這種思考。

00:57:31 - 00:57:33
那我就跟同學講，我們要破解這種性別刻板印象其實很簡單，就把其中的男女主角對調就好了。

00:57:39 - 00:57:39
對。

00:57:39 - 00:57:41
很多女生說男生要多付一點，那我就反問，那為什麼不是女生要多付一點？

00:57:44 - 00:57:44
對啊，為什麼？

00:57:45 - 00:57:47
這就是性別刻板印象啊，因為

00:57:49 - 00:57:51
傳統上這個要怎麼說。

00:57:53 - 00:57:55
你們不要以為說父權觀念，一定是那一種。

00:57:56 - 00:57:59
把女生當作客題去宰制、去支配，對女生很差那個才叫父權。

00:58:00 - 00:58:00
父權，沒有父權的。

00:58:02 - 00:58:04
把女生看作比男生低一等的生物。

00:58:05 - 00:58:06
覺得女生不如男生，那個就是父權思想。

00:58:08 - 00:58:08
所以你想喔。

00:58:10 - 00:58:12
那種傳統的鄉土劇。

00:58:13 - 00:58:14
呃，惡婆婆。

00:58:15 - 00:58:16
女代父職。

00:58:17 - 00:58:20
或者是先生把太太當出氣筒。

00:58:21 - 00:58:22
那樣的男女關係。

00:58:22 - 00:58:23
那個是父權沒有錯。

00:58:25 - 00:58:26
換到現在另外一個極端。

00:58:27 - 00:58:30
男生把女生當作一個無行為能力人呵護。

00:58:30 - 00:58:32
那種想法其實也是父權啊。

00:58:32 - 00:58:34
那個叫浪漫主義的父權。

00:58:34 - 00:58:40
真的啦，之前大法官在有關勞基法的解釋當中，講到那個女工夜間工作的限制，大法官就提到這個名字：浪漫父權。

00:58:42 - 00:58:44
浪漫父權也是父權的一種。

00:58:44 - 00:58:47
他就是覺得女生很弱，所以男生要保護她。

00:58:48 - 00:58:49
那也是一種父權。

00:58:49 - 00:58:55
所以你不要覺得說父權一定是怎麼樣，父權就反正你把女生當作一個比較次等的對象。

00:58:55 - 00:58:56
那個就是父權思想。

00:58:56 - 00:58:58
所以父權思想現在依然存在啊。

00:58:58 - 00:59:05
很多人覺得說男生要保護女生，男生不能讓女生受傷，男生這個要多付一點錢什麼的，那也是父權思想。

00:59:05 - 00:59:06
所以講這麼多我就說。

00:59:08 - 00:59:09
你不要覺得臺灣很進步啦。

00:59:09 - 00:59:11
臺灣這個社會到目前為止。

00:59:11 - 00:59:13
依然很多時候很多人都會覺得說。

00:59:14 - 00:59:15
這個女生是怎麼樣的人。

00:59:15 - 00:59:16
比較弱勢啊。

00:59:16 - 00:59:19
或者是覺得男生應該保護女生之類的。

00:59:19 - 00:59:20
那個這都是父權思想。

00:59:20 - 00:59:21
所以。

00:59:22 - 00:59:23
從這個條文其實可以講很多啦。

00:59:23 - 00:59:24
就是講說226條第二項這個條文。

00:59:26 - 00:59:27
它絕對不是什麼進步的條文。

00:59:28 - 00:59:30
這個條文，它是一個有問題的規定。

00:59:30 - 00:59:32
它可能是無數無過失責任的條文。

00:59:32 - 00:59:35
而且它也會有這個父權思想的疑慮。

00:59:35 - 00:59:36
所以這個條文呢。

00:59:36 - 00:59:39
應該要把他丟掉才對，而不是透過刑法的繼續去維護它。

00:59:42 - 00:59:43
然後這裡的話，我們把這個單元看完了。

00:59:44 - 00:59:45
我們接下來看幾個。

00:59:47 - 00:59:48
來看到幾個題目。

01:00:21 - 01:00:23
我們看一個代表性的就好。

01:00:23 - 01:00:25
那個36頁的23題。

01:01:49 - 01:01:49
還沒了。

01:01:50 - 01:01:53
那個36頁的23題我們來看一下。

01:01:54 - 01:01:55
23題，這一題。

01:01:57 - 01:02:00
那個筆，那個筆的部分，他怎麼論述。

01:02:00 - 01:02:01
罪不成也。

01:02:01 - 01:02:03
所以那A罪不成罪的話

01:02:04 - 01:02:04
我們怎麼辦

01:02:05 - 01:02:06
A等於C

01:02:06 - 01:02:08
我講嘛，加重結果犯是A加B等於C嘛

01:02:09 - 01:02:11
A最不成罪，那個A最不切題的B怎麼等於C，對不對

01:02:11 - 01:02:17
所以這一題當中,當然沒辦法成立加重結果犯,不可能,你知道嗎？

01:02:17 - 01:02:22
時間在第一步,基礎犯這個部分,就把它否定掉了,不可能喔。

01:02:24 - 01:02:27
好,所以這一題是這樣子。

01:02:27 - 01:02:29
然後,看一下喔。

01:02:40 - 01:02:42
好,沒關係,我們看這一題就好。

01:02:42 - 01:02:45
OK，我們先到這邊休息10分鐘，等一下我再來看那個不作為犯。

01:02:49 - 01:02:53
好，我們接下來看到這個第十單元關於不作為犯。

01:02:54 - 01:02:56
好，終於進入刑總快要尾聲的階段了。

01:02:56 - 01:02:58
我們講完很多犯罪類型，最後一種是不作為犯。

01:02:59 - 01:03:02
不作為犯結束，就會進入到競合的單元。

01:03:02 - 01:03:03
我們來看到最後這個東西，不作為犯。

01:03:04 - 01:03:11
好，我們在講不作為犯的時候啊，我們前面講過，不作為犯分兩種，純正不作為跟不純正不作為。

01:03:11 - 01:03:14
這個定義，我相信同學應該對它們都很熟悉了。

01:03:14 - 01:03:17
所以我這邊的話呢，就不再特別去講了。

01:03:17 - 01:03:19
反正我說了。

01:03:20 - 01:03:21
純正不作為犯。

01:03:22 - 01:03:23
這個在刑總沒有什麼好說的。

01:03:24 - 01:03:26
因為純正不作為犯，那個就是法條規定的問題。

01:03:27 - 01:03:30
純正不作為犯就是隻要你有法條的不作為義務，罪就成立。

01:03:30 - 01:03:30
罪就成立。

01:03:31 - 01:03:34
所以純正不作為犯，他是刑分的問題。

01:03:34 - 01:03:35
我們刑總要談的不多，所以我們接下來這個單元不作為犯。

01:03:38 - 01:03:41
我們要談的是不純正不作為犯，記得喔。

01:03:41 - 01:03:43
我們要談的是不純正不作為犯。

01:03:43 - 01:03:45
這個東西在刑總才有的談。

01:03:45 - 01:03:49
那第二點這邊呢，我們講到不純正不作為犯成立的界線。

01:03:49 - 01:03:50
各位。

01:03:50 - 01:03:53
原則上，刑法分則上面的犯罪。

01:03:53 - 01:03:56
原則上每一條都可以成立不純正不作為犯。

01:03:58 - 01:04:00
原則上都可以喔。

01:04:00 - 01:04:01
知道嗎?

01:04:01 - 01:04:04
刑法分則的各罪原則上都可以成立，包含不作為犯。

01:04:06 - 01:04:09
比如說你來看到了那個刑法184的犯罪。

01:04:09 - 01:04:12
那個損壞軌道燈塔那一條，刑法184。

01:04:13 - 01:04:20
那個刑法184啊，他說如果你損壞軌道燈塔標識，因而致生火車往來的危險。

01:04:20 - 01:04:21
這是刑法184。

01:04:21 - 01:04:24
各位184條文規範的是作為嘛，對不對？

01:04:24 - 01:04:25
所以184在罰什麼呢？

01:04:25 - 01:04:30
比如說你把鐵軌去斷，你把平交道的欄杆拔掉。

01:04:30 - 01:04:32
這種的，這個叫刑法184，OK，沒有問題。

01:04:34 - 01:04:35
可不可以是不作為？

01:04:36 - 01:04:37
可以，絕對可以。

01:04:37 - 01:04:39
那你說什麼叫184的不作為？

01:04:39 - 01:04:40
有啊，可以啊。

01:04:40 - 01:04:50
比如說那個臺鐵的包商，他們有跟臺鐵簽約，說要去修理火車軌道，或者要修理平交道。

01:04:50 - 01:04:54
結果他簽的約之後沒有去修,放任火車繼續通行。

01:04:54 - 01:04:56
那個是不是184的不作為?

01:04:56 - 01:04:56
是啊。

01:04:57 - 01:04:58
所以像184條這種犯罪。

01:04:59 - 01:05:00
他條文是寫損壞喔。

01:05:00 - 01:05:02
可是損壞一定要是作為嗎？不見得啊。

01:05:03 - 01:05:06
有修繕義務的人不修繕，那就是不作為的損壞啊。

01:05:06 - 01:05:07
瞭解喔。

01:05:07 - 01:05:11
所以184這種犯罪，也可以不作為喔，這個十年前律師有考過喔。

01:05:11 - 01:05:12
老師我們講，刑法上

01:05:13 - 01:05:16
絕大多數的犯罪都可以透過不作為的方式來實現。

01:05:19 - 01:05:20
來翻過來。

01:05:20 - 01:05:22
少數的犯罪。

01:05:22 - 01:05:25
只有一些少數的犯罪是只能用作為實現的。

01:05:27 - 01:05:29
它是只能用作為實現的。

01:05:29 - 01:05:30
像第一個

01:05:30 - 01:05:31
妨害公務罪。

01:05:31 - 01:05:34
因為妨害公務罪他條文寫強暴脅迫。

01:05:34 - 01:05:38
所以這一條罪只能用作為的方式來實現，只能作為。

01:05:39 - 01:05:42
你說有不作為的強暴脅迫嗎？

01:05:42 - 01:05:44
有，想像上是有可能的。

01:05:45 - 01:05:47
比如說你養的一隻比特犬。

01:05:47 - 01:05:52
那有一天警察去你家搜索，那隻比特犬很聽你的話，但你就故意不控制牠。

01:05:54 - 01:05:56
比特犬看到有人入侵。

01:05:56 - 01:05:58
那個比特犬就衝過去咬警察。

01:05:58 - 01:06:00
還把警察的兩顆蛋

01:06:00 - 01:06:00
蛋咬掉，

01:06:00 - 01:06:02
如果是這樣，這樣的話你可不可以成立

01:06:02 - 01:06:05
那個妨害公務致重傷罪的不作為犯？

01:06:05 - 01:06:05
不行喔。

01:06:06 - 01:06:09
135這個犯罪，它僅限於作為，

01:06:09 - 01:06:11
不作為沒辦法成立，這個是第一個，

01:06:11 - 01:06:13
像135的犯罪它就是。

01:06:14 - 01:06:16
還有第二個，登載不實的系列。

01:06:17 - 01:06:21
登載不實的犯罪，也僅限於作為，

01:06:21 - 01:06:23
實務的說法，僅限作為。

01:06:23 - 01:06:27
所以啊，消極的不登載，不更正。

01:06:27 - 01:06:30
這沒辦法論登載不實的犯罪。

01:06:31 - 01:06:34
我們以213的公務員登載不實為例喔。

01:06:34 - 01:06:37
警察找毒販去派出所做筆錄。

01:06:38 - 01:06:40
那警察就問毒販說你有賣毒品嗎？

01:06:41 - 01:06:43
毒販說沒有，我真的沒有賣。

01:06:43 - 01:06:48
結果警察在筆錄上面寫說對，我有賣，我承認警察的指控。

01:06:48 - 01:06:50
這個叫213，沒有疑問。

01:06:50 - 01:06:52
人家說A你寫非A嘛，對不對？

01:06:52 - 01:06:54
這個叫登載不實，這個沒有疑問。

01:06:55 - 01:06:57
那你知道嗎，登載不實的犯罪，

01:06:57 - 01:07:01
確實有可能涉及到不作為哦。

01:07:01 - 01:07:03
理論上有可能，但是說上說沒有辦法成立。

01:07:04 - 01:07:04
什麼意思？

01:07:05 - 01:07:06
應登載而不登載，

01:07:06 - 01:07:08
應更正而未更正。

01:07:08 - 01:07:09
我們講，

01:07:10 - 01:07:12
一樣，警察在派出所做筆錄。

01:07:13 - 01:07:14
那警察就問啦：

01:07:15 - 01:07:16
你有沒有賣毒品？

01:07:17 - 01:07:18
毒販說我沒有。

01:07:19 - 01:07:20
警察說你還說你沒有，

01:07:20 - 01:07:21
來，來你看一下，

01:07:21 - 01:07:24
這個是你的跟你買毒的人，他們做的筆錄。

01:07:25 - 01:07:27
你看啊，ABCD四個人欸。

01:07:28 - 01:07:29
四個人都說毒品跟你買欸。

01:07:30 - 01:07:31
你還說你沒賣，你怎麼解釋？

01:07:32 - 01:07:34
然後這個時候毒販說，哎呀，我不意外。

01:07:34 - 01:07:36
那四個人，第一個他們人品差。

01:07:36 - 01:07:38
他們就本來喜歡，本來就喜歡說謊。

01:07:38 - 01:07:41
還有啊，那四個人，他們都欠我錢。

01:07:42 - 01:07:44
那他們都欠我錢，我一直跟他們要錢，

01:07:44 - 01:07:46
所以他們聯合起來栽贓，

01:07:46 - 01:07:48
說我賣毒給他們，當然合理啊。

01:07:48 - 01:07:52
因為他們欠我錢，他們栽贓我販毒，我被抓進去關的話，

01:07:53 - 01:07:55
那就沒有人跟他們討錢啊，他們錢就不用還了，

01:07:55 - 01:07:58
他們鐵定是基於這樣的動機，才誣賴我販毒啦，

01:07:58 - 01:07:58
一定是這樣。

01:07:59 - 01:08:00
毒販這樣回答。

01:08:00 - 01:08:02
結果警察記錄的時候，剛剛毒販講的那一段話全部否認，全部都忽略。

01:08:05 - 01:08:08
警察只在筆錄上說，毒販打人，我沒有賣。

01:08:09 - 01:08:09
這個叫什麼？

01:08:10 - 01:08:12
應登載而未登載，對不對？

01:08:13 - 01:08:13
會不會成立犯罪？不會。

01:08:14 - 01:08:15
瞭解嗎？所以實務說了。

01:08:16 - 01:08:17
登載不實的犯罪，僅限作為哦。

01:08:19 - 01:08:23
不作為不成立哦，應登載而未登載，應更正而不更正，沒辦法成立哦。

01:08:24 - 01:08:27
好，再來第三類，沒辦法論不作為的犯罪。

01:08:27 - 01:08:30
第三類談的是公務員包庇犯罪。

01:08:31 - 01:08:32
包賭包槍，這種包庇的犯罪。

01:08:33 - 01:08:37
記得喔，包庇的犯罪，實務說只有積極的作為才算。

01:08:38 - 01:08:45
所以公務員包庇這個內線交易，或者警察投資賭業賭場、職業賭場，甚至警察擔任賭場的幹部，這個叫包庇，沒有錯。

01:08:52 - 01:08:57
但如果只是說警察知道轄區有賭場而不去取締，算不算包庇？

01:08:57 - 01:08:59
不算，這個不算。

01:09:00 - 01:09:03
所以包庇的犯罪呢，也只有作為才能成立。

01:09:03 - 01:09:06
好，所以這個是我們想的第一個，不作為犯的本質。

01:09:06 - 01:09:09
那再來第二個，關於作為跟不作為的區分。

01:09:09 - 01:09:12
這個東西也是近年在考試上很常出現的一個問題。

01:09:12 - 01:09:14
我們怎麼區分作為跟不作為呢？

01:09:15 - 01:09:17
其實我們前面沒有正式講。

01:09:18 - 01:09:22
我們前面只說積極的方式叫作為，消極的方式叫不作為。

01:09:23 - 01:09:25
這個說法很籠統啊，什麼叫積極，什麼叫消極？

01:09:26 - 01:09:27
那個在具體案例會遇到問題。

01:09:28 - 01:09:30
所以我們來看好，作為與不作為怎麼區分。

01:09:31 - 01:09:33
最早以前的說法叫能量說。

01:09:34 - 01:09:37
能量說說有身體動作就是作為，那沒有的話就是不作為，這是最早的版本。

01:09:40 - 01:09:41
但這說法後來沒有人採納。

01:09:41 - 01:09:43
因為後來的人發現這說法有問題嘛。

01:09:44 - 01:09:46
我們人無時無刻身體都會有動作。

01:09:47 - 01:09:48
你用這個方法是區分是否有問題的。

01:09:49 - 01:09:51
所以後來有一個修正版的能量說。

01:09:51 - 01:09:54
他說，從法益的好壞增減來認定。

01:09:55 - 01:09:57
讓法義惡化是作為。

01:09:58 - 01:10:00
不讓惡化的法益狀態好轉。

01:10:00 - 01:10:00
那是不作為。

01:10:00 - 01:10:00
這是氣玉偉老師的說法，叫能量啟助說。

01:10:05 - 01:10:12
這個能量啟助說，其實跟我們現在的通說，那個風險關係說，其實是類似的意思。

01:10:13 - 01:10:15
他只是用語不一樣，但其實那個觀察角度是一樣的，能量啟助說。

01:10:17 - 01:10:23
你可以寫了，就是氣月老師那個能量啟助說，他其實跟第三說風險關係說是很類似的觀點。

01:10:24 - 01:10:26
結論幾乎都是一樣的，有這一種說法。

01:10:27 - 01:10:28
然後我們來看到第二說。

01:10:30 - 01:10:32
第二說叫評價重點說。

01:10:33 - 01:10:35
評價重點說，是一個傳統上的說法。

01:10:36 - 01:10:41
這一說一直到現在其實都還蠻多人採的喔，像早期林山田老師的書採對說。

01:10:42 - 01:10:47
那現在的話基本主流的書，像那個許澤天老師啊，還有林書楷老師啊，他們也都是採對說。

01:10:48 - 01:10:48
評價重點說。

01:10:49 - 01:10:51
評價重點的意思是說啊，

01:10:51 - 01:10:56
這個犯罪到底是作為或不作為，如果認定上有疑慮的話，

01:10:56 - 01:11:02
那我們就把值得被評價、值得被譴責的那個部分抓出來看。

01:11:03 - 01:11:06
然後我們再看這個部分是作為或者是不作為。

01:11:07 - 01:11:07
這個叫做

01:11:09 - 01:11:10
這個叫做評價重點說。

01:11:11 - 01:11:14
所以照評價重點說來看山羊毛案。

01:11:15 - 01:11:16
我們前面講那個山羊毛案。

01:11:17 - 01:11:20
山羊毛案，感覺既有作為，又不作為，對不對？

01:11:20 - 01:11:22
因為他不作為的成分是沒消毒。

01:11:23 - 01:11:24
作為的成分是交付。

01:11:25 - 01:11:25
那我們看喔，

01:11:26 - 01:11:29
如果一個案件到底是作為或不作為，認定有疑問的話，

01:11:29 - 01:11:31
評價重點所主張的是，

01:11:31 - 01:11:33
那我們就把有疑問的部分抓出來。

01:11:35 - 01:11:37
我們就把值得被譴責的部分抓出來。

01:11:38 - 01:11:40
所以這個案例值得被譴責的是哪一個部分？

01:11:41 - 01:11:41
哪一個部分？

01:11:42 - 01:11:44
呃，沒有消毒，還是交付？

01:11:44 - 01:11:45
交付嘛，對不對？

01:11:46 - 01:11:47
那所以交付是作為還是不作為？

01:11:48 - 01:11:48
作為啊。

01:11:49 - 01:11:50
這就是評價重點說的思考，知道嗎？

01:11:50 - 01:11:51
這個是作為啊。

01:11:52 - 01:11:55
所以照評價重點說來講的話，

01:11:55 - 01:11:56
這一件，

01:11:56 - 01:11:57
它就是什麼呢？

01:11:57 - 01:11:58
它就是作為一半喔，知道嗎？

01:11:58 - 01:11:59
這評價重點說。

01:12:00 - 01:12:00
好，

01:12:01 - 01:12:03
評價重點說雖然是一個主流的說法沒有錯，

01:12:03 - 01:12:05
但這個說法會遇到的問題是，

01:12:07 - 01:12:08
他會遇到的問題是，

01:12:09 - 01:12:10
循環論證。

01:12:10 - 01:12:11
為什麼？

01:12:11 - 01:12:12
你想一下這個思考。

01:12:13 - 01:12:15
你想一下評價重點的說法。

01:12:15 - 01:12:20
他說，如果這個犯罪是作為或不作為我們難以判斷的話，

01:12:20 - 01:12:24
那我們就把值得譴責的部分挑出來看，

01:12:24 - 01:12:26
然後看這個部分是作為還不作為。

01:12:28 - 01:12:30
你有沒有發現他根本沒有提出標準？

01:12:30 - 01:12:32
對啊，沒有錯啊。

01:12:33 - 01:12:36
這個就好像，什麼叫好人，什麼叫壞人。

01:12:37 - 01:12:39
然後你的回答是被認定成好人的人就是好人，

01:12:39 - 01:12:41
被認定成壞人的人就是壞人。

01:12:41 - 01:12:43
講白就是這個意思，它叫循環論證，

01:12:43 - 01:12:44
懂嗎？

01:12:44 - 01:12:47
所以第二種說法評價重點說，一直被批評的，

01:12:47 - 01:12:48
說他循環論證。

01:12:49 - 01:12:52
於是我們來看我覺得最可採的說法叫風險關係說。

01:12:53 - 01:12:55
風險關係說怎麼看作為跟不作為呢？

01:12:56 - 01:12:56
好，

01:12:56 - 01:12:58
他說，製造原本不存在的風險，

01:12:59 - 01:13:19
那個是

01:13:19 - 01:13:40
作為。

01:13:41 - 01:13:43
放任既有的風險發生或擴大，

01:13:44 - 01:13:44
那是不作為。

01:13:45 - 01:13:45
OK嗎？

01:13:46 - 01:13:48
製造風險是作為。

01:13:49 - 01:13:52
放任既有的風險發生或擴大，

01:13:53 - 01:13:54
那是不作為。

01:13:55 - 01:14:00
所以其實這一說跟謝玉偉老師那個修正版的能量說，其實已經差不多的啦。

01:14:00 - 01:14:00
來，山羊毛案作為或不作為

01:14:04 - 01:14:06
其實我跟你們說評價重點說不是完全沒有意義

01:14:07 - 01:14:10
其實評價重點說它的用途是什麼你知道嗎

01:14:11 - 01:14:17
就是我們判斷完作為跟不作為之後，如果一個犯罪同時有作為又有不作為的話

01:14:17 - 01:14:21
評價重點說的意思是我們要優先以作為來論罪

01:14:22 - 01:14:27
瞭解吧，所以其實評價重點說嚴格來講，它不是一個區分作為跟不作為的理論

01:14:28 - 01:14:30
它其實是一個決定競合關係的理論

01:14:31 - 01:14:38
就是一個犯罪如果同時有作為有不作為的話,評價重點說會跟我們講的,我們要優先論作為的部分,其實這個意思知道吧

01:14:43 - 01:14:46
所以山羊毛案,如果我們挑的行為是交付

01:14:47 - 01:14:50
那交付從風險關係來講，這個是作為還不作為

01:14:51 - 01:14:52
交付

01:14:53 - 01:14:54
這是作為喔

01:14:54 - 01:14:55
為什麼

01:14:55 - 01:14:59
因為把一塊有細菌的山羊毛交給女工去加工

01:15:00 - 01:15:01
這個是製造原本不存在的風險

01:15:01 - 01:15:03
對，沒有錯，所以這個是作為

01:15:03 - 01:15:05
好，第二個不開車燈案也是

01:15:07 - 01:15:09
開著一臺沒有燈的車上路

01:15:10 - 01:15:12
這個是不是製造原本不足的交通危險

01:15:12 - 01:15:13
對，沒有錯，所以這個也是作為

01:15:14 - 01:15:16
接著第三個叫急診醫生案

01:15:18 - 01:15:20
這個病患啊，受到嚴重的槍傷

01:15:21 - 01:15:25
可是醫師卻採取一些無意的救助措施，用生理食鹽水消毒傷口之類的

01:15:26 - 01:15:27
這個是作為或不作為

01:15:29 - 01:15:30
外表上有動作沒有

01:15:30 - 01:15:32
可是他的作為根本毫無意義

01:15:32 - 01:15:33
他根本是在怎麼樣

01:15:34 - 01:15:37
放任傷患死亡的風險繼續擴大，所以這個是什麼呢

01:15:38 - 01:15:39
不作為，知道嗎

01:15:39 - 01:15:39
這個是不作為

01:15:40 - 01:15:41
好來

01:15:41 - 01:15:44
發現仇人案1234，這個是會考的一些案例

01:15:45 - 01:15:46
一的話你看喔

01:15:48 - 01:15:49
發現有人

01:15:49 - 01:15:50
仇人嘛,不救,所以就離開了

01:15:52 - 01:15:53
沒有疑問吧,所以一定是甚麼

01:15:55 - 01:15:55
不作為,對不對

01:15:56 - 01:15:58
放任那個人死亡的風險擴大嘛,這是不作為

01:15:59 - 01:15:59
那之一

01:16:00 - 01:16:01
繩索丟下去,

01:16:01 - 01:16:02
被害人還沒有抓到,

01:16:03 - 01:16:05
他就把繩索抽起來了。

01:16:06 - 01:16:07
那有丟跟沒有丟一樣嘛,

01:16:07 - 01:16:08
被害人還是那樣嘛。

01:16:09 - 01:16:10
所以本體是什麼呢？

01:16:10 - 01:16:11
依然是不作為，

01:16:12 - 01:16:12
懂嗎？

01:16:12 - 01:16:13
依然是不作為喔。

01:16:13 - 01:16:13
好。

01:16:14 - 01:16:15
13呢？

01:16:16 - 01:16:17
被害人拉到繩索了喔,

01:16:19 - 01:16:20
繩索也快拉起來了喔,

01:16:22 - 01:16:23
結果行為人發現,

01:16:23 - 01:16:23
哎呀！

01:16:23 - 01:16:24
那個人竟然是仇人

01:16:24 - 01:16:26
趕快慢慢地把繩索放回去

01:16:27 - 01:16:28
被害人重回受困的狀態

01:16:29 - 01:16:30
這個去年考過欸

01:16:31 - 01:16:32
這很多同學都會搞錯

01:16:32 - 01:16:33
我跟你們講，

01:16:33 - 01:16:34
這個是作為。

01:16:35 - 01:16:35
這個是作為，

01:16:35 - 01:16:36
為什麼？

01:16:37 - 01:16:42
因為被害人在被拉起來快要獲救的時候，

01:16:42 - 01:16:44
他是處於一個安全狀態。

01:16:45 - 01:16:47
然後行為人把繩索放掉，

01:16:47 - 01:16:49
讓他重新回到下水道，

01:16:50 - 01:16:53
那是把一個安全狀態的人推到危險狀態。

01:16:54 - 01:16:55
所以那個叫什麼？

01:16:55 - 01:16:56
製造風險,

01:16:56 - 01:16:56
懂嗎？

01:16:56 - 01:16:57
那個叫製造風險,

01:16:58 - 01:16:59
所以他是作為。

01:17:00 - 01:17:01
有些人的思考是,

01:17:01 - 01:17:03
啊可是他原本就在下水道啊,

01:17:04 - 01:17:06
他最後不是隻是回到原本那個地方而已,

01:17:06 - 01:17:06
不對,

01:17:06 - 01:17:07
你不能這樣思考。

01:17:08 - 01:17:10
因為我們評價的是行為人的哪一件事？

01:17:11 - 01:17:12
鬆開繩索。

01:17:13 - 01:17:14
所以在鬆開繩索那個當下，

01:17:14 - 01:17:15
被害人原本是怎麼樣？

01:17:16 - 01:17:18
處於已獲救的安全狀態喔，

01:17:19 - 01:17:20
然後行為人把繩索鬆開。

01:17:20 - 01:17:22
讓他重新回到一個危險狀態,

01:17:22 - 01:17:23
所以那個叫什麼？

01:17:24 - 01:17:26
製造風險,

01:17:26 - 01:17:27
那個叫做偽作為,

01:17:28 - 01:17:28
懂嗎？

01:17:28 - 01:17:29
那個叫作為喔。

01:17:29 - 01:17:30
來，

01:17:30 - 01:17:32
發現仇人案之四。

01:17:33 - 01:17:33
欸，

01:17:33 - 01:17:34
這個時候啊，

01:17:35 - 01:17:35
你看喔，

01:17:36 - 01:17:37
甲要救人啊，

01:17:37 - 01:17:38
乙也發現有人受困啊，

01:17:38 - 01:17:40
而且乙發現那個人是仇人啊，

01:17:40 - 01:17:42
所以乙搶先一步。

01:17:42 - 01:17:45
搶走甲又要用來救援的繩索。

01:17:46 - 01:17:47
結果啊,

01:17:47 - 01:17:48
那個,

01:17:48 - 01:17:50
那個乙就死掉了,

01:17:50 - 01:17:51
來,

01:17:51 - 01:17:52
乙案還是不作為？

01:17:53 - 01:17:54
這個是近年來很熱門的案例，

01:17:54 - 01:17:55
考試考過很多次，

01:17:55 - 01:17:58
謝玉偉老師寫了三篇文章都在談這個問題。

01:17:59 - 01:18:00
今年來考...

01:18:00 - 01:18:00
重要哈，這種救助關係的阻斷，要是不作為。

01:18:04 - 01:18:06
我舉一個更簡單的例子，讓你們更有帶入感，你們想一下哈。

01:18:07 - 01:18:11
假設等一下我在講臺上突然上課上到一半，我就昏倒在講臺上的。

01:18:11 - 01:18:15
好，我昏倒之後啊，同學你緊張嗎，就要打119啊，要送我去醫院。

01:18:16 - 01:18:20
結果救護車到了之後，我被這個救護車已經到了。

01:18:21 - 01:18:23
我原本將要被獲救了。

01:18:23 - 01:18:27
結果這時候啊，忽然有另外一個討厭我的同事。

01:18:27 - 01:18:29
他心想我不能被救。

01:18:29 - 01:18:33
於是這個同事呢，就上前把救護人員打昏。

01:18:33 - 01:18:35
讓我無法被送上救護車。

01:18:36 - 01:18:41
或者是這個同事，他就去樓下把救護車的輪胎刺破，讓我無法送醫。

01:18:42 - 01:18:44
結果我最後就倒在講臺上心肌梗塞而死。

01:18:45 - 01:18:48
各位，那個打昏救護人員的同事。

01:18:49 - 01:18:51
跟那個下去把救護車輪胎刺破的同事。

01:18:53 - 01:18:54
作為或不作為。

01:18:54 - 01:18:55
來，我要強調。

01:18:57 - 01:18:59
這個人，他打昏救護人員涉及到強制罪。

01:19:00 - 01:19:01
涉及到傷害罪。

01:19:02 - 01:19:06
他刺破救護車的輪胎，涉及到妨害公務的犯罪，涉及到毀損罪。

01:19:06 - 01:19:09
這些犯罪百分之百是作為，不用懷疑，你知道嗎？

01:19:09 - 01:19:13
我們要談的是，那他把救護車輪胎刺破，他把救護人員打昏。

01:19:14 - 01:19:17
對於我生命法益的這個殺人罪來講，作為還是不作為？

01:19:20 - 01:19:20
不作為，為什麼？

01:19:22 - 01:19:23
因為你想活。

01:19:23 - 01:19:27
我原本倒在講臺上的風險是心肌梗塞而死。

01:19:27 - 01:19:32
他把救護人員打昏，他把救護車的輪胎刺破，他有造成我死亡的新風險嗎？

01:19:33 - 01:19:33
沒有。

01:19:34 - 01:19:38
他只是怎麼樣，放任我倒在講臺上死亡的風險繼續擴大。

01:19:39 - 01:19:41
所以這是不作為，知道嗎？

01:19:41 - 01:19:42
這是不作為，很多人會搞混喔。

01:19:44 - 01:19:48
這一說如果你照前面謝玉偉老師的能量起訴說，其實也一樣。

01:19:49 - 01:19:50
來，翻回去。

01:19:51 - 01:19:52
你翻到那個397頁。

01:19:53 - 01:19:54
能量起訴說看什麼呢？

01:19:55 - 01:19:56
你看嘛。

01:19:56 - 01:19:58
讓法益狀態惡化是作為。

01:19:59 - 01:19:59
不讓法益

01:20:00 - 01:20:02
惡化中的法益好轉是不作為。

01:20:03 - 01:20:03
那是不是一樣的意思？

01:20:05 - 01:20:07
我倒在講臺上，心梗是快要死掉了。

01:20:08 - 01:20:13
然後同事把救護車輪胎刺破，或者把救難人員打傷，讓我無法及時配送。

01:20:14 - 01:20:15
他只是怎麼樣？

01:20:16 - 01:20:19
不讓我這個惡化中的生命狀態好轉，所以依然是什麼？

01:20:20 - 01:20:21
不作為嘛，對不對，沒有錯啊，所以這一種救難關係的阻斷。

01:20:25 - 01:20:31
照目前的說法，不管是新版的能量說，或者是風險關係說，他都屬於不作為。

01:20:31 - 01:20:34
當然啦，如果你採扁一下重點說的話，它是作為啦。

備註：???扁一下

01:20:34 - 01:20:36
但你說有問題吧，我不建議採，懂嗎？

01:20:36 - 01:20:38
所以這種案例是不作為喔。

01:20:39 - 01:20:41
所以到這裡有同學就會說，很混，很混亂。

01:20:43 - 01:20:44
為什麼是那個案例？

01:20:45 - 01:20:48
被害人拉到身所，我再把它放回去，說那個是作為。

01:20:49 - 01:20:55
那為什麼後面的案例，同樣都是救助關係的阻斷，為什麼後面就變成是不作為了。

01:20:55 - 01:20:56
重點在哪裡？

01:20:57 - 01:21:00
這個救助條件實際上啟動了沒有。

01:21:01 - 01:21:07
因為當救助條件實際啟動之後，其為人把它中斷掉的話，那會是怎麼樣？

01:21:08 - 01:21:13
讓被害人在受救助的狀態，變成沒有受救助的危險狀態。

01:21:14 - 01:21:15
所以這個一定是作為，知道嗎？

01:21:15 - 01:21:16
這個一定是作為。

01:21:16 - 01:21:20
可是當這個救助條件還沒有啟動的時候，

01:21:20 - 01:21:22
其為人就把它消滅掉。

01:21:23 - 01:21:24
那法益狀態沒有變啊。

01:21:25 - 01:21:27
他只是不讓法益好轉而已啊。

01:21:27 - 01:21:29
所以那個變成是不作為,知道嗎?

01:21:29 - 01:21:33
所以為什麼案例三,案例四,都是救助關係的阻斷。

01:21:33 - 01:21:34
為什麼一個是作為,一個是不作為?

01:21:35 - 01:21:36
因為這裡則是怎麼樣？

01:21:36 - 01:21:39
一個救助條件已經啟動了。

01:21:39 - 01:21:41
另外一個呢，還沒有啟動，知道吧？

01:21:41 - 01:21:42
差別在這邊喔，那個發現仇人按兵不動。

01:21:45 - 01:21:46
這幾年國考很常考，這個請同學多注意喔。

01:21:50 - 01:21:50
好。

01:21:51 - 01:21:55
所以這個398到399的內容，我就跳過不講了，我們剛口頭都談完了。

01:21:59 - 01:21:59
請看400頁。

01:22:01 - 01:22:03
我們來看到不純正不作為犯的構成要件。

01:22:16 - 01:22:17
不純正不作為犯幾個要件。

01:22:17 - 01:22:22
第一個我們講，要實現所有的成文不成文的構成要素，這個是一定的。

01:22:22 - 01:22:25
再來第二個叫做作為可能性。

01:22:26 - 01:22:29
同學啊，你不要把這個東西跟期待可能性混在一起。

01:22:30 - 01:22:37
期待可能性是說我們在規範的觀點來講，可不可以期待行為人不要這麼做，或者可不可以期待行為人要做點什麼事。

01:22:37 - 01:22:38
這個叫期待可能性。

01:22:39 - 01:22:49
作為可能性，它是純粹從物理上、從事實上的觀點去說，行為人實際上沒有救助的可能，這個叫作可能性，知道嗎？

01:22:49 - 01:22:52
它是純粹事實的認定，它不是規範的評價。

01:22:54 - 01:22:55
我舉一個有點年代感的案例。

01:22:56 - 01:22:57
叫做八掌溪事件。

01:22:58 - 01:22:59
我不知道同學們有沒有印象。

01:23:00 - 01:23:02
沒很正常，因為這個可能在你的出生之前。

01:23:02 - 01:23:03
2000年8月。

01:23:04 - 01:23:06
對，我記得應該是這個時候，2000年8月。

01:23:06 - 01:23:08
當時陳水扁第一次當總統。

01:23:09 - 01:23:11
那當時呢，八掌溪是這樣子，如果你們不知道的話，你們去搜尋圖片八掌溪事件。

01:23:15 - 01:23:20
當時啊,好像有四個工人在那個八掌溪的沙洲上面作業。

01:23:20 - 01:23:23
忽然午後雷陣雨,八掌溪暴漲。

01:23:23 - 01:23:27
四個工人受困河床當中的沙洲。

01:23:27 - 01:23:30
水來得又快又急,一直在沖刷。

01:23:30 - 01:23:33
那四個人就受困,四個人就緊緊抓著彼此。

01:23:33 - 01:23:34
一直在等直升機來救。

01:23:35 - 01:23:37
那當時中央跟地方一直推委責任。

01:23:38 - 01:23:42
就中央說地方你要派，地方說那個是中央的事。

01:23:42 - 01:23:42
就一直在推。

01:23:43 - 01:23:45
推到最後，直升機還沒有來。

01:23:45 - 01:23:46
四個人被沖走,後來都死掉了。

01:23:47 - 01:23:48
這個叫八掌溪事件,這個

01:23:51 - 01:23:52
2000年8月的事,7月還是8月啊,反正這一陣子的事啦。

01:23:55 - 01:23:56
當時這個事情發生之後啊,

01:23:57 - 01:23:59
我還記得一下很深刻。

01:23:59 - 01:23:59
當時連

01:24:00 - 01:24:02
前幾天新聞都在報這個事。

01:24:02 - 01:24:03
新聞傳回來的畫面，

01:24:03 - 01:24:06
這記者在八掌溪邊現場轉播，

01:24:06 - 01:24:10
看到那四個工人手牽著手受困河床，最後全部被沖走。

01:24:11 - 01:24:12
新聞就一直轉播這個畫面,

01:24:12 - 01:24:13
那你們想喔,

01:24:13 - 01:24:19
這四個工人的家屬在電視上看到他們的家人受困沙洲也很急,

01:24:20 - 01:24:21
可是沒辦法救。

01:24:22 - 01:24:23
或者是溪邊的記者也是,

01:24:23 - 01:24:25
他們也很想救，可是不能跳下去啊。

01:24:26 - 01:24:27
跳下去救就一起死啊。

01:24:27 - 01:24:30
那個河那麼深那麼急，對不對？

01:24:30 - 01:24:32
所以這個叫什麼呢？欠缺作為可能性。

01:24:33 - 01:24:33
就這種情況知道嗎？

01:24:34 - 01:24:37
你看到家人受困，你沒辦法去救他喔，這個叫欠缺作為可能性。

01:24:38 - 01:24:40
好，接著喔，不作為犯的因果關係。

01:24:41 - 01:24:42
這跟作為犯不一樣。

01:24:43 - 01:24:46
我們講作為犯的因果關係，非P則非Q，條件公式。

01:24:47 - 01:24:48
那個沒有問題。

01:24:49 - 01:24:50
好，你想作為犯喔。

01:24:51 - 01:24:52
我開槍打A，A中彈而死。

01:24:53 - 01:24:58
那我是不是可以很百分之百的說，我不要開槍打A，A就不會中彈而死？

01:24:58 - 01:24:59
對，百分之百，對吧？

01:25:00 - 01:25:01
可是不作為犯不是喔。

01:25:02 - 01:25:06
不作為犯的因果關係，永遠是用假設的。

01:25:07 - 01:25:10
因為我們就是在想，那如果他作為會怎麼樣？

01:25:10 - 01:25:11
對吧？

01:25:11 - 01:25:15
所以不作為犯的因果關係，永遠是一種假設狀態。

01:25:16 - 01:25:19
假設他作為那事情會有什麼發展。

01:25:19 - 01:25:25
所以我們說呢,不作為犯的因果關係,又叫擬制的因果關係。

01:25:25 - 01:25:28
或者又有人叫它假設的因果關係,

01:25:28 - 01:25:32
或者有些學者叫它準因果關係,都是一樣的意思。

01:25:33 - 01:25:35
你說啊,這個跟作為犯有什麼不同嗎?有,當然不一樣,

01:25:35 - 01:25:36
你們想一個例子。

01:25:38 - 01:25:40
那個，如果有一對父子相依為命，

01:25:41 - 01:25:42
爸爸年紀很大了，

01:25:42 - 01:25:45
那有一天這個爸爸突然在家裡心肌梗塞，

01:25:45 - 01:25:48
那兒子心想，照顧爸爸很累，不想就醫，

01:25:48 - 01:25:49
不想送醫。

01:25:49 - 01:25:52
就想說算了，就讓爸爸早點走吧，還可以早點繼承遺產。

01:25:53 - 01:25:54
所以兒子就沒有打119。

01:25:54 - 01:25:56
後來那個爸爸果真死在家裡。

01:25:56 - 01:25:57
各位，

01:25:58 - 01:25:59
這樣的案例當中，

01:26:00 - 01:26:03
你說兒子不打119跟爸爸的死亡有沒有非P則非Q的關係。

01:26:08 - 01:26:09
真的有嗎？

01:26:09 - 01:26:10
你怎麼知道？

01:26:11 - 01:26:12
這很難講啊，對不對？

01:26:13 - 01:26:18
你怎麼知道如果兒子有打119，爸爸就一定去得了，爸爸就一定救得活。

01:26:19 - 01:26:20
對啊,你怎麼知道?

01:26:21 - 01:26:24
你能保證救護車在路上一定不會出車禍嗎?

01:26:24 - 01:26:28
你能保證這個爸爸被送醫就醫就不會發生醫療疏失嗎?

01:26:28 - 01:26:30
機率很低沒有錯,但你怎麼保證?

01:26:30 - 01:26:31
瞭解這個意思吧?

01:26:31 - 01:26:33
所以我作為就是這樣。

01:26:33 - 01:26:38
因為我們是在假設，假設如果行為人有作為，事情會怎麼樣。

01:26:39 - 01:26:41
那你怎麼可能百分之百？

01:26:41 - 01:26:42
瞭解這個難題吧？

01:26:43 - 01:26:47
所以多數說對不作為犯的因果關係的判斷，才會認為說呢。

01:26:48 - 01:26:49
我們只要怎麼樣呢？

01:26:50 - 01:26:51
只要啊。

01:26:52 - 01:26:55
只要啊，盡可能地確定。

01:26:55 - 01:26:59
意思就是說，如果沒有意外的話，事情會怎麼發展。

01:27:00 - 01:27:01
只要到這個程度就夠了，知道嗎？

01:27:01 - 01:27:03
不需要到百分之百，不用啊。

01:27:03 - 01:27:06
需要達到一個所謂盡可能的確定，這個就夠了。

01:27:08 - 01:27:09
好，這是本質上的問題啊。

01:27:10 - 01:27:12
接著客觀規則，這個沒有什麼不同。

01:27:13 - 01:27:15
作為犯跟不作為犯的客觀歸責啊。

01:27:15 - 01:27:19
作為犯的第一階叫做製造法所不允許的風險。

01:27:19 - 01:27:22
那不作為犯的話，我們配合不作為的定義嘛。

01:27:22 - 01:27:23
所以第一就會變成什麼呢？

01:27:24 - 01:27:26
放任法所不允許的風險，一樣啊。

01:27:27 - 01:27:27
好。

01:27:27 - 01:27:30
那等價條款，這個是比較偏學者的問題啊。

01:27:30 - 01:27:32
意思就是說，在有些定型犯罪，我們要怎麼把不作為跟作為等價。

01:27:35 - 01:27:37
那個通常會展現在詐欺罪，我們到詐欺罪看到就知道的。

01:27:39 - 01:27:40
接著來第六點，保證人地位。

01:27:54 - 01:27:54
什麼叫保證人地位？

01:27:56 - 01:27:57
要成立不作為犯，必須不作為的行為人跟這個法律之間有某種關係。

01:27:57 - 01:27:59
這個叫保證人地位。

01:27:59 - 01:28:00
我前面講了，保證人地位這個保證人跟我們

01:28:00 - 01:28:03
在民法上說你人呆才做保，這個保證人沒有關係喔。

01:28:03 - 01:28:10
這個保證人地位，他講的就是不作為的人跟那個法益要有某種關聯性。

01:28:11 - 01:28:13
那個不作為的人才會成罪犯。

01:28:13 - 01:28:15
所以像我以前舉過一個例子，你想喔。

01:28:16 - 01:28:19
我經過火車站前面的地下道的時候。

01:28:20 - 01:28:23
我看到有個流浪漢，奄奄一息地在求救。

01:28:24 - 01:28:26
但我想幹我什麼事啊，他死死算了啦。

01:28:26 - 01:28:27
我就走掉了。

01:28:27 - 01:28:29
我算不算上人的不作為犯？

01:28:29 - 01:28:31
不算，因為我跟那個流浪漢沒有關係，對不對？

01:28:31 - 01:28:35
欸，可是如果那個流浪漢是我阿公的話，你覺得我這樣走掉會不會有事？

01:28:35 - 01:28:36
會，那個叫做保證人地位，你知道嗎？

01:28:37 - 01:28:40
或者，為什麼那個會倒在那邊一起啊？

01:28:40 - 01:28:42
因為我十分鐘之前跟他打架。

01:28:42 - 01:28:44
那我後面又不救他會不會有事？

01:28:45 - 01:28:46
會，這個叫做保證人地位，知道嗎？

01:28:47 - 01:28:53
好，所以保證人地位的意思就是說呢，行為人，那個不作為的人，要跟法益有某種關聯性，這個才算喔。

01:28:55 - 01:28:55
好。

01:28:56 - 01:28:59
那麼接下來，我們就來看保證人地位分成下面兩類。

01:29:00 - 01:29:03
保護型，還有監督型，分成這兩類。

01:29:04 - 01:29:05
我畫個圖。

01:30:33 - 01:30:34
好，我們來看什麼，保證人的地位分這兩類，保護型還有監督型，各是什麼意思？

01:30:39 - 01:30:40
保護型，你看這個圖啊，

01:30:41 - 01:30:42
保護型的意思是，

01:30:42 - 01:30:44
這個法義，它相對脆弱，

01:30:44 - 01:30:46
容易遭受外來危險的侵害，

01:30:46 - 01:30:50
所以行為人的責任就是要保護好這個法益，

01:30:50 - 01:30:53
不要讓這個法益遭受外來危險的侵害，

01:30:53 - 01:30:55
這個叫做保護型。

01:30:55 - 01:30:57
那接著另外一類叫做監督型，

01:30:57 - 01:31:00
監督型是什麼，行為人手上領

01:32:00 - 01:32:00
有一個危險源。

01:32:00 - 01:32:08
這個危險源可能會去侵害別人，所以行為人要做的事情，就是控管好這個危險源，不要讓這個危險源去侵害別人，這一種叫做監督型，我們分成這兩種，所以這個圖應該看得出來。

01:32:15 - 01:32:19
我畫這個監督型的時候，有同學說這個圖很像病毒。

01:32:19 - 01:32:20
我說對，真的有點像。

01:32:21 - 01:32:23
有人喜歡病毒，我覺得病毒很美。

01:32:23 - 01:32:26
真的啊，我後揹包上掉一顆病毒啊，有些同學可能都看過。

01:32:27 - 01:32:28
這個，到我覺得病毒很美。

01:32:28 - 01:32:29
好像都不覺得。

01:32:30 - 01:32:32
我覺得美好像都跟通說不一樣。

01:32:32 - 01:32:34
美都是那種少數說的。

01:32:35 - 01:32:37
好，我們來看一下保護型的部分。

01:32:39 - 01:32:41
在保護型這邊,402頁。

01:32:42 - 01:32:43
保護型的保證會帶有這些。

01:32:43 - 01:32:44
第一個是法律規定。

01:32:45 - 01:32:51
像比如說民法說，父母對未成年子女有保護教養的權利義務，OK，這是一種保護型，沒有疑問。

01:32:53 - 01:32:57
再來，像是你看哦，船長對於罹難漁末者的救助義務。

01:32:57 - 01:33:00
兩層以上建築物施工時的防止。

01:33:00 - 01:33:00
等等。

01:33:00 - 01:33:03
這種東西呢,叫做法律規定,這個比較沒有疑問。

01:33:04 - 01:33:08
再來第二個叫做生活共同體,或者是危險共同體。

01:33:11 - 01:33:12
我們來講說什麼叫生活共同體。

01:33:14 - 01:33:16
生活共同體的意思是。

01:33:16 - 01:33:19
這些人，他們住在一起。

01:33:19 - 01:33:24
而且這些人住在一起的時候，他們有精神上的扶持。

01:33:25 - 01:33:26
這才要生活共同體。

01:33:26 - 01:33:27
單純住一起不算喔。

01:33:28 - 01:33:30
要有精神上的扶持才算。

01:33:30 - 01:33:33
所以像家人之間，這個算。

01:33:33 - 01:33:36
還有呢，同居情侶之間，這個也可以算。

01:33:38 - 01:33:39
宿舍的室友不算。

01:33:40 - 01:33:42
因為那個只是學校偶然的安排而已。

01:33:43 - 01:33:45
一夜情的男女也不算。

01:33:45 - 01:33:46
那個叫各取所需，那個也不算。

01:33:47 - 01:33:49
監獄的獄友算不算？

01:33:50 - 01:33:53
如果柯文哲的獄友倒在那邊口吐白沫。

01:33:54 - 01:33:56
但柯文哲跟這個獄友關係不好。

01:33:56 - 01:33:58
所以柯文哲說對我是醫生，但我就不想救你，怎麼樣？

01:33:59 - 01:33:59
對吧。

01:34:00 - 01:34:03
如果是這樣子的話，柯文哲保證人的地位就沒有。

01:34:03 - 01:34:05
監獄的約友就是一種室友嘛。

01:34:05 - 01:34:06
他們會住在一起。

01:34:07 - 01:34:08
那就只是偶然嘛。

01:34:08 - 01:34:10
可能就只是偶然而已啊。

01:34:10 - 01:34:11
這個預防的安排吧。

01:34:12 - 01:34:13
聽說在監獄裡面,

01:34:14 - 01:34:15
看守所啦。

01:34:15 - 01:34:19
聽說有些跟主管關係不錯的犯人，他們可以挑獄友。

01:34:19 - 01:34:20
真的啊，可以挑啊。

01:34:20 - 01:34:22
就是他們不想跟瘋子關在一起。

01:34:22 - 01:34:23
有，他們聽說是這樣子。

01:34:23 - 01:34:26
聽說像那種規模比較大的，像比如說北所。

01:34:26 - 01:34:31
北所的話，他們預，就是寢室的安排會有一些規則啦。

01:34:31 - 01:34:35
比如說，他們的潛規則就是說不同幫派的不會關在一起。

01:34:35 - 01:34:37
四海跟竹聯關一起，他們整天打架。

01:34:37 - 01:34:39
所以不同幫派不會關在一起。

01:34:40 - 01:34:41
然後那種容易被欺負的人，

01:34:42 - 01:34:43
性侵犯會關保護室。

01:34:44 - 01:34:45
他們會有一些這樣的潛規則。

01:34:45 - 01:34:48
然後，然後這個，對啊，然後那個，

01:34:49 - 01:34:51
他們有些，我聽裡面的人講很多了。

01:34:51 - 01:34:54
然後你們知道嗎，監所裡面的衛生條件很差。

01:34:55 - 01:34:57
關在裡面被老鼠咬很常見。

01:34:58 - 01:34:59
真的，我遇過不止一次。

01:35:00 - 01:35:01
被告被老鼠咬。

01:35:02 - 01:35:06
所以，你說監所裡面的被告如果被老鼠咬，

01:35:06 - 01:35:08
同房的獄友要不要去救他？

01:35:08 - 01:35:08
不用啦。

01:35:09 - 01:35:11
這並不是所謂的生活共同體。

01:35:11 - 01:35:12
好。

01:35:12 - 01:35:13
再來，危險共同體。

01:35:14 - 01:35:17
一起從事危險行為的人，

01:35:17 - 01:35:21
一起爬山，一起攀巖，一起泛舟。

01:35:21 - 01:35:24
這一種我們叫做危險共同體。

01:35:24 - 01:35:25
好，這個叫危險共同體。

01:35:26 - 01:35:26
好。

01:35:27 - 01:35:30
那就危險共同體，括號二，這個東西來講。

01:35:31 - 01:35:36
危險共同體呢,要限於一同從事合法活動的人,這個才算喔。

01:35:37 - 01:35:39
違法行為的共同參與者,

01:35:39 - 01:35:41
這個不叫做危險共同體喔。

01:35:41 - 01:35:46
因為學理上的說法是,如果違法行為的參與者,他們算危險共同體的話,

01:35:47 - 01:35:48
比如說一群毒蟲們,

01:35:49 - 01:35:50
他們算危險共同體。

01:35:50 - 01:35:53
那有人吸食過量口吐白沫,別人要救他。

01:35:54 - 01:35:56
那這樣不是讓這群毒蟲的感情更穩固嗎?

01:35:56 - 01:35:58
法律不會做這樣的要求。

01:35:58 - 01:36:00
所以危險共同體呢,要是共同從事。

01:36:00 - 01:36:02
這個合法行為,這個才算。

01:36:02 - 01:36:05
好,第三個叫做自願承擔保護義務。

01:36:06 - 01:36:09
這個東西又叫做事實上的承擔。

01:36:10 - 01:36:12
所以比如說保姆對嬰幼兒,

01:36:13 - 01:36:15
救生員對泳客這一種,

01:36:15 - 01:36:20
有事實上的承擔的，這一種東西呢，叫做自願承擔保護義務。

01:36:21 - 01:36:25
這個傳統的教科書啊，在講到這一類的時候，

01:36:26 - 01:36:32
我講的是更早以前的，像蔡敦銘老師他們那一輩的教科書，他們在提到這個保護保證義務的時候啊，

01:36:32 - 01:36:34
他們可能會講契約的約定。

01:36:35 - 01:36:37
但現在的書已經放棄這個說法了。

01:36:37 - 01:36:38
現在不會講契約約定,

01:36:39 - 01:36:40
現在就會講事實上承擔,

01:36:40 - 01:36:41
為什麼呢?

01:36:42 - 01:36:45
因為你講契約約定的話,

01:36:46 - 01:36:48
那如果這個保姆她未成年,

01:36:49 - 01:36:52
或者這個保母可能他受監護宣告或輔助宣告之類的,

01:36:53 - 01:36:55
那他所締結的契約不是效力有問題嗎?

01:36:55 - 01:36:56
瞭解吧?

01:36:56 - 01:36:59
所以現在的說法,重點不是這個契約有沒有成立生效,

01:36:59 - 01:37:09
重點是

01:37:09 - 01:37:42
有沒有事實上的承擔。

備註：事實上的承擔，締結契約的話，保母如果未成年

01:37:43 - 01:37:45
我還記得我大一的時候啊，刑總老師在說，

01:37:45 - 01:37:49
說這個，說這個同學們啊，他講，

01:37:49 - 01:37:56
他說那個，那個什麼，游泳池的救生員對泳客有救助的義務。

01:37:57 - 01:38:00
當時老師的說法是有契約關係存在。

01:38:00 - 01:38:01
那種免費展。

01:38:01 - 01:38:03
幫搶進去游泳的人溺水了。

01:38:04 - 01:38:05
就是沒法救他。

01:38:05 - 01:38:05
要救。

01:38:05 - 01:38:07
因為重點不是契約關係。

01:38:07 - 01:38:08
重點是事實上承擔。

01:38:08 - 01:38:09
瞭解吧。

01:38:10 - 01:38:12
你如果要講契約關係的話。

01:38:13 - 01:38:13
欸。

01:38:14 - 01:38:15
那你們從民法的觀點想一想。

01:38:17 - 01:38:19
游泳池的泳客。

01:38:19 - 01:38:21
他的契約關係也不是跟救生員定的啊。

01:38:22 - 01:38:23
他是跟泳池的業者定的啊。

01:38:24 - 01:38:26
救生員只是泳池的那個服務人員啊。

01:38:26 - 01:38:27
對不對。

01:38:27 - 01:38:29
所以重點不是契約關係是否成立生效，不是喔。

01:38:30 - 01:38:30
好。

01:38:30 - 01:38:31
再來關號人。

01:38:32 - 01:38:34
必須要現實控管風險。

01:38:35 - 01:38:37
保證人地位才會發生喔。

01:38:37 - 01:38:38
要現實控管才算喔。

01:38:39 - 01:38:41
口頭的承諾不算喔。

01:38:42 - 01:38:43
口頭承諾不算喔。

01:38:43 - 01:38:47
所以那一群人去爬山，他們要找李隊。

01:38:48 - 01:38:52
結果啊，當天清晨，李隊的電話一直打不通，沒有人接。

01:38:53 - 01:38:56
這群人想，算了啦，他可能睡過頭了，我們自己去爬好了。

01:38:57 - 01:38:58
結果後來發生山難。

01:38:59 - 01:39:01
那個睡過頭的李隊有沒有刑責啊。

01:39:01 - 01:39:03
沒有啊，口頭講不算喔。

01:39:03 - 01:39:06
他們並沒有真的落實控管風險，這個不算。

01:39:07 - 01:39:09
可是有一種情況不一樣，來看他關號的後面。

01:39:11 - 01:39:11
後面說。

01:39:11 - 01:39:16
可是如果行為已經透過一個行為創造他人的合理信賴，

01:39:16 - 01:39:19
以至於他人捨棄法益的話呢？

01:39:19 - 01:39:22
這時候啊，就不是隻是說說而已喔。

01:39:22 - 01:39:24
我們講，常舉的一個例子是這樣。

01:39:25 - 01:39:25
那個。

01:39:27 - 01:39:27
父母啊。

01:39:28 - 01:39:32
他們把家裡的鑰匙給了同社區的保母。

01:39:33 - 01:39:37
那這一對夫妻的說法是，我們8點會出門上班。

01:39:37 - 01:39:41
那我們上班離開之後，你就拿鑰匙進來，幫我們照顧嬰兒。

01:39:42 - 01:39:43
這對夫妻是這樣做。

01:39:43 - 01:39:46
那他們跟保姆可能也合作了一段時間了。

01:39:46 - 01:39:48
結果有一天，夫妻如同往常的去上班。

01:39:51 - 01:39:53
結果保姆睡過頭。

01:39:53 - 01:39:55
睡到12點才到他們家。

01:39:55 - 01:39:57
結果到他們家呢,嬰兒在家裡出事了。

01:39:58 - 01:40:00
這時候保姆,他就領...

01:40:00 - 01:40:01
不是純粹的口頭承擔喔,

01:40:01 - 01:40:03
因為他跟這對夫妻已經合作很久,

01:40:03 - 01:40:05
而且甚至還有他們家的鑰匙。

01:40:05 - 01:40:08
這種情況的話，就不是單純的口頭承諾而已了，知道吧？

01:40:08 - 01:40:11
所以這種情況的話，還是附有保障的地位。

01:40:12 - 01:40:13
好，再來括號三，

01:40:13 - 01:40:20
事實上承擔除了要承擔之外，還必須這個承擔在客觀上有一個合理的信賴關係存在。

01:40:20 - 01:40:21
你想喔，

01:40:22 - 01:40:23
社區的泳池

01:40:24 - 01:40:25
家長帶小孩去玩水

01:40:26 - 01:40:27
當時救生員不在

01:40:28 - 01:40:31
那家長就跟那個社區的清潔阿姨說

01:40:31 - 01:40:34
那我買個菜，小孩你顧一下喔

01:40:34 - 01:40:35
清潔阿姨說好，

01:40:36 - 01:40:37
結果啊，小孩突然溺水，

01:40:38 - 01:40:40
清潔阿姨也不會游泳啊，

01:40:40 - 01:40:42
只能眼睜睜看那個小孩溺水，

01:40:43 - 01:40:45
這時候清潔阿姨有沒有保證人地位啊？

01:40:45 - 01:40:46
沒有喔,

01:40:46 - 01:40:49
因為他雖然事實上做一個承擔的承諾沒有錯,

01:40:50 - 01:40:53
可是那個承擔,那個承諾根本就不合理,

01:40:53 - 01:40:56
你怎麼期待一個清潔人員去救溺水的人呢,

01:40:56 - 01:40:59
所以這個東西並不算是在事實上承擔。

01:41:41 - 01:41:43
好，我們翻到第404頁，看到這個題目。

01:42:01 - 01:42:04
來，僱主對外傭。

01:42:05 - 01:42:06
你說算哪一種保證人地位？

01:42:08 - 01:42:10
可不可以算生活共同體？

01:42:11 - 01:42:12
我認為不算啊。

01:42:12 - 01:42:13
對,我認為不算,為什麼?

01:42:14 - 01:42:17
照顧老人的外傭會住在僱主家。

01:42:18 - 01:42:20
那是為了服務老人的方便。

01:42:21 - 01:42:23
而不是把他們當作一家人。

01:42:23 - 01:42:24
瞭解吧?

01:42:24 - 01:42:27
就像如果你家有外傭的話，你想一想。

01:42:28 - 01:42:29
你覺得你跟那個外傭的關係。

01:42:30 - 01:42:34
他比較像是你的室友，還是比較像你的姐姐？

01:42:35 - 01:42:37
如果你覺得像姐姐的話，那是你們的感情特別好，這應該不是常態。

01:42:38 - 01:42:40
正常來說一般人應該會覺得說就是室友，瞭解吧？

01:42:41 - 01:42:42
所以那個不是生活共同體。

01:42:43 - 01:42:44
那有沒有事實上承擔？

01:42:46 - 01:42:46
搞清楚喔。

01:42:47 - 01:42:49
是外傭對老人有事實上承擔喔。

01:42:49 - 01:42:51
不是僱主對外傭有事實上承擔喔，知道吧？

01:42:52 - 01:42:55
所以這題我會認為沒有保證人地位，就是沒有，知道嗎？

01:42:56 - 01:42:58
所以保證人地位的功能就在這邊。

01:42:58 - 01:43:00
你說好，可是只有甲的。

01:43:00 - 01:43:01
就為甲，不就沒事嗎？

01:43:02 - 01:43:03
那他沒有關聯性，幹嘛救人家？

01:43:04 - 01:43:04
所以這個意思啊。

01:43:05 - 01:43:06
或者舉一個更極端的案例。

01:43:06 - 01:43:08
假設我獨居在深山。

01:43:09 - 01:43:11
有一天半夜，有個登山客狂按我的門鈴。

01:43:12 - 01:43:13
他在外面呼救。

01:43:13 - 01:43:16
說他被雨傘節，他被那個百步蛇咬到。

01:43:17 - 01:43:19
說他已經走了八十幾步了。

01:43:19 - 01:43:20
他快要掛了，希望我趕快去救他。

01:43:21 - 01:43:22
然後我就回他說：

01:43:22 - 01:43:23
被百步蛇咬到！

01:43:23 - 01:43:27
你走了80幾步，你還有20幾步的空間，那你再多被他咬一口啊，你就可以再多100步的空間啊，我就用這個幹話去回他。

01:43:33 - 01:43:34
然後後來他就死了。

01:43:34 - 01:43:35
各位。

01:43:35 - 01:43:36
這樣案例當中。

01:43:38 - 01:43:39
沒錯，只有我能救。

01:43:40 - 01:43:41
啊我又沒有去救他。

01:43:42 - 01:43:43
所以我要負責嗎？

01:43:44 - 01:43:45
要幹我什麼事，那百步蛇又不是我放的，對不對？

01:43:47 - 01:43:49
對啊，我跟他又沒有保證地位。

01:43:50 - 01:43:51
所以保證地位在這裡。

01:43:51 - 01:43:56
並不會說你能救，而你不救，你就成立犯罪，不會，重點是要有那個關聯性，知道吧？

01:43:59 - 01:43:59
好。

01:43:59 - 01:44:00
所以

01:44:00 - 01:44:01
這個是第一類，保護型。

01:44:02 - 01:44:05
再來第二類叫做監督型。

01:44:05 - 01:44:07
我們來看一下監督型有哪些呢？

01:44:08 - 01:44:10
第一個叫做危險源的監督。

01:44:11 - 01:44:14
那個危險源，可能是人，也可能是物。

01:44:15 - 01:44:18
比如說呢，精神病院。

01:44:18 - 01:44:21
就是這種，這應該也算是一種長照機構啦。

01:44:21 - 01:44:26
精神病院的管理者，對裡面有攻擊性的精神病患

01:44:26 - 01:44:29
負有這種危險源監督的責任。

01:44:29 - 01:44:30
這種就有。

01:44:30 - 01:44:33
像以前那個龍發堂，同學有聽過嗎？

01:44:33 - 01:44:37
那個在高雄，那個算路竹還是湖內啊，就北高雄那邊。

01:44:37 - 01:44:42
以前有一個叫龍發堂的地方，專門收容思覺失調症的病患。

01:44:43 - 01:44:44
像這種機構的管理者。

01:44:44 - 01:44:48
他就會對裡面的精神病患負有監督的義務。

01:44:48 - 01:44:51
還有呢，家長對小孩。

01:44:51 - 01:44:54
各位啊，家長對小孩是兩種義務都有哦。

01:44:55 - 01:44:58
他有義務保護小孩免於遭受危險。

01:44:58 - 01:45:02
他也有義務要控管這個小孩，讓小孩不要去侵害別人。

01:45:03 - 01:45:04
兩個都有，知道嗎？

01:45:05 - 01:45:08
這個恐龍家長，會認為他沒有後面這一種。

01:45:08 - 01:45:09
真的啊。

01:45:09 - 01:45:16
我有時候看網路上，都會覺得有些家長好像生了小孩之後就覺得自己好像吃了什麼無敵星星一樣，整個社會都欠他欸，真的啊。

01:45:16 - 01:45:19
就放任小孩在店裡跑來跑去大吵大鬧。

01:45:19 - 01:45:21
然後有人對他小孩有意見。

01:45:21 - 01:45:22
大家就要開大絕。

01:45:22 - 01:45:24
然後說你們沒有同理心。

01:45:24 - 01:45:25
你們要包容小孩，你們包容小孩。

01:45:25 - 01:45:28
你們就是社會少子化的元兇，因為你都會講這種東西。

01:45:28 - 01:45:29
奇怪吼。

01:45:30 - 01:45:32
父母對小孩有保護義務沒有錯。

01:45:32 - 01:45:33
他不用監督喔。

01:45:33 - 01:45:36
小孩吵到別人，那是你們缺乏同理心。

01:45:36 - 01:45:37
你怎麼會這樣認定呢？

01:45:37 - 01:45:40
所以我們講，父母對小孩兩個義務都有。

01:45:40 - 01:45:42
既有保護，也有監督。

01:45:44 - 01:45:45
好，不管是哪一種。

01:45:46 - 01:45:47
我們講啊。

01:45:48 - 01:45:50
監督型的保證人地位，

01:45:51 - 01:45:51
繫於什麼呢？

01:45:52 - 01:45:54
這個危險

01:45:54 - 01:45:58
是由這個人或這個物本身所帶來的才算。

01:45:59 - 01:46:00
反過來說。

01:46:00 - 01:46:04
如果只是這個物，偶然成為別人的犯罪工具。

01:46:04 - 01:46:07
這時候行為人，他並不負有清除的義務喔。

01:46:09 - 01:46:11
比如說，你的牆壁被別人噴漆。

01:46:12 - 01:46:14
噴的漆是妨礙別人名譽的言論。

01:46:15 - 01:46:17
那你不會有消滅的義務。

01:46:17 - 01:46:20
因為那個叫做物，偶然成為別人的犯罪工具。

01:46:21 - 01:46:26
我記得我小的時候啊，那時候有一天晚上，我媽媽陪我去上那個長期補美語。

01:46:26 - 01:46:27
我想說治安很差嘛。

01:46:27 - 01:46:30
那個時候一堆綁架案啊，所以這個時候。

01:46:30 - 01:46:34
我媽都會陪我去，帶我一起去上這個美語補習班。

01:46:35 - 01:46:44
當時我還記得，當時我路過我家附近一戶公寓的一樓，我看到人噴漆，寫「成立俠欠錢不還」，我還記得，成立俠欠錢不還，我覺得很有趣，啊原來成立俠欠錢不還哦。

01:46:49 - 01:46:50
兩個多小時後，回來了。

01:46:52 - 01:46:55
我就看到那個牆壁好像被洗過。

01:46:55 - 01:46:58
我媽講說，那個「成立俠欠錢不還」怎麼不見了。

01:46:59 - 01:47:05
起初我就看到有一個中年人，一手拿著水管，一手拿著這個刷子啊，用不太友善的眼神看著我們母子。

01:47:05 - 01:47:08
我當下瞬間懂了，他可能就是陳立俠本人。

01:47:09 - 01:47:10
我覺得很尷尬。

01:47:10 - 01:47:10
來各位。

01:47:11 - 01:47:15
這樣的案例當中，來假設是你家的牆壁被噴這個漆。

01:47:15 - 01:47:17
你有沒有消除的義務？

01:47:17 - 01:47:20
沒有啊，這個叫做物，偶然成為別人的犯罪工具。

01:47:22 - 01:47:25
我記得以前發生過這麼一件事。

01:47:26 - 01:47:27
在有臉書之前。

01:47:28 - 01:47:30
我大學的時候啦，臉書是我大學。

01:47:30 - 01:47:31
我大學後半段才出來的啦。

01:47:31 - 01:47:34
在我大學的前半段，當時是流行無名小站。

01:47:35 - 01:47:37
這個年輕的同學可能沒有經歷過無名小站那個年代。

01:47:38 - 01:47:41
我當時在無名小站上面寫的一系列法律系轉學考的文章。

01:47:41 - 01:47:42
因為我是轉學生嘛。

01:47:42 - 01:47:44
我就還蠻鼓勵同學來考的。

01:47:44 - 01:47:45
我就寫這樣的文，就講說。

01:47:45 - 01:47:48
法律轉學考可能會考什麼東西，就是寫這些東西。

01:47:50 - 01:47:51
偶爾啊。

01:47:51 - 01:47:52
會有人來亂，對。

01:47:52 - 01:47:54
偶爾會有人來亂。

01:47:54 - 01:47:59
像比如說偶爾會有人在下面嗆說，你們法律人就是什麼人寫的。

01:48:00 - 01:48:00
法律系的人，都廢除死刑什麼的，就偶爾會這種人來亂。

01:48:03 - 01:48:05
然後還有一次，超莫名。

01:48:06 - 01:48:10
那個人不知道跟我們法律系某一位李老師有什麼仇恨。

01:48:10 - 01:48:14
他就在我的臉書上面，臉書在我的無名下面留言。

01:48:14 - 01:48:18
他說我們的某一位女老師啊，在研究室跟男學生打炮。

01:48:18 - 01:48:23
然後還講說什麼，她多淫蕩什麼的，還公佈她的個資、她的車牌號碼。

01:48:23 - 01:48:29
最後還留言說，我也好想考上東吳法律系喔，這樣就可以跟這個淫蕩的女老師做愛的，就留這樣的言。

01:48:31 - 01:48:33
我想說奇怪，他跟老師到底有什麼仇恨。

01:48:33 - 01:48:35
所以我看到之後我就把它刪掉了。

01:48:35 - 01:48:38
我當時是覺得我跟那個女老師也沒有仇。

01:48:38 - 01:48:41
我不希望這個言論被繼續流傳，我就把它刪掉。

01:48:41 - 01:48:44
但其實在法律上來說，我沒有刪除的義務啊。

01:48:45 - 01:48:47
因為這跟我原本的原文舉止沒有關係啊。

01:48:48 - 01:48:53
這就是我所控管的電子記錄，偶然成為別人的犯罪工具嘛，對不對？

01:48:53 - 01:48:56
其實我沒有義務刪啊，還是把它刪掉，我現在如果是什麼瘋子。

01:48:58 - 01:49:00
好，所以我們講，這個叫做危險。

01:49:00 - 01:49:00
介入。

01:49:01 - 01:49:03
再來第二個叫做商品製造人責任。

01:49:04 - 01:49:09
也就是行為人所製造出來的商品，他有加害別人的危險。

01:49:09 - 01:49:14
比如說食品有食安的疑慮，車子會暴衝，電腦會爆炸，這一種。

01:49:14 - 01:49:17
那出賣人負有收回的義務，這個是我們這邊講的第二點：

01:49:17 - 01:49:19
商品製造人責任。

01:49:20 - 01:49:22
再來第三個，叫做危險前行為。

01:49:24 - 01:49:25
嗯。

01:49:25 - 01:49:26
講了這麼多保證人義務。

01:49:27 - 01:49:29
你有沒有發現前面那些都沒有法律規定。

01:49:29 - 01:49:30
對，沒錯。

01:49:30 - 01:49:33
因為通說認為保證人義務不需要法律的直接明文。

01:49:34 - 01:49:36
法理上承認的也算。

01:49:37 - 01:49:38
對，法理上承認的也算。

01:49:38 - 01:49:41
那你說這個沒有罪刑法律的問題嗎？

01:49:41 - 01:49:43
好像大家就是存而不論這樣子。

01:49:43 - 01:49:46
對啊，這個就好像我們前面講，作為跟不作為的區分。

01:49:47 - 01:49:49
通說採評價重點說。

01:49:49 - 01:49:52
那我就說評價重點說，他會有虛幻論證的疑慮。

01:49:52 - 01:49:53
那我記得

01:49:54 - 01:49:57
我今年寒假跟以前我的指導老師吃飯聊天。

01:49:57 - 01:49:59
我就問老師說那這個評價重點。

01:50:00 - 01:50:02
邏輯上已經被批評是循環論證，

01:50:02 - 01:50:03
難道大家都沒有放棄嗎？

01:50:03 - 01:50:05
老實說沒有啊，在德國他還是在用啊，

01:50:05 - 01:50:06
對啊，所以很多問題就是，

01:50:06 - 01:50:09
它是個問題，可是好像大家都裝作沒看到，視而不見。

01:50:10 - 01:50:13
就是有一個比喻叫做房間裡的大象，有沒有聽過嗎？

01:50:14 - 01:50:16
意思就是說這個問題其實很明顯，大家都知道，

01:50:17 - 01:50:19
但大家就當作它不存在。

01:50:20 - 01:50:25
所以我覺得不作為犯的保證人地位，其實也是類似像我們所謂房間裡的大象這種東西吧。

01:50:25 - 01:50:25
就是，

01:50:26 - 01:50:29
我們在法無明文的情況之下，就說你有這個義務，

01:50:30 - 01:50:31
那沒有罪刑法定問題嗎？

01:50:31 - 01:50:33
對啊，一直有學者提出這個質疑啊，

01:50:33 - 01:50:36
可是通說就不管它，就繼續當作它不存在啊。

01:50:37 - 01:50:38
所以這裡我們來看，

01:50:39 - 01:50:40
這麼多保證人地位當中,

01:50:40 - 01:50:44
真的啦,刑法唯一有規定的,就是15條第二項,

01:50:44 - 01:50:45
就是危險前行為,

01:50:46 - 01:50:48
所以我們來看一下,危險前行為是什麼意思?

01:50:49 - 01:50:52
他的思考很簡單,跟我們一般人的法感很像。

01:50:53 - 01:50:55
就是說呢，危險是誰製造的，

01:50:55 - 01:50:59
這個製造危險的人，就有控管危險的義務。

01:51:01 - 01:51:04
你造成的危險，那你就要去收拾它，

01:51:04 - 01:51:05
就是這個想法。

01:51:06 - 01:51:07
這跟我們一般的法感差不多啊。

01:51:07 - 01:51:10
這好像你想的，如果你來補習班，

01:51:11 - 01:51:14
你到了原本你畫定的座位，

01:51:14 - 01:51:17
結果你一打開，你把椅子拉開，

01:51:18 - 01:51:22
你發現椅子濕濕的，感覺有一杯剛打翻的奶茶。

01:51:22 - 01:51:23
你看到會有什麼想法？

01:51:24 - 01:51:28
你一定第一個想法是，誰那麼沒水準，打翻飲料為什麼不擦乾淨？

01:51:29 - 01:51:31
你第一個想法應該是這個吧，對不對？

01:51:31 - 01:51:34
你第二個想法應該不是說，這是什麼爛補習班，怎麼那麼髒。

01:51:35 - 01:51:37
如果你有後面那個想法先冒出來，那可能是你跟補習班有糾紛。

01:51:38 - 01:51:40
不然正常人應該是想說這是誰打翻的，為什麼不清？

01:51:40 - 01:51:45
沒錯,所以我們一般人的想法會覺得說,製造危險的人,就應該消除它。

01:51:46 - 01:51:47
危險前行為就是這個想法。

01:51:47 - 01:51:51
所以你看哦,實務上面的案例,

01:51:52 - 01:51:54
把槍借給別人玩,

01:51:55 - 01:51:56
結果別人玩槍的時候啊,走火,

01:51:57 - 01:51:59
那個人被打死，危險行為。

01:52:00 - 01:52:00
還有呢，在池塘邊追人。

01:52:02 - 01:52:05
那個人掉下去呼救，啊你卻不去救他。

01:52:06 - 01:52:07
這也是危險行為。

01:52:07 - 01:52:12
還有啊，在飯鍋中下毒，原本要毒A，B來吃呢。

01:52:13 - 01:52:16
行為人怕事情敗露啊,沒有毒死,後來B也死掉了。

01:52:16 - 01:52:18
這些都是危險前行為的案例。

01:52:18 - 01:52:21
簡單說,誰製造的危險。

01:52:21 - 01:52:23
誰要去收拾它。

01:52:23 - 01:52:24
這個叫做危險前行為。

01:52:24 - 01:52:26
好，這是他基本的意思。

01:52:26 - 01:52:29
學說真摯的部分，我們先休息一下。

01:52:29 - 01:52:32
等一下呢，我們再來看後面的這幾說。

01:52:32 - 01:52:33
我們就看到這邊。

01:52:33 - 01:52:35
黑板不用擦，黑板幫我留著，不用擦。

01:52:36 - 01:52:37
好，我們先休息一下。

01:52:42 - 01:52:47
好，我們繼續回來看到406頁的括號二，危險前行為的學說爭議。

01:52:48 - 01:52:51
來，這個危險前行為，一直以來存在的一個爭議是。

01:52:51 - 01:52:54
那個危險前行為要不要多限制。

01:52:54 - 01:52:59
是說一切引起法益危險的行為都叫做危險前行為嗎？

01:52:59 - 01:53:04
還是說這個行為除了有危險之外，行為人也要做錯事呢？

01:53:05 - 01:53:06
來，這兩說這個意思。

01:53:06 - 01:53:08
因果前行為就是不設限。

01:53:09 - 01:53:12
所有一切造成法益危險的行為，

01:53:13 - 01:53:15
都叫做危險前行為。

01:53:16 - 01:53:17
這個是第一說。

01:53:17 - 01:53:18
知道嗎，像因果先行行為就是不設限。

01:53:18 - 01:53:20
一切，管你有沒有做錯事。

01:53:20 - 01:53:22
反正你造成法益的危險。

01:53:22 - 01:53:24
你就有收拾的義務，這個叫做因果先行行為。

01:53:26 - 01:53:28
再來第二說啊，圈圈二。

01:53:28 - 01:53:32
圈圈二這個說法叫做違背義務前行為。

01:53:33 - 01:53:34
圈圈二這說的是什麼意思呢？

01:53:35 - 01:53:36
所謂違背義務是指什麼？

01:53:37 - 01:53:37
有做錯事嗎？

01:53:38 - 01:53:44
所以圈圈二這說的意思就是說，只有在行為人有過錯的引發別人法益危險的時候。

01:53:44 - 01:53:47
行為人才會負有收拾的義務，這是第二說，叫做違背義務的前行為。

01:53:47 - 01:53:48
好。

01:53:48 - 01:53:52
這兩說差別在哪裡，你看哦，有三種不同的狀況。

01:53:55 - 01:53:56
第一個是說。

01:53:56 - 01:54:00
如果是無過失引起別人的

01:54:00 - 01:54:00
法益危險。

01:54:00 - 01:54:01
那要不要救？

01:54:03 - 01:54:03
比如說。

01:54:04 - 01:54:07
如果你在河濱騎腳踏車。

01:54:08 - 01:54:15
然後突然有個屁孩從樹叢後面穿出來，衝過來，你根本閃不掉，你把他撞倒。

01:54:15 - 01:54:17
假設有這樣的情景。

01:54:17 - 01:54:19
河濱騎腳踏車的同學應該都有這種經驗吧。

01:54:19 - 01:54:20
應該都有吧，這個

01:54:21 - 01:54:22
我有幾次。

01:54:23 - 01:54:24
還蠻多次喔。

01:54:24 - 01:54:27
我下課之後從這邊騎腳踏車回我家。

01:54:27 - 01:54:28
對，大概騎一個小時。

01:54:28 - 01:54:29
騎河濱。

01:54:30 - 01:54:31
騎一個小時，因為

01:54:31 - 01:54:34
今天可能不行，我怕回去會下雨，不然我真的

01:54:34 - 01:54:38
去年還滿多次就是這邊下課之後我騎腳踏車回去，滿舒服的啦。

01:54:38 - 01:54:41
就除非真的很熱，不然我覺得還滿舒服的。

01:54:41 - 01:54:46
因為我上這個課，我晚上回到家，我一定不會去慢跑。

01:54:47 - 01:54:51
那與其坐在電腦前面，我覺得我不如就乾脆騎車回去。

01:54:51 - 01:54:53
就通勤間運動，有時候真的會這樣子。

01:54:54 - 01:54:57
好，如果你騎腳踏車在河濱，就突然有小屁孩

01:54:57 - 01:54:59
從這個樹叢竄出來啊，你根本閃不掉。

01:54:59 - 01:55:02
你就把它撞倒，你也倒了啊。

01:55:02 - 01:55:04
那小孩就倒在那邊哭。

01:55:04 - 01:55:07
那你心想好像活該嘛，誰叫你要撞我。

01:55:07 - 01:55:08
你說走掉的。

01:55:08 - 01:55:08
你要去救他。

01:55:08 - 01:55:14
如果他後來死了，這樣的話，你會對他的死亡成立不作為的過失致死罪嗎？

01:55:16 - 01:55:18
如果採因果前行為，會。

01:55:19 - 01:55:22
因為小孩是你撞的嘛,你叫去救他嘛。

01:55:22 - 01:55:24
那如果採違背義務前行為呢?

01:55:25 - 01:55:26
不會啊。

01:55:26 - 01:55:26
因為

01:55:26 - 01:55:29
你怎麼一開始撞到他你沒有過失啊。

01:55:30 - 01:55:31
對啊，你一開始撞到他你沒有過失啊。

01:55:31 - 01:55:34
那你沒有過失造成別的法益陷入危險的話，

01:55:34 - 01:55:36
當然你就不會負有救助的義務，這是第一個區別。

01:55:37 - 01:55:39
無過失造成法益的危險。

01:55:40 - 01:55:42
再來第二個區別是考試最容易出現的。

01:55:43 - 01:55:44
圈圈二。

01:55:44 - 01:55:47
這個叫做正當防衛的行為人。

01:55:47 - 01:55:52
對於因為防衛行為而受損的歹徒有沒有救助的義務？

01:55:52 - 01:55:54
考試最常考這個。

01:55:54 - 01:55:56
正當防衛的行為人。

01:55:56 - 01:55:59
對於因為防衛行為而受損的歹徒，有沒有負有救

01:55:59 - 01:56:00
濟

01:56:00 - 01:56:01
救助的義務？

01:56:01 - 01:56:02
好，我舉個例子喔。

01:56:04 - 01:56:04
假設，

01:56:04 - 01:56:09
我今天晚上走出捷運站之後，走小巷回我家，

01:56:09 - 01:56:11
結果有個歹徒要對我性侵害。

01:56:12 - 01:56:14
那我為了捍衛自己的性自主權，

01:56:14 - 01:56:18
所以我就持磚塊反擊那個歹徒，把歹徒打倒在地。

01:56:18 - 01:56:23
歹徒被打倒在地之後啊，倒在地上流血，似乎是昏迷的狀態。

01:56:24 - 01:56:27
我心想我幹嘛救你啊,你要性侵我欸,我就走掉了。

01:56:27 - 01:56:33
結果隔天我下來買早餐的時候,我發現現場蓋起了一塊白布,還拉起黃色的封鎖線,

01:56:33 - 01:56:35
原來那個歹徒啊,後來死掉了。

01:56:36 - 01:56:38
各位,這樣的案例我怎麼論罪?

01:56:40 - 01:56:42
這種案例,你一定要分前後兩段喔,

01:56:43 - 01:56:44
是這樣子喔。

01:56:44 - 01:56:45
這種案例來說,

01:56:46 - 01:56:49
前面我們涉及到防衛,

01:56:51 - 01:56:52
前面涉及防衛嘛,

01:56:52 - 01:56:56
後面的話呢,行為人不救助這個歹徒。

01:56:57 - 01:57:00
防衛的部分，我把歹徒打倒在地，

01:57:01 - 01:57:03
我該當277條第一項的故意傷害罪，

01:57:04 - 01:57:06
但這時候我是不是可以依照正當防衛阻卻違法？

01:57:06 - 01:57:07
對，沒有錯，

01:57:07 - 01:57:11
所以這個時候呢，確實可以依照正當防衛阻卻違法，所以不成立犯罪。

01:57:11 - 01:57:14
那後面不救助的話,涉及什麼罪?

01:57:15 - 01:57:20
可能會有過失致死的不作為犯。

01:57:21 - 01:57:25
所以這裡要探討的是,有沒有危險前行為的保證人地位,

01:57:25 - 01:57:28
你知道嗎?這種題目你一定是前後拆開論。

01:57:29 - 01:57:35
因為每次考這種東西,同學最常犯的錯誤就是直接開277第二項傷害致死。

01:57:36 - 01:57:39
你直接開傷害致死的話，就會一團亂。

01:57:40 - 01:57:48
因為你看嘛，前面的防衛行為，前面的傷害基礎行為，它有阻卻違法事由。

01:57:49 - 01:57:52
後面不去救歹徒，它不會有阻卻違法事由。

01:57:53 - 01:57:54
你怎麼合在一起評價？

01:57:54 - 01:57:55
瞭解嗎？

01:57:55 - 01:57:58
所以這種情況，我們是拆開兩段去論。

01:57:58 - 01:58:00
前面的

01:58:00 - 01:58:01
防衛行為

01:58:01 - 01:58:03
277不會成立，因為那個叫正當防衛。

01:58:04 - 01:58:06
所以後面的不救助可能涉及到過失致死。

01:58:06 - 01:58:08
這裡算危險前行為嗎？

01:58:09 - 01:58:11
剛剛的兩說我講喔，通說採了來說。

01:58:13 - 01:58:15
通說採違背義務前行為。

01:58:16 - 01:58:20
也就是有做錯事的人，才會對法益負有救助的義務。

01:58:21 - 01:58:22
通說採否定說知道嗎？

01:58:22 - 01:58:23
違背義務前行為喔。

01:58:23 - 01:58:28
有做錯事的人,才會對法益產生救助的義務。

01:58:28 - 01:58:34
所以各位,如果我們採取違背義務的前行為的這一說法的話。

01:58:34 - 01:58:35
如果採這一說法喔。

01:58:36 - 01:58:39
那我不救歹徒會不會成立過失致死的違法呢?

01:58:39 - 01:58:40
當然不會。

01:58:40 - 01:58:41
懂嗎？

01:58:41 - 01:58:42
當然不會喔。

01:58:42 - 01:58:42
好。

01:58:42 - 01:58:44
那如果採因果前行為呢？

01:58:45 - 01:58:46
有沒有救助義務？

01:58:47 - 01:58:47
有喔。

01:58:47 - 01:58:51
這裡採因果前行為的話，會有救助義務喔。

01:58:52 - 01:58:54
所以這裡啊，有些人就覺得很奇怪。

01:58:55 - 01:58:58
說，採因果前行為，那我還要救歹徒喔。

01:58:59 - 01:59:01
第一個有人會說這個是不是違反人性？

01:59:02 - 01:59:02
再來喔。

01:59:03 - 01:59:07
那你把這個案例如果推導到誇張一點，歹徒性侵我把他打倒在地。

01:59:08 - 01:59:11
依照因果前行為，我要去救那個性侵犯。

01:59:11 - 01:59:15
那我救他，他救活之後，他看到我，他是不是又要來性侵我？

01:59:15 - 01:59:17
然後他又來性侵我呢，我再把他打倒在地。

01:59:18 - 01:59:20
打倒在地之後，我要去救他。

01:59:20 - 01:59:22
再把他救活，救活之後他又來性侵我。

01:59:22 - 01:59:24
那我再把他打倒在地。

01:59:24 - 01:59:25
無限循環。

01:59:25 - 01:59:27
當然這個是誇張啦,但我就說。

01:59:27 - 01:59:29
那這說法很怪,對不對？

01:59:29 - 01:59:30
所以跟你們講。

01:59:30 - 01:59:32
採因果前行為的學者,通常會搭配另外一個理論叫做無期待可能性。

01:59:37 - 01:59:38
黃榮堅老師的說法。

01:59:40 - 01:59:44
所以啊，黃榮堅老師在這個問題的處理上，他雖然採因果前行為沒有錯。

01:59:45 - 01:59:49
但他並沒有要讓這個不救助的人就因此而成立不作為犯，沒有。

01:59:50 - 01:59:50
而是怎麼做呢？

01:59:52 - 01:59:55
他在這個行為的罪責，

01:59:57 - 01:59:59
說行為人沒有救助的期待可能性。

02:00:00 - 02:00:05
你怎麼期待一個剛被歹徒攻擊的人去救那個侵害他的歹徒呢？

02:00:05 - 02:00:06
不可能，對不對？

02:00:06 - 02:00:10
所以我們的會在罪責的部分，說這個行為人無期待可能性，進而讓這個行為人不成立犯罪，懂嗎？

02:00:13 - 02:00:15
這個是多數說的做法。

02:00:16 - 02:00:17
不是多數說啦，少數說啦，黃老師的做法。

02:00:18 - 02:00:21
多數說會直接否定保證人的地位。

02:00:21 - 02:00:29
好，那第三個區別是，請緊急避難的人，對於避難行為被犧牲的無辜者，有沒有救助義務？

02:00:31 - 02:00:32
好，你想喔。

02:00:32 - 02:00:35
假設我開車在路上。

02:00:35 - 02:00:38
結果不明原因，煞車失靈。

02:00:39 - 02:00:43
證明跟我無關，不是我疏於保養喔，是可能原廠的瑕疵喔。

02:00:43 - 02:00:44
不明原因上升失靈。

02:00:44 - 02:00:50
那我眼看著前面是國小，而且一群小朋友在過馬路。

02:00:51 - 02:00:52
我往前衝的話死傷無數。

02:00:53 - 02:00:55
所以我趕快把車子的方向盤往右打。

02:00:56 - 02:00:59
讓車子衝上人行道，只撞傷兩個行人。

02:01:00 - 02:01:02
那我這個叫什麼呢？

02:01:02 - 02:01:03
緊急避難。

02:01:03 - 02:01:05
對不對，我要這個要緊急避難嘛。

02:01:05 - 02:01:08
為了避免更大的傷亡，所以我犧牲路人的身體。

02:01:08 - 02:01:09
緊急避難。

02:01:09 - 02:01:14
所以我把那兩個行人撞傷之後，有沒有義務要去救那兩個行人？

02:01:16 - 02:01:16
這問題很有趣喔。

02:01:17 - 02:01:20
如果你採違背義務前行為的話。

02:01:21 - 02:01:23
那緊急避難是合法行為啊，我又沒有做錯事。

02:01:24 - 02:01:25
所以我要去救那兩個路人。

02:01:26 - 02:01:26
好像不用，對不對？

02:01:27 - 02:01:29
但通說總覺得聽起來怪怪、毛毛的。

02:01:30 - 02:01:31
所以這個時候呢，開例外。

02:01:32 - 02:01:32
你看通說怎麼講。

02:01:33 - 02:01:35
通說講說雖然他是合法行為沒有錯。

02:01:35 - 02:01:40
但說呢,但由於被犧牲者所產生的服務需求是由避難者所導致的。

02:01:40 - 02:01:44
所以避難者有義務要讓犧牲者的損害不要繼續擴大。

02:01:44 - 02:01:46
這個理由我覺得不堅強啦。

02:01:47 - 02:01:49
但通說就是覺得法感怪怪的。

02:01:49 - 02:01:50
所以在這邊開例外。

02:01:51 - 02:01:53
但反觀如果採取黃榮堅老師的理論呢。

02:01:54 - 02:01:55
那不是問題啊。

02:01:55 - 02:01:57
因為黃老師本來就不設限啊。

02:01:57 - 02:01:59
他就採因果前行為啊。

02:01:59 - 02:02:00
所以有道理。

02:02:00 - 02:02:00
救助義務,

02:02:00 - 02:02:01
有啊，本來就有啊。

02:02:02 - 02:02:05
所以我以前還蠻喜歡讀黃老師那本基礎刑法學。

02:02:05 - 02:02:06
因為我覺得，

02:02:07 - 02:02:09
黃老師理論算是少數說法,

02:02:09 - 02:02:10
但他的好處就是邏輯一貫。

02:02:11 - 02:02:12
不會說到這邊採這一說,

02:02:12 - 02:02:15
然後到這邊覺得這一說好怪,我又再開個例外,不會。

02:02:15 - 02:02:17
他就是這個理論從頭可以用到尾。

02:02:17 - 02:02:18
我覺得好處就是這樣。

02:02:19 - 02:02:21
好，所以這個是幾個區別實益。

02:02:22 - 02:02:23
那當然我說最常考的就是，

02:02:23 - 02:02:25
括號這個圈圈二，

02:02:26 - 02:02:28
正當防衛之後的狀況。

02:02:28 - 02:02:29
這個是最常出現的情況。

02:02:30 - 02:02:31
下面這個經典考題啊，

02:02:31 - 02:02:33
因為我覺得這一題有點難啦，

02:02:33 - 02:02:35
這個講完很花時間，

02:02:35 - 02:02:37
我用另外一題來替代。

02:02:37 - 02:02:38
我覺得這一題不應該放課本

02:02:38 - 02:02:40
這一題應該放解題書就好。

02:02:41 - 02:02:43
課堂不適合講那麼雜的題目。

02:02:43 - 02:02:45
我們看另外一題來做替代

02:02:45 - 02:02:46
這一題在

02:02:46 - 02:02:48
在國防法務官那一題來

02:02:53 - 02:02:54
37頁第四題,

02:03:55 - 02:03:56
你知道這一題在考什麼嗎？

02:03:59 - 02:04:00
這一題就是黑板上這個結構，

02:04:00 - 02:04:00
瞭解吧，他是這樣出的。

02:04:02 - 02:04:02
OK喔，這個是強制罪喔。

02:04:04 - 02:04:06
所以這個甲在對強制行為的正當防衛。

02:04:06 - 02:04:09
那甲在強制行為的正當防衛之後。

02:04:09 - 02:04:12
後面，他有沒有去救那個機車騎士。

02:04:13 - 02:04:14
那就這個問題啊。

02:04:15 - 02:04:18
違背義務的前行為跟因果前行為。

02:04:18 - 02:04:19
就是這兩說。

02:04:20 - 02:04:21
瞭解喔，就這兩說。

02:04:23 - 02:04:25
好，所以這個就是第四題喔。

02:04:26 - 02:04:27
就是在考一模一樣的東西。

02:04:28 - 02:04:29
好，繼續我們回到408頁。

02:04:30 - 02:04:33
我往下看喔，不作為犯的違法跟罪責。

02:04:48 - 02:04:48
好，我們來看一下。

02:04:49 - 02:04:55
那個不作為犯啊，他的違法性，阻卻違法是由，大部分都跟作為犯一樣。

02:04:56 - 02:05:00
唯獨有一種東西是不作為犯專屬的。

02:05:00 - 02:05:03
阻卻違法是由，這個東西叫做義務衝突。

02:05:03 - 02:05:06
好，我們在講義務衝突前。

02:05:06 - 02:05:07
概念上來講。

02:05:07 - 02:05:09
義務衝突想像上可能會有三類。

02:05:10 - 02:05:11
第一個是。

02:05:12 - 02:05:14
不作為義務跟不作為義務。

02:05:14 - 02:05:16
但我打問號，為什麼呢？

02:05:18 - 02:05:20
我們人活在這個世界上。

02:05:20 - 02:05:22
本來就面臨了無數的不作為義務。

02:05:23 - 02:05:25
此時此刻的我們。

02:05:25 - 02:05:29
我們不可以去殺人，不可以去打人，不可以去偷東西，不可以加入詐騙集團。

02:05:30 - 02:05:31
這些都是不作為義務。

02:05:32 - 02:05:34
那沒有衝突啊，你不要去犯法就好了啊，對不對？

02:05:34 - 02:05:35
所以這個不叫義務衝突啊。

02:05:36 - 02:05:40
再來第二個叫做不作為義務跟作為義務的衝突。

02:05:41 - 02:05:44
爸爸帶女兒出去玩，結果女兒被狗咬。

02:05:44 - 02:05:45
而且這隻狗是有人養的。

02:05:46 - 02:05:47
爸爸為了救女兒所以把那隻狗打死。

02:05:49 - 02:05:49
這個是什麼？

02:05:51 - 02:05:52
作為義務，要救女兒。

02:05:53 - 02:05:55
作為義務和不作為義務，不可以毀損財產的衝突。

02:05:56 - 02:05:58
那這個我們也不用特別處理，為什麼？

02:05:58 - 02:05:59
那就緊急避難嘛，對不對？

02:06:00 - 02:06:01
這個沒有什麼問題。

02:06:01 - 02:06:02
接著第三個，

02:06:03 - 02:06:05
那作為義務跟作為義務的衝突呢？

02:06:06 - 02:06:09
媽媽帶兩個小孩去玩水，

02:06:10 - 02:06:11
兩個小孩同時溺水，

02:06:12 - 02:06:13
媽媽先救第一個，

02:06:14 - 02:06:16
救起來之後啊，媽媽的腳抽筋了，

02:06:17 - 02:06:17
救不了第二個。

02:06:18 - 02:06:20
只好放任第二個小孩溺斃。

02:06:21 - 02:06:22
這個叫義務衝突，

02:06:22 - 02:06:23
作為義務跟作為義務。

02:06:24 - 02:06:27
這種情況有些同學會想，用緊急避難不行嗎？

02:06:28 - 02:06:29
不行。

02:06:29 - 02:06:29
為什麼？

02:06:29 - 02:06:32
因為這種案例如果你用緊急避難的話，

02:06:33 - 02:06:35
緊急避難，這個是攻擊還防禦？

02:06:36 - 02:06:37
攻擊啊，因為他犧牲無辜啊。

02:06:37 - 02:06:38
對不對？

02:06:38 - 02:06:40
攻擊型要法益衡平，要大於。

02:06:40 - 02:06:42
這種是不是對的，對啊，不能去違法啊。

02:06:43 - 02:06:45
所以我們只好另創這個東西。

02:06:45 - 02:06:48
另創超法規阻卻違法是有。

02:06:48 - 02:06:49
那叫做義務衝突。

02:06:49 - 02:06:49
知道嗎？

02:06:49 - 02:06:50
它是這樣來的。

02:06:51 - 02:06:51
好，所以我們來看一下。

02:06:53 - 02:06:53
括號三說的，

02:06:54 - 02:06:58
作為義務跟作為義務的衝突，這才是義務衝突喔。

02:06:59 - 02:07:00
因為緊急避難處理不了嘛,

02:07:01 - 02:07:04
法益衡量過不去嘛,所以我們只好另創這個東西。

02:07:05 - 02:07:06
來,409頁,我們來看要件。

02:07:07 - 02:07:12
首先第一個,叫做有數個作為義務同時存在。

02:07:13 - 02:07:14
這個什麼意思?

02:07:15 - 02:07:20
同學我們聽過一個，這個算笑話嗎？就聽說很多女生都會這樣問男朋友。

02:07:20 - 02:07:25
女生都會問男朋友說，如果我跟你媽同時落水，你會先救誰？

02:07:26 - 02:07:28
各位，這個不是義務衝突。

02:07:29 - 02:07:29
知道嗎？

02:07:30 - 02:07:31
這不是義務衝突，當然啦。

02:07:31 - 02:07:34
因為男生對媽媽有救助義務,

02:07:34 - 02:07:37
但男生對女朋友應該不會有救助義務。

02:07:38 - 02:07:40
所以如果男同學以後被問,

02:07:40 - 02:07:43
被女朋友問，說我跟你媽落水，你要先救誰？

02:07:44 - 02:07:46
法律上的正確答案是要救媽媽。

02:07:46 - 02:07:47
瞭解吧？

02:07:47 - 02:07:50
對，法律上正確答案是要救媽媽，因為這個才有保證人地位。

02:07:50 - 02:07:51
這不是義務衝突喔。

02:07:52 - 02:07:53
對，這不是義務衝突喔。

02:07:54 - 02:07:59
好，所以我們說第一個，要有數個作為義務同時存在。

02:08:00 - 02:08:01
女朋友跟媽媽一起落水,

02:08:01 - 02:08:02
那個應該不算喔。

02:08:02 - 02:08:03
好,

02:08:03 - 02:08:03
第二個。

02:08:05 - 02:08:06
數個義務要有排斥的關係,

02:08:07 - 02:08:09
行為人只能履行其中一部分。

02:08:09 - 02:08:11
為什麼我剛剛要特別講，

02:08:11 - 02:08:13
你說媽媽救完第一個小孩之後腳就抽筋了，

02:08:14 - 02:08:14
為什麼？

02:08:15 - 02:08:17
她腳沒有抽筋的話為什麼不去救第二個？

02:08:17 - 02:08:17
對吧？

02:08:18 - 02:08:20
所以我特別講說他腳抽筋就在講這個要件。

02:08:20 - 02:08:22
數個義務間具有排斥的關係，

02:08:22 - 02:08:24
行為人只能履行其中一部分。

02:08:25 - 02:08:25
好。

02:08:25 - 02:08:26
第三個喔,

02:08:26 - 02:08:29
行為人盡力履行的部分,

02:08:31 - 02:08:32
他已經盡力了,

02:08:32 - 02:08:33
而且履行部分的法益,

02:08:34 - 02:08:37
沒有輕於未履行的部分。

02:08:38 - 02:08:39
這個又在講什麼呢？

02:08:39 - 02:08:39
好，

02:08:39 - 02:08:40
我們再思考一個問題喔。

02:08:41 - 02:08:42
那如果是說，

02:08:43 - 02:08:43
好，

02:08:43 - 02:08:44
比如說那個什麼？

02:08:45 - 02:08:46
媽媽，

02:08:46 - 02:08:48
帶著她的一個小孩，

02:08:49 - 02:08:50
跟他們養的狗，

02:08:50 - 02:08:51
比如說一隻吉娃娃。

02:08:51 - 02:08:54
帶著小孩跟吉娃娃一起去溪邊玩水。

02:08:54 - 02:08:55
結果啊,

02:08:55 - 02:08:57
小孩跟吉娃娃同時溺水。

02:08:58 - 02:08:59
媽媽這個時候心想,

02:08:59 - 02:09:01
毛小孩比較可愛,

02:09:01 - 02:09:02
他先去救那隻狗,

02:09:03 - 02:09:04
結果把狗救上來之後啊,

02:09:04 - 02:09:06
那媽媽腿又抽筋了,

02:09:06 - 02:09:07
救不了小孩了,

02:09:07 - 02:09:09
只好放任小孩被流走。

02:09:10 - 02:09:10
欸,

02:09:10 - 02:09:12
這個不能主張義務衝突喔。

02:09:13 - 02:09:15
人類小孩跟毛小孩一起溺水,

02:09:16 - 02:09:17
怎麼不先去救人類呢?

02:09:17 - 02:09:18
這個不行喔，

02:09:18 - 02:09:19
所以這個是第三個要件。

02:09:20 - 02:09:21
接著翻過來第四個要件，

02:09:22 - 02:09:23
造成這個局面，

02:09:23 - 02:09:25
並不是可歸責於行為人所致。

02:09:27 - 02:09:27
這在講什麼啊？

02:09:28 - 02:09:28
好,

02:09:28 - 02:09:29
那如果是有一天,

02:09:30 - 02:09:32
媽媽帶兩個小孩去山上,

02:09:33 - 02:09:34
比如說去那個哪裡,

02:09:34 - 02:09:35
汐止的山上,

02:09:35 - 02:09:36
新山夢湖,

02:09:36 - 02:09:37
那個地方還蠻漂亮的。

02:09:38 - 02:09:39
媽媽可能從外縣市,

02:09:40 - 02:09:42
開好幾個小時的車去那個汐止的新山夢湖。

02:09:43 - 02:09:44
帶小孩去看那個美麗的湖景。

02:09:45 - 02:09:45
結果啊，

02:09:46 - 02:09:46
到了現場，

02:09:47 - 02:09:48
兩個小孩沒興趣，

02:09:49 - 02:09:49
說想去看動物。

02:09:50 - 02:09:51
說不想看新山夢湖,

02:09:51 - 02:09:52
那媽媽火了,

02:09:52 - 02:09:54
想說我開這麼多的那麼久的車,

02:09:54 - 02:09:55
那你們竟然沒有興趣,

02:09:55 - 02:09:56
媽媽一氣之下,

02:09:57 - 02:09:58
就把兩個小孩往湖裡面丟。

02:09:59 - 02:10:00
這樣子。

02:10:00 - 02:10:02
把小孩往湖裡面丟。

02:10:03 - 02:10:04
你們聽過一個笑話，

02:10:04 - 02:10:08
那個，有一次，阿嬤帶著孫子在湖邊散步。

02:10:09 - 02:10:10
孫子掉到湖裡面了。

02:10:11 - 02:10:14
幾秒後啊，湖中女神浮起來了。

02:10:15 - 02:10:15
阿嬤就很著急啊，

02:10:16 - 02:10:18
跟湖中女神講說拜託你要快快救我的金孫啊。

02:10:19 - 02:10:22
結果湖中女神講了一句話，說你太貪心了。

02:10:23 - 02:10:24
女神就沉下去了。

02:10:25 - 02:10:25
聽過嗎？

02:10:25 - 02:10:27
金斧頭、銀斧頭的笑話啊。

02:10:28 - 02:10:30
不能講要救金孫，要說你要救我的普孫。

02:10:30 - 02:10:32
這樣的話，湖中女神才會去救。

02:10:32 - 02:10:34
好，這時候媽媽，回到我剛剛那個案例。

02:10:35 - 02:10:37
媽媽把兩個小孩往湖裡面丟嘛。

02:10:38 - 02:10:39
丟下去之後，

02:10:39 - 02:10:40
哎，糟糕，兩個小孩不會游泳。

02:10:41 - 02:10:43
媽媽瞬間恢復理智，我怎麼做這種事？

02:10:43 - 02:10:44
趕快跳下去救。

02:10:45 - 02:10:49
結果一樣啊，媽媽救完第一個小孩之後，她腿又抽筋了，又救不了第二個啦。

02:10:49 - 02:10:52
只好放任這個小孩溺斃，這種情況不能主張義務衝突喔。

02:10:53 - 02:10:54
因為行為人可歸責在先。

02:10:55 - 02:10:56
他先做這種事嘛。

02:10:56 - 02:10:58
所以我們講，這是義務衝突的四大要件。

02:10:59 - 02:11:07
四大要件

02:11:07 - 02:11:25
如果都符合的話，

02:11:25 - 02:11:42
那效果叫什麼呢？

02:11:42 - 02:11:44
阻卻違法不成立犯罪。

02:11:44 - 02:11:46
所以它是一種阻卻違法事由。

02:11:47 - 02:11:47
來，

02:11:48 - 02:11:49
下面這個進階問題。

02:11:50 - 02:11:51
以前發生過這麼一件很荒謬的事。

02:11:52 - 02:11:54
真實案件喔，大概十年前的事。

02:11:55 - 02:11:59
當時，有個警察在路上追通緝犯。

02:12:00 - 02:12:02
民眾身上有濃濃的酒味。

02:12:02 - 02:12:05
警察說，那你剛剛騎車抓通緝犯。

02:12:05 - 02:12:06
你喝酒欸。

02:12:07 - 02:12:09
結果就兩個人都進警局。

02:12:10 - 02:12:12
通緝犯進警局就他原本通緝的罪。

02:12:13 - 02:12:15
那個見義勇為的民眾也進警局。

02:12:15 - 02:12:16
因為他酒駕。

02:12:17 - 02:12:18
對，沒錯，因為他酒駕。

02:12:19 - 02:12:21
然後，對啊，就因為他酒駕啊。

02:12:21 - 02:12:23
後來那個民眾真的被起訴酒駕，185之3。

02:12:24 - 02:12:28
那個民眾覺得很冤，說我為了幫警察抓通緝犯，我酒駕應該可以吧。

02:12:29 - 02:12:33
當時好像是他的律師吧，幫他主張義務衝突。

02:12:34 - 02:12:36
這個律師不對啦，這不叫義務衝突啦。

02:12:36 - 02:12:38
對啊，當時律師幫他主張義務衝突。

02:12:39 - 02:12:42
我跟你講，法院後來義務衝突不成立，為什麼？

02:12:44 - 02:12:45
不可以酒駕是每個人的義務。

02:12:46 - 02:12:47
抓通緝犯是嗎?

02:12:48 - 02:12:50
不是啊，抓通緝犯是權力啊，又不是義務，對不對？

02:12:50 - 02:12:52
所以法院說這個不算義務衝突。

02:12:52 - 02:12:53
那我們再延伸思考啦。

02:12:54 - 02:12:59
因為刑事訴訟當中，他又不像民訴，民訴有所謂聲明的拘束性嘛。

02:12:59 - 02:12:59
懂這意思吧？

02:13:00 - 02:13:07
就民訴你要告民法184，那你請求權基礎用錯，用到767，法院不會跟你更正，法院會判你敗訴，民訴是這樣，刑訴不是啊。

02:13:08 - 02:13:11
刑訴你的罪名什麼主張錯沒關係啊，因為法院有職權。

02:13:11 - 02:13:14
法院有職權更正的義務嘛。

02:13:14 - 02:13:16
對，所以這一件他主張義務衝突當然不對。

02:13:17 - 02:13:18
那我們退一步來講。

02:13:18 - 02:13:20
這件有沒有適用緊急避難的空間？

02:13:21 - 02:13:22
緊急避難可不可以？

02:13:23 - 02:13:24
一樣不行啦。

02:13:24 - 02:13:24
為什麼？

02:13:25 - 02:13:28
抓通緝犯是保護什麼利益，國家司法權的行使。

02:13:29 - 02:13:31
那個不是緊急避難能保護的法益，知道嗎？

02:13:31 - 02:13:33
所以這一件，其實李正哲老師的看法也一樣。

02:13:34 - 02:13:35
就是不能阻卻違法。

02:13:37 - 02:13:40
因為真的沒有阻卻法事由啦，也沒有類似雙法來阻卻法事由，就真的沒有。

02:13:41 - 02:13:43
所以正見確實不能主動違法。

02:13:43 - 02:13:47
頂多啦，如果行為人覺得他的酒駕是可以被允許的。

02:13:48 - 02:13:49
那就走16條啊，容許錯誤。

02:13:50 - 02:13:51
頂多是這樣，知道嗎？頂多走16條，容許錯誤。

02:13:52 - 02:13:54
10年前的案件，以前考試有考過。

02:13:56 - 02:13:59
好,然後不作為犯的罪責,這跟作為犯基本上一樣,沒有了。

02:14:00 - 02:14:00
什麼要說的?

02:14:01 - 02:14:02
請翻過來412頁。

02:14:03 - 02:14:05
不作為犯的未遂犯。

02:14:15 - 02:14:17
不作為犯的未遂犯,我們談的問題是,

02:14:17 - 02:14:20
那不作為犯什麼時候著手？

02:14:22 - 02:14:22
這個東西，

02:14:23 - 02:14:23
你看哦，

02:14:24 - 02:14:27
有一種說法叫做第一救助機會理論。

02:14:28 - 02:14:31
不作為犯的著手，有人是說你錯過第一個機會。

02:14:32 - 02:14:33
就是著手。

02:14:34 - 02:14:38
也有另外一個說法叫做最後救助機會理論。

02:14:39 - 02:14:43
你要錯過那個最後的拯救機會，才算是著手。

02:14:44 - 02:14:45
也有這個說法，

02:14:45 - 02:14:46
錯過最後機會才算。

02:14:47 - 02:14:51
還有一個說法叫區分說，法益危險理論，

02:14:51 - 02:14:53
直接危險理論，區分說，

02:14:53 - 02:14:57
等於是怎麼樣呢？把主客觀混合說帶到不作為犯。

02:14:58 - 02:15:00
所以你看哦，照區分說來講，

02:15:01 - 02:15:06
如果照行為人認知，保護法益已經進入危險狀態的話，那確實是行為人著手了。

02:15:07 - 02:15:10
但如果還沒有進入危險狀態的話，

02:15:10 - 02:15:12
那我們就要看呢，照行為人認知，

02:15:13 - 02:15:15
那個危險快要接近了沒有？

02:15:16 - 02:15:18
還有，照行為人的認知，

02:15:19 - 02:15:22
我們再看呢，行為人後來做了什麼事。

02:15:23 - 02:15:25
如果行為人隨時都可以進入作為的話,

02:15:26 - 02:15:27
那要等危險接近才著手。

02:15:27 - 02:15:32
但如果行為人是轉身離去，放任這個危險擴大的話，那他轉身離去就是著手。

02:15:33 - 02:15:35
所以照最後一種說法，

02:15:35 - 02:15:36
比如說學者舉的例子。

02:15:37 - 02:15:40
平交道管理員看到有個醉漢倒在鐵軌上面。

02:15:41 - 02:15:42
照邱先生說的話,

02:15:42 - 02:15:43
那什麼時候著手？

02:15:43 - 02:15:45
第一個我會問，那火車快來了沒有？

02:15:46 - 02:15:48
如果火車半個小時之後才會來的話,

02:15:48 - 02:15:52
那你就要看這個管理員他當時做了什麼事。

02:15:53 - 02:15:57
如果他繼續在平交道旁邊的那個小房間裡面，繼續看那個醉漢，

02:15:58 - 02:15:59
那要等什麼時候才著手？

02:16:00 - 02:16:02
可能等火車到幾百公尺之處，

02:16:02 - 02:16:03
快要到的時候才著手。

02:16:04 - 02:16:06
但如果這個管理人是直接轉身離開呢？

02:16:06 - 02:16:07
那他一離開就著手了，

02:16:07 - 02:16:07
懂嗎？

02:16:08 - 02:16:09
這個判斷是這樣子，

02:16:09 - 02:16:10
我想應該不難。

02:16:11 - 02:16:11
來,

02:16:11 - 02:16:12
那下面第二大點,

02:16:12 - 02:16:14
不作為犯的中止未遂。

02:16:15 - 02:16:16
這個東西,

02:16:16 - 02:16:17
再跟各位講一件事。

02:16:17 - 02:16:19
就是不作為犯的中止未遂,

02:16:19 - 02:16:22
不適用那個推手推車過山坡的圖。

02:16:22 - 02:16:23
不適用,

02:16:23 - 02:16:23
為什麼？

02:16:24 - 02:16:25
因為作為犯我會講,

02:16:26 - 02:16:27
未了未遂，

02:16:27 - 02:16:28
行為人只要放棄。

02:16:29 - 02:16:30
既了未遂，

02:16:30 - 02:16:31
要行為人積極拯救。

02:16:32 - 02:16:34
這個當然在不作為犯不適用啊。

02:16:35 - 02:16:36
不作為犯他就是不作為。

02:16:36 - 02:16:37
所以他的中止行為，

02:16:37 - 02:16:38
當然要怎麼樣？

02:16:38 - 02:16:39
他當然要作為啊，

02:16:39 - 02:16:40
怎麼可以放棄？

02:16:41 - 02:16:42
放棄就是繼續不作為,

02:16:42 - 02:16:42
對不對？

02:16:42 - 02:16:44
所以不作為犯的中止未遂,

02:16:44 - 02:16:45
不適用那個圖。

02:16:46 - 02:16:46
好,

02:16:46 - 02:16:47
關於不作為犯的著手，

02:16:47 - 02:16:49
我們直接用下面這一題來看。

02:16:50 - 02:16:51
我們用下面這一題，

02:16:51 - 02:16:53
來跑一下前面的三說。

02:16:53 - 02:16:55
讓同學知道一下這三說怎麼用。

02:16:55 - 02:16:56
這個題目出得很好。

02:16:57 - 02:16:58
這就是不作為犯的著手,

02:16:58 - 02:16:59
經典的題目。

02:17:34 - 02:17:36
這一題你不要去寫誤想防衛。

02:17:37 - 02:17:39
很多人會看走眼,

02:17:39 - 02:17:40
他就寫誤想防衛。

02:17:41 - 02:17:42
看清楚,

02:17:42 - 02:17:43
誰在誤想防衛？

02:17:44 - 02:17:44
小黑。

02:17:45 - 02:17:46
是那一隻狗。

02:17:47 - 02:17:47
不要寫錯,

02:17:48 - 02:17:48
我真的遇過這種同學,

02:17:49 - 02:17:51
就看得老半天就看到黑影就開槍,

02:17:51 - 02:17:52
這邊說小黑誤想防衛,

02:17:53 - 02:17:53
不要這樣寫,

02:17:53 - 02:17:54
小黑是狗。

02:17:55 - 02:17:55
好咧,

02:17:56 - 02:17:57
那個甲怎麼論罪啊?

02:17:58 - 02:17:59
我們看喔。

02:18:00 - 02:18:02
甲的部分你要做區分。

02:18:02 - 02:18:03
第一個是，

02:18:04 - 02:18:07
假若小黑掙脫狗繩，

02:18:08 - 02:18:10
這是你第一個要檢討的行為。

02:18:10 - 02:18:12
假若小黑掙脫狗繩。

02:18:13 - 02:18:13
同學啊，

02:18:14 - 02:18:18
假若小黑掙脫狗繩,對,它確實是不作為,

02:18:19 - 02:18:20
但那個行為會不會成立犯罪?

02:18:20 - 02:18:21
不會,

02:18:21 - 02:18:21
為什麼?

02:18:21 - 02:18:23
因為沒有作為可能性。

02:18:23 - 02:18:26
狗發瘋起來的時候啊，那個力氣比人還大。

02:18:26 - 02:18:28
這各位有拉過狗就知道。

02:18:29 - 02:18:30
題目裡面喔，

02:18:30 - 02:18:31
小黑是狼狗，

02:18:31 - 02:18:32
又不是吉娃娃。

02:18:32 - 02:18:33
吉娃娃當然拉得住啊,

02:18:33 - 02:18:34
狼狗,

02:18:34 - 02:18:35
這很大的狗啊。

02:18:35 - 02:18:37
對，所以這一題當中，

02:18:38 - 02:18:42
牠在狗發瘋的第一時間沒有抓住。

02:18:42 - 02:18:43
對，這個是不作為，

02:18:43 - 02:18:45
但他沒有作為的可能性。

02:18:45 - 02:18:46
所以這個行為不成立犯罪，

02:18:46 - 02:18:47
知道嗎？

02:18:47 - 02:18:49
你要做這樣的區分，這個行為不成立犯罪。

02:18:49 - 02:18:50
好，然後再來喔。

02:18:52 - 02:18:53
小黑撕咬乙。

02:18:54 - 02:18:55
然後他不阻止。

02:18:56 - 02:18:57
這是第二個不作為。

02:18:58 - 02:19:40
小黑在撕咬乙。

02:19:40 - 02:19:41
但是甲卻不阻止,

02:19:41 - 02:19:42
是第二個不作為。

02:19:43 - 02:19:44
第二個不作為有沒有作為的可能性？

02:19:44 - 02:19:45
有，

02:19:45 - 02:19:46
他有作為可能性。

02:19:46 - 02:19:48
所以這裡在探討的是，

02:19:48 - 02:19:50
那他著手了沒有？

02:19:50 - 02:19:51
你沒有試嘛，

02:19:51 - 02:19:51
對不對？

02:19:51 - 02:19:52
他著手了沒有？

02:19:53 - 02:19:54
那我們看左邊這三說。

02:19:57 - 02:19:59
如果採一有沒有著手?

02:19:59 - 02:20:00
有啊。

02:20:00 - 02:20:02
中止未遂啊,

02:20:02 - 02:20:04
對啊,這題設計中止未遂啊

02:20:05 - 02:20:09
你看，被害人說，我做鬼也不會放過你。

02:20:10 - 02:20:11
甲驚覺事態嚴重，

02:20:12 - 02:20:13
叫小黑停止攻擊，

02:20:14 - 02:20:15
並打119。

02:20:15 - 02:20:17
但後來這個被路人送醫了。

02:20:18 - 02:20:19
所以這個涉及到準中止,

02:20:21 - 02:20:25
我們這裡要爭執的問題是說,那這個題目當中,

02:20:26 - 02:20:30
甲他有沒有算是因己意而終止,

02:20:31 - 02:20:34
被被害人說我做鬼也不會放過你,

02:20:34 - 02:20:35
這樣算己意

02:20:36 - 02:20:38
我們前幾個禮拜講的三說，我們大概複習一下，

02:20:38 - 02:20:40
如果照主觀說，

02:20:41 - 02:20:42
法蘭克公式，

02:20:43 - 02:20:45
這個得為而不為，

02:20:45 - 02:20:46
應該算。

02:20:46 - 02:20:46
對不對？

02:20:46 - 02:20:48
所以照法蘭克公式的話應該算。

02:20:48 - 02:20:51
那如果照那個限定主觀說，算不算？

02:20:52 - 02:20:54
倫理上的自我要求，

02:20:55 - 02:20:56
好像不算耶。

02:20:56 - 02:20:57
對啊，好像不算喔。

02:20:57 - 02:20:59
那如果照客觀來說呢？

02:21:40 - 02:21:41
一般人會怎麼選擇？

02:21:42 - 02:21:44
客觀來說我不會選，真的。

02:21:44 - 02:21:49
一般人遇到被害人威脅說我做鬼也不會放過你，就會這樣停下來嗎？

02:21:49 - 02:21:50
我說真的我不知道,

02:21:50 - 02:21:51
所以客觀說不好寫,

02:21:52 - 02:21:54
至少照主觀說啦，他有已意,

02:21:54 - 02:21:55
懂嗎，所以這題設計的很好喔,

02:21:56 - 02:21:58
這一題考到不作為犯的作為可能性

02:21:58 - 02:22:00
考到著手，也考到了因已意終止。

02:22:00 - 02:22:01
這邊才問的是個問題，知道嗎？

02:22:02 - 02:22:07
這些參與形態可不可以用不作為的方式來實現？

02:22:07 - 02:22:09
答案是不一定啦，你要看哪一種。

02:22:10 - 02:22:11
第一個叫間接正犯。

02:22:11 - 02:22:12
好，這個沒有什麼疑問。

02:22:13 - 02:22:15
間接正犯當然不可以是不作為。

02:22:15 - 02:22:16
當然不可以，為什麼？

02:22:16 - 02:22:19
間接正犯叫優越意思支配。

02:22:20 - 02:22:21
那個定義上就衝突啦。

02:22:21 - 02:22:25
你要怎麼用不作為去意志支配別人？

02:22:25 - 02:22:26
不可能，對吧？

02:22:26 - 02:22:29
所以間接正犯沒有不作為。

02:22:30 - 02:22:36
那你來看清楚喔，如果出現疑似不作為的間接正犯。

02:22:37 - 02:22:38
那我們要論什麼？

02:22:38 - 02:22:41
我們要論那個直接正犯，知道嗎？

02:22:41 - 02:22:44
我們論直接正犯就好了，不用去論間接正犯。

02:22:44 - 02:22:45
所以我們來看到下面這個案例。

02:22:53 - 02:22:55
甲大學畢業之後請朋友幫忙搬家。

02:22:55 - 02:23:03
以前往甲的住居的宿舍搬東西的時候啊，誤將甲的室友的筆電一同搬到箱子上。

02:23:03 - 02:23:04
裝到車上。

02:23:04 - 02:23:11
甲看到這個情況，因為兩個人之前有紛爭，所以甲沒有跟以說這個電腦是比爾所有，願由乙把電腦搬回家。

02:23:11 - 02:23:12
說甲有什麼刑責。

02:23:12 - 02:23:14
很多同學看到這題傻住，說這題在考什麼？

02:23:14 - 02:23:16
我跟你們講，這題思考很簡單，我們稍微把題目改一下喔。

02:23:19 - 02:23:21
如果這個題目當中啊，假設是這樣喔。

02:23:22 - 02:23:23
如果

02:23:23 - 02:23:24
這個題目當中，甲

02:23:25 - 02:23:27
他是直接跟他朋友講：

02:23:27 - 02:23:29
「那個筆電是我的，幫我搬上車。」

02:23:31 - 02:23:33
那你會覺得這個百分之百是正犯，對吧？

02:23:33 - 02:23:34
哪一種？

02:23:34 - 02:23:36
利用他人進入故意的情境，錯誤支配，對不對？

02:23:38 - 02:23:39
那這一題改成是怎麼樣？

02:23:40 - 02:23:43
沒有阻止他人既有的錯誤，這樣就是不作為啊。

02:23:45 - 02:23:46
所以這一題我們要講第一個。

02:23:46 - 02:23:50
不作為不能成立，間接正犯，這是第一點喔，知道嗎？

02:23:50 - 02:23:52
不作為不能成立間接正犯，於是我們考慮什麼呢？

02:23:54 - 02:23:55
直接正犯。

02:23:56 - 02:23:59
甲可被成立，作為不作為的直接正犯。

02:23:59 - 02:23:59
可是

02:24:00 - 02:24:01
不點，為什麼，因為沒有保障的地位。

02:24:03 - 02:24:05
對啊，對私有的財產怎麼會有保障的地位。

02:24:06 - 02:24:08
我們講嘛，保障的地位就黑板上兩種嘛。

02:24:09 - 02:24:10
保護跟監督嘛。

02:24:11 - 02:24:12
所以你覺得，來第一個。

02:24:12 - 02:24:14
甲對他所有的財產有個保護義務。

02:24:15 - 02:24:15
廢話，當然沒有啊。

02:24:16 - 02:24:19
那甲對來幫他搬家的朋友的行為有沒有監督義務？

02:24:19 - 02:24:20
當然也不會有，對不對？

02:24:21 - 02:24:22
這是搞笑，威脅原先都不可能嘛。

02:24:23 - 02:24:26
所以這題當中，沒有保證的地位了，因為無罪，知道嗎。

02:24:27 - 02:24:30
所以記得那個層次哦，你要先寫間接正犯。

02:24:30 - 02:24:33
說間接正犯不能用不作為的方式來實現。

02:24:34 - 02:24:36
然後再轉而去寫直接正犯，但也不成立。

02:24:36 - 02:24:38
因為行為人沒有保證的地位，這樣寫才漂亮。

02:24:40 - 02:24:42
好，不作為可不可以寫共同正犯？

02:24:42 - 02:24:43
可以。

02:24:43 - 02:24:43
一定可以。

02:24:44 - 02:24:45
這沒有問題喔。

02:24:45 - 02:24:49
爸爸跟媽媽兩個人一起謀議，我們不要小孩了。

02:24:50 - 02:24:53
我們就一起把嬰兒餓死吧，那就是不作為殺人共同正犯。

02:24:55 - 02:24:55
這個沒有疑問。

02:24:57 - 02:24:58
教唆犯可不可以是不作為？

02:25:00 - 02:25:00
超怪，對不對？

02:25:01 - 02:25:04
不作為教唆別人犯罪，這是舉例上的衝突，不可能嘛。

02:25:04 - 02:25:06
所以教唆犯不能是不作為，好。

02:25:07 - 02:25:07
來。

02:25:08 - 02:25:09
第四大點，超重要。

02:25:10 - 02:25:11
不作為幫助犯。

02:25:12 - 02:25:13
因為這個會牽涉到。

02:25:13 - 02:25:18
那不作為的幫助犯跟正犯要怎麼區分？

02:25:19 - 02:25:20
我今天要把它講完。

02:25:20 - 02:25:22
可能會稍微晚一點點下課，不會到太久了。

02:25:22 - 02:25:27
可能稍微晚個頂多10分鐘，這個東西我一次課程把它講完。

02:25:27 - 02:25:28
這個真的很重要，近年的考試。

02:25:29 - 02:25:31
尤其是三等考試，超愛考。

02:25:33 - 02:25:35
三等考試不知道考多少次了。

02:25:35 - 02:25:36
超愛考這個東西。

02:25:36 - 02:25:37
律師也考過，106年考一次。

02:25:39 - 02:25:40
107又考一次，有一陣子沒考了喔。

02:25:42 - 02:25:43
再抓出來考試有可能喔。

02:25:45 - 02:25:45
我來看這個問題。

02:26:00 - 02:26:01
所以他故意不設定保全。

02:26:02 - 02:26:03
結果晚上補習班被偷。

02:26:04 - 02:26:05
那就是什麼呢？

02:26:05 - 02:26:05
不作為幫助犯，

02:26:06 - 02:26:06
對不對？

02:26:06 - 02:26:07
這應該比較不會有疑問。

02:26:07 - 02:26:08
這應該比較不會有疑問。

02:26:08 - 02:26:09
會有疑問的是這樣。

02:26:10 - 02:26:12
有保證人地位的人，

02:26:13 - 02:26:15
不阻止別人的故意犯罪，

02:26:15 - 02:26:16
就要怎麼論罪？

02:26:17 - 02:26:19
這個是最有疑問的一種類型喔。

02:26:19 - 02:26:20
我們下面這個專題就有寫。

02:26:21 - 02:26:23
有保證人地位的人不阻止別人的故意犯罪，

02:26:23 - 02:26:25
這個應該怎麼去論罪呢？

02:26:25 - 02:26:27
有保證人地位的人不阻止別人的故意犯罪，

02:26:28 - 02:26:30
就是不作為的幫助犯跟不作為的正犯要怎麼去區分啊？

02:26:31 - 02:26:32
好。

02:26:33 - 02:26:34
我先搞清楚這個前提喔。

02:26:34 - 02:26:35
因為

02:26:36 - 02:26:37
來，這個東西很多同學見事不見理。

02:26:38 - 02:26:39
我舉另外一個例子。

02:27:25 - 02:27:26
我們講清楚啊，

02:27:26 - 02:27:27
以下我們探討的問題叫做，

02:27:27 - 02:27:32
有保證人地位的人對於別人的故意犯罪不阻止，

02:27:32 - 02:27:33
該怎麼論罪？

02:27:33 - 02:27:35
清楚是有保證人地位的人怎麼樣？

02:27:35 - 02:27:36
對別人的故意犯罪，

02:27:37 - 02:27:37
清楚喔，

02:27:37 - 02:27:40
是故意犯罪喔，對別人的故意犯罪不阻止，應該怎麼去論罪？

02:27:41 - 02:27:42
欸，顛倒過來喔。

02:27:42 - 02:27:45
那如果是有保證人地位的人不阻止別人的過失犯罪呢？

02:27:45 - 02:27:46
欸，這不是問題喔，來我舉這個例子喔。

02:27:47 - 02:27:48
護校生去醫院實習，

02:27:48 - 02:27:49
實習的時候啊，

02:27:50 - 02:27:53
護校生正要為病患注射錯誤的藥劑。

02:27:53 - 02:27:54
比如說這個病患高血壓,

02:27:55 - 02:27:56
原本要給他降血壓的藥劑,

02:27:56 - 02:27:58
結果這個護校生呢,拿錯,拿到升血壓的藥劑。

02:27:59 - 02:28:00
指導的

02:28:00 - 02:28:00
護理師就在旁邊。

02:28:01 - 02:28:05
但指導的護理師心想，那個病患很惹人厭，那麼豬哥，死死算了沒關係。

02:28:06 - 02:28:09
於是指導的護理師就假裝沒有看到他的實習生，在錯注射錯的藥劑。

02:28:12 - 02:28:13
就擺爛。

02:28:13 - 02:28:15
後來的那病患果真死掉了。

02:28:15 - 02:28:17
各位，這個案例

02:28:18 - 02:28:20
沒有什麼正犯跟幫助犯區分的問題喔。

02:28:21 - 02:28:22
沒有喔，為什麼？

02:28:23 - 02:28:27
因為這個案例當中，這一個互校的實習生你論什麼罪？

02:28:29 - 02:28:31
276過失致死，對不對？

02:28:31 - 02:28:34
那所以指導他的護理師怎麼論罪？

02:28:34 - 02:28:36
當然不可能論幫助犯啊。

02:28:36 - 02:28:38
過失犯怎麼論幫助犯？

02:28:38 - 02:28:39
不可能，對吧？

02:28:39 - 02:28:41
所以指導他的護理師，

02:28:42 - 02:28:43
我們論什麼呢？

02:28:44 - 02:28:47
故意殺人既遂的，是直接正犯。

02:28:51 - 02:28:51
知道嗎？

02:28:52 - 02:28:59
所以我們強調，如果是由保證人地位的人，不阻止別人的過失犯罪。

02:29:01 - 02:29:04
有保證人地位的人不阻止別人的過失犯罪。

02:29:04 - 02:29:06
這時候我們要論的是什麼？

02:29:08 - 02:29:09
請先正犯。

02:29:10 - 02:29:11
完全沒有疑問。

02:29:11 - 02:29:13
這種案例不可能有幫助犯的空間。

02:29:14 - 02:29:16
因為過失行為沒辦法論幫助犯，知道嗎？

02:29:16 - 02:29:17
你要搞清楚這個前提喔。

02:29:18 - 02:29:21
因為以前我在情緒班的考題故意出過這種陷阱，一堆人就掉下去。

02:29:22 - 02:29:23
就寫了一堆。

02:29:23 - 02:29:24
我說跟這個沒有關係。

02:29:25 - 02:29:26
所以我們回到重點。

02:29:27 - 02:29:33
我們這裡要談的問題叫做由保證人地位的人阻止別人的故意犯罪的時候。

02:29:34 - 02:29:37
那個有保證人地位的人應該怎麼論罪？

02:29:39 - 02:29:41
我這[redacted] 放的例子叫做人學老爸案。

02:29:42 - 02:29:43
很簡單。

02:29:43 - 02:29:45
爸爸跟兒子出去吃晚餐的時候，

02:29:46 - 02:29:48
兒子被流氓偷去暗巷打。

02:29:49 - 02:29:50
那爸爸也覺得很無奈,

02:29:50 - 02:29:52
想說兒子在外惹事生非,

02:29:52 - 02:29:53
於是爸爸產生一個念頭,

02:29:54 - 02:29:57
小孩自己不會教，那就交給社會來管教吧，就算了,

02:29:57 - 02:29:58
不要打死就好，於是呢,

02:29:58 - 02:30:00
爸爸就當著小孩的面,

02:30:02 - 02:30:04
就讓這個小孩呢被流氓抓去打,

02:30:04 - 02:30:06
小孩被打成熊貓，大概是這樣喔。

02:30:06 - 02:30:08
這個爸爸怎麼論罪？

02:30:09 - 02:30:09
你要想喔,

02:30:10 - 02:30:11
這一種案例,

02:30:12 - 02:30:15
理論上爸爸傷害罪的正犯,

02:30:15 - 02:30:16
說得過去。

02:30:16 - 02:30:17
對不對？

02:30:17 - 02:30:19
有有保證人因為不作為嘛,

02:30:19 - 02:30:21
論不作為就OK說得過去。

02:30:21 - 02:30:23
那你說要論爸爸幫助犯,

02:30:24 - 02:30:25
說得過去嗎?

02:30:25 - 02:30:26
也可以

02:30:26 - 02:30:27
為什麼？

02:30:27 - 02:30:29
因為打人的流氓就已經有一個277了嘛，

02:30:30 - 02:30:31
他爸爸可不可以從中協助？

02:30:31 - 02:30:32
可以啊，

02:30:32 - 02:30:33
對不對，也說得過去啊。

02:30:33 - 02:30:35
所以在這個問題的處理上，

02:30:35 - 02:30:38
到底，你說這個爸爸該怎麼論？

02:30:39 - 02:30:41
有保證人地位的人不阻止別人的故意犯罪，

02:30:41 - 02:30:44
到底是要論直接論這個不作為的正犯，

02:30:44 - 02:30:46
還是要論幫助犯呢？

02:30:47 - 02:30:47
這裡啊,

02:30:48 - 02:30:50
傳統上採的是這個,

02:30:50 - 02:30:51
我們先講實務見解。

02:30:52 - 02:30:55
實務見解怎麼論呢?

02:30:56 - 02:30:57
實務很簡單,

02:30:58 - 02:31:11
就看那個爸爸

02:31:11 - 02:31:22
跟那個流氓

02:31:22 - 02:31:40
有沒有犯意聯絡。

02:31:40 - 02:31:42
有的話，他們都論共同正犯。

02:31:43 - 02:31:44
沒有的話，論幫助犯。

02:31:44 - 02:31:45
是不是這麼簡單？

02:31:45 - 02:31:46
實務喔，同學一定要會。

02:31:47 - 02:31:49
有犯意聯絡，論共同正犯。

02:31:50 - 02:31:53
沒有的話，那就論幫助犯。

02:31:53 - 02:31:54
OK嗎？

02:31:54 - 02:31:55
沒有的話就論幫助犯喔。

02:31:55 - 02:31:56
好。

02:31:57 - 02:31:58
這是實務的說法。

02:31:59 - 02:32:00
學說啊,顯然不太接受這個說法。

02:32:01 - 02:32:02
他們會是認為說啊。

02:32:04 - 02:32:07
這種情況,我們要怎麼區分幫助犯,還是正犯,我們來看這五說的看法哦。

02:32:11 - 02:32:14
先講哦,這五說所講的正犯,原則上是單獨正犯。

02:32:18 - 02:32:19
不是共同正犯。

02:32:20 - 02:32:24
實務沒有想到單獨正犯的可能性，實務就是共同正犯跟幫助犯二擇一。

02:32:25 - 02:32:31
可是學者在這五說當中，所講的正犯，原則上都是單獨正犯喔，你知道為什麼嗎？

02:32:32 - 02:32:33
剛剛我舉那個人寫老爸，你想喔。

02:32:35 - 02:32:40
爸爸看到兒子被流氓拖去打，爸爸在旁邊滑手機，你覺得爸爸跟流氓會有犯意聯絡嗎？

02:32:41 - 02:32:42
通常不會,對不對?

02:32:42 - 02:32:45
所以這裡講的正犯一定是單獨正犯才有意義。

02:32:46 - 02:32:51
等於就是打人的流氓跟那個擺爛的爸爸,兩個是平行正犯,同時犯,瞭解吧?

02:32:51 - 02:32:56
所以下面的正犯不要誤會哦,不是共同正犯,都是什麼呢?單獨正犯,OK哦。

02:32:57 - 02:32:58
好,我們來看一下哦。

02:32:59 - 02:33:01
一個叫犯罪支配論，不要懷疑。

02:33:02 - 02:33:07
這個犯罪支配論，就是我們在正犯共犯區分那邊的犯罪支配論。

02:33:08 - 02:33:09
就是那個東西一模一樣。

02:33:13 - 02:33:14
犯罪支配論分三種情況。

02:33:15 - 02:33:17
我這邊標123，對沒有錯，分三種情況。

02:33:18 - 02:33:20
第一種情況是有作為也沒有用。

02:33:21 - 02:33:22
這第一種情況喔，有作為也沒有用。

02:33:24 - 02:33:26
那代表這個結果不可避免嗎？

02:33:26 - 02:33:27
所以保證人不罰，OK嗎？這第一種情況喔，有作為也沒有用。

02:33:31 - 02:33:36
第二種情況是，保證人雖然沒辦法獨自作為防止。

02:33:37 - 02:33:40
但他有機會透過公權力，透過第三方的方式，所以第二種。

02:33:40 - 02:33:42
第二種論什麼呢？

02:33:42 - 02:33:44
第二種論幫助犯。

02:33:45 - 02:33:46
好，第二種論幫助犯。

02:33:47 - 02:33:50
第三種情況是保證人他自己就可以中止。

02:33:51 - 02:33:53
自己可以中止還不中止，代表他很重要。

02:33:53 - 02:33:55
所以他是什麼呢？正犯，懂嗎？

02:33:55 - 02:33:56
分三種情況喔。

02:33:57 - 02:33:59
來，我舉個例子，我把這個人寫成老爸案啊。

02:34:00 - 02:34:03
講具體一點，讓各位知道這三種情況是什麼意思？

02:34:04 - 02:34:04
好來。

02:34:05 - 02:34:06
我們把案例講得具體一點啊。

02:34:07 - 02:34:12
如果這個爸爸是像我這樣的身材。

02:34:14 - 02:34:16
然後那個流氓是像館長那種身材。

02:34:17 - 02:34:18
就具體一點啊。

02:34:18 - 02:34:21
爸爸是像我這個身材,館長是像流氓那樣的身材。

02:34:22 - 02:34:23
然後呢?

02:34:24 - 02:34:27
這個場景是發生在荒郊野外。

02:34:28 - 02:34:31
沒有其他路人，而且爸爸有沒有帶手機。

02:34:32 - 02:34:33
那就是一種情況。

02:34:34 - 02:34:35
完全沒有辦法阻止。

02:34:36 - 02:34:36
對吧？

02:34:36 - 02:34:41
因為你想我跟館長兩個人，館長應該一拳就輕鬆把我打飛吧，應該很容易想像啊。

02:34:42 - 02:34:43
所以這個是第一種情況。

02:34:44 - 02:34:45
有所作為，也不可能會有用。

02:34:46 - 02:34:48
所以這個時候呢,保證人的行為是不罰的。

02:34:49 - 02:34:50
OK嗎?這第一種情況。

02:34:50 - 02:34:51
好。

02:34:52 - 02:34:53
那第二種情況。

02:34:54 - 02:34:54
一樣喔。

02:34:55 - 02:34:57
爸爸是像我這樣的身材的人。

02:35:00 - 02:35:02
流氓是館長那種身材的人。

02:35:03 - 02:35:06
可是毆打的地點在熱鬧的市區。

02:35:08 - 02:35:10
理論上來說，爸爸揮手跟路人呼救。

02:35:11 - 02:35:13
或者掏出手機打個110。

02:35:13 - 02:35:14
就可以制止的。

02:35:15 - 02:35:15
人很多嘛,對啊。

02:35:16 - 02:35:17
但爸爸就是假裝沒有看到。

02:35:19 - 02:35:19
這個是第二種。

02:35:20 - 02:35:24
雖然這個爸爸無力自行阻止,但有機會獲得第三人的幫助。

02:35:24 - 02:35:25
這個是幫忙犯，懂嗎？

02:35:25 - 02:35:26
這個是幫忙犯喔，好，最後。

02:35:28 - 02:35:28
好。

02:35:28 - 02:35:30
那如果顛倒過來。

02:35:32 - 02:35:34
爸爸是像館長的那種身材。

02:35:35 - 02:35:37
流氓是像我這種身材。

02:35:38 - 02:35:38
那就第三種啊。

02:35:39 - 02:35:40
爸爸自己就可以阻止了。

02:35:40 - 02:35:41
他還不阻止，他論正犯。

02:35:42 - 02:35:43
瞭解吧？這第一說，犯罪支配論。

02:35:43 - 02:35:43
好。

02:35:47 - 02:35:49
第二說叫主觀理論。

02:35:49 - 02:35:55
主觀理論看什麼呢？行為人是為了誰的利益而不作為？

02:35:55 - 02:35:58
如果行為人是為自己的利益，論正犯。

02:35:58 - 02:36:00
那如果行為人是為了

02:36:00 - 02:36:00
那個,

02:36:01 - 02:36:03
那個，作為這犯的利益,

02:36:03 - 02:36:04
讓論幫助犯。

02:36:05 - 02:36:06
所以照主觀理論來講,

02:36:06 - 02:36:07
剛剛這個例子,

02:36:09 - 02:36:09
我論什麼？

02:36:09 - 02:36:10
那個爸爸論什麼？

02:36:13 - 02:36:14
爸爸的想法是，

02:36:14 - 02:36:16
反正自己對兒子管教也是很無奈。

02:36:16 - 02:36:17
算了啦,

02:36:17 - 02:36:19
自己管不動就交給社會來管。

02:36:19 - 02:36:20
他為誰的利益？

02:36:20 - 02:36:21
自己啊,

02:36:21 - 02:36:21
對不對？

02:36:22 - 02:36:22
希望小孩好管教啊,

02:36:23 - 02:36:24
所以這個是什麼呢?

02:36:24 - 02:36:24
正犯,

02:36:24 - 02:36:25
懂嗎?

02:36:25 - 02:36:25
這個主觀理論,

02:36:26 - 02:36:28
看行為人是為了誰的利益而不作為。

02:36:30 - 02:36:33
接著第三說叫正犯理論。

02:36:34 - 02:36:35
像一跟二,

02:36:35 - 02:36:36
國內比較沒有人採,

02:36:37 - 02:36:38
那個都德國學說。

02:36:38 - 02:36:40
後面的三四五國內就都有人採了喔。

02:36:41 - 02:36:41
像三,

02:36:41 - 02:36:42
叫正犯理論。

02:36:43 - 02:36:44
正犯理論的說法,

02:36:44 - 02:36:45
像許澤天老師採這一說。

02:36:46 - 02:36:47
正犯理論是覺得說啦，

02:36:48 - 02:36:49
是說那個，

02:36:50 - 02:36:51
不作為犯的重點在義務違反。

02:36:52 - 02:36:54
所以有義務違反的人就應該論正犯。

02:36:54 - 02:36:55
換句話講，

02:36:55 - 02:36:57
他認為那個犯罪支配論之下，

02:36:57 - 02:36:58
正犯共犯的區別標準，

02:36:59 - 02:37:00
那個不是用在不作為犯。

02:37:01 - 02:37:03
所以不作為犯原則上都是正犯，

02:37:03 - 02:37:03
懂嗎？

02:37:03 - 02:37:04
原則上都是正犯。

02:37:04 - 02:37:06
這個是正犯理論的說法,

02:37:06 - 02:37:07
不作為犯原則上都正犯。

02:37:08 - 02:37:08
除非,

02:37:09 - 02:37:10
涉及到418頁,

02:37:11 - 02:37:12
三種例外。

02:37:13 - 02:37:14
你標上123。

02:37:15 - 02:37:16
純正身分犯。

02:37:17 - 02:37:18
親手犯。

02:37:18 - 02:37:19
還有意圖犯。

02:37:24 - 02:37:25
而且那個意圖犯,

02:37:26 - 02:37:28
你把最後一句話畫起來。

02:37:30 - 02:37:30
欸,

02:37:31 - 02:37:31
這個是哪一句話,

02:37:32 - 02:37:32
我看一下。

02:37:36 - 02:37:38
應該是第三行這邊,

02:37:38 - 02:37:39
欠缺意圖。

02:37:42 - 02:37:43
正犯理論有例外喔,

02:37:44 - 02:37:45
三個例外喔,

02:37:45 - 02:37:46
看清楚。

02:37:48 - 02:37:49
純正身分犯,

02:37:50 - 02:37:50
親手犯,

02:37:51 - 02:37:53
還有意圖犯而沒有意圖的情況。

02:37:54 - 02:37:56
不是說意圖犯就變例外,

02:37:56 - 02:37:58
是意圖犯要沒有意圖的情況。

02:37:58 - 02:37:59
才會變例外。

02:38:00 - 02:38:01
意圖犯而沒有意圖啊。

02:38:01 - 02:38:04
這個是這個這個這個這個叫做正犯理論。

02:38:05 - 02:38:06
三個例外。

02:38:07 - 02:38:09
所以像比如說已手犯就是個例子。

02:38:10 - 02:38:14
那有一對兄妹啊，他們都年滿16。

02:38:14 - 02:38:17
那這一對兄妹，他們就很迷戀彼此的身體。

02:38:18 - 02:38:19
兄妹經常在家打炮。

02:38:20 - 02:38:24
爸爸覺得說沒關係，因為不要懷孕就好啊，那小孩愛打就給他打啊。

02:38:25 - 02:38:27
那爸爸認血親性交了怎麼辦？

02:38:27 - 02:38:30
如果你踩正犯理論，因為爸爸違反義務嘛，他應該論正犯。

02:38:30 - 02:38:32
可是血親性交是已手犯啊。

02:38:32 - 02:38:34
所以爸爸應該改論什麼呢？

02:38:34 - 02:38:35
幫助犯，懂嗎？

02:38:35 - 02:38:36
三個例外。

02:38:40 - 02:38:40
OK。

02:38:41 - 02:38:43
我等一下再跟各位講那個例外怎麼操作。

02:38:44 - 02:38:46
接著第四說叫幫助犯理論。

02:38:46 - 02:38:47
所以說超簡單。

02:38:48 - 02:38:49
你一定要記得。

02:38:50 - 02:38:53
幫助犯理論會說這種情況沒有例外，一定會幫助犯。

02:38:54 - 02:38:54
為什麼？

02:38:55 - 02:38:56
你想像那個畫面。

02:38:56 - 02:38:59
爸爸跟兒子出門，兒子被流氓拖去打，爸爸在旁邊

02:39:00 - 02:39:01
抽菸滑手機，沒有去制止。

02:39:02 - 02:39:03
後來兒子變熊貓眼。

02:39:04 - 02:39:07
你覺得兒子變熊貓眼那件事，誰才是主角？

02:39:08 - 02:39:09
那被話打的流氓是主角嗎，對不對？

02:39:10 - 02:39:12
爸爸在旁邊擺爛。

02:39:12 - 02:39:13
你覺得擺爛的人會是主角嗎？

02:39:14 - 02:39:14
不會。

02:39:14 - 02:39:14
對，沒錯。

02:39:15 - 02:39:21
所以幫助犯理論認為擺爛不作為的人，永遠都只能論幫助犯，沒有任何的例外，知道嗎？

02:39:23 - 02:39:24
這個叫幫助犯理論。

02:39:27 - 02:39:27
好。

02:39:27 - 02:39:29
最後,叫區別理論。

02:39:30 - 02:39:30
剛剛。

02:39:30 - 02:39:33
我要同事不要擦黑板,留下這個圖是有原因的。

02:39:33 - 02:39:37
因為區別理論是要區別行為人違反哪一種義務。

02:39:38 - 02:39:40
看這個不作為的行為人呢。

02:39:40 - 02:39:43
他是違反對法益的保護義務。

02:39:43 - 02:39:47
還是違反對他人的締結義務。

02:39:48 - 02:39:50
違反保護義務的話，

02:39:50 - 02:39:52
代表行為人離那個法益近，

02:39:53 - 02:39:54
所以他該論正犯。

02:39:54 - 02:39:56
如果違反簽訂義務的話。

02:39:57 - 02:39:59
行為人離那個被害法益遠，所以要論幫助犯。

02:39:59 - 02:40:00
對。

02:40:00 - 02:40:01
懂這個思維吧？

02:40:01 - 02:40:03
違反保護義務的人，他跟法益的關係近嘛。

02:40:03 - 02:40:05
對不對，他要保護法益，

02:40:05 - 02:40:05
他沒有盡到義務嘛，

02:40:05 - 02:40:06
所以他就正犯。

02:40:06 - 02:40:09
那如果只是違反對他人行為的監督義務的話呢，

02:40:09 - 02:40:11
那他跟那個法益沒有什麼關係啊。

02:40:11 - 02:40:13
所以他只能論幫助犯。

02:40:14 - 02:40:16
OK,這個是林書楷老師的看法,

02:40:16 - 02:40:17
這個叫區分說。

02:40:18 - 02:40:19
這個區分說啊是這樣子,

02:40:20 - 02:40:22
林書楷老師書上舉的一個例子。

02:40:22 - 02:40:23
他說呢,

02:40:24 - 02:40:25
在學校裡面,

02:40:25 - 02:40:27
比如說在一個國中的校園當中,

02:40:28 - 02:40:29
發生了校園霸凌。

02:40:30 - 02:40:37
國中生甲當著班導師還有被害學童的爸爸的面,

02:40:37 - 02:40:39
毆打了國中生乙。

02:40:40 - 02:40:41
就這麼簡單的案例,

02:40:41 - 02:40:43
國中生甲當著

02:40:45 - 02:40:47
班上同學乙的爸爸的面,

02:40:48 - 02:40:50
還有當著班導師的面,

02:40:50 - 02:40:52
當眾呢,毆打了乙。

02:40:52 - 02:40:55
而班導跟爸爸都沒有制止。

02:40:56 - 02:40:57
好,

02:40:57 - 02:40:57
這時候啊,

02:40:58 - 02:40:59
班導跟爸爸怎麼論罪?

02:41:01 - 02:41:04
那個被霸凌學童的爸爸違反的是什麼義務？

02:41:05 - 02:41:07
對他小孩的保護義務，

02:41:07 - 02:41:09
對不對？所以論的是正犯，

02:41:09 - 02:41:09
瞭解嗎？

02:41:10 - 02:41:11
那班導師違反什麼義務？

02:41:12 - 02:41:16
班導師違反的是對霸凌同學的制止義務，那個叫做監督義務。

02:41:17 - 02:41:19
所以班導論的是幫助犯，

02:41:19 - 02:41:19
瞭解夠。

02:41:20 - 02:41:22
懂這個思考邏輯夠，違反保護義務論正犯，

02:41:22 - 02:41:25
違反監督義務的話，論幫助犯。

02:41:25 - 02:41:27
這個是各種不同的說法。

02:41:27 - 02:41:29
林書凱老師採這一說吼。

02:41:30 - 02:41:33
幫助犯老師，那個幫助犯理論的話是蕭宏義老師採。

02:41:33 - 02:41:36
所以這幾位老師啊，都對這個議題來表態。

02:41:37 - 02:41:40
這個東吳轉學考，我不再特別帶你們去看吼。

02:41:40 - 02:41:44
我帶你們看一個我覺得另外出的更好的題目。

02:41:45 - 02:41:46
我們來看那個,

02:41:47 - 02:41:51
那一題我放在，我應該是放在參與論那邊,

02:41:51 - 02:41:54
對，我們來看到31頁第56題。

02:41:57 - 02:41:59
我們用這一題來做代表。

02:42:00 - 02:42:01
31頁第56題。

02:42:02 - 02:42:06
105年就是九年前的警特考考這個東西。

02:42:07 - 02:42:08
我們看完這一題應該就差不多了，

02:42:08 - 02:42:11
因為同質性的題目很多，我們看一題做代表就夠了。

02:42:13 - 02:42:15
以前的警特啊，真的考得很不人道。

02:42:15 - 02:42:17
都考那種法研所考的東西。

02:42:18 - 02:42:19
不要說以前啊,其實今年也是啦,

02:42:19 - 02:42:23
今年考那個,今年警特考那個什麼溝通理論、傳播理論,

02:42:24 - 02:42:26
四等考生哪會寫,真的考這種東西哦。

02:42:26 - 02:42:27
好啦,我們看一下56題哦,

02:42:28 - 02:42:29
31頁第56題。

02:42:30 - 02:42:32
我們用這個題目來跑這六說，

02:42:32 - 02:42:34
讓同學熟悉一下這六說怎麼用。

02:42:35 - 02:42:38
這一題是我覺得這個問題考到目前為止最難的一題。

02:42:40 - 02:42:41
好，第一個來實務見解。

02:42:43 - 02:42:44
這一題採實務的話,

02:42:45 - 02:42:47
56這一題,

02:42:47 - 02:42:47
如果採實務,

02:42:49 - 02:42:50
你看喔,

02:42:50 - 02:42:52
甲想偷乙的古董花瓶,

02:42:52 - 02:42:55
擔心受到阻礙，隱瞞自己的計畫。

02:42:56 - 02:42:58
對於在乙家擔任警衛的丙說：

02:42:58 - 02:42:58
我代班，

02:42:59 - 02:42:59
讓你休息。

02:43:00 - 02:43:01
丙知道乙的計畫，

02:43:02 - 02:43:03
也對花瓶有興趣，

02:43:04 - 02:43:08
預計將來用這個事威脅甲，讓甲把古董花瓶轉給自己，

02:43:08 - 02:43:10
所以配合甲的計畫，

02:43:10 - 02:43:14
後來甲果真偷了花瓶，而且成功，

02:43:14 - 02:43:15
就這樣。

02:43:16 - 02:43:18
然後問說這個丙的刑事責任。

02:43:19 - 02:43:19
好來，

02:43:20 - 02:43:21
這一題的丙怎麼論罪？

02:43:22 - 02:43:22
對，

02:43:22 - 02:43:23
這一題丙怎麼論罪？

02:43:25 - 02:43:26
如果採實務見解,

02:43:27 - 02:43:28
實務見解看什麼呢?

02:43:28 - 02:43:30
有沒有犯意聯絡,

02:43:30 - 02:43:30
對不對?

02:43:31 - 02:43:33
所以這一題的丙跟甲有犯意聯絡嗎?

02:43:33 - 02:43:34
當然沒有啊。

02:43:34 - 02:43:36
所以照實務這一題論幫助犯，

02:43:36 - 02:43:37
OK嗎？

02:43:37 - 02:43:38
這一題論幫助犯。

02:43:52 - 02:43:54
好，那接著學說的五說，

02:43:54 - 02:43:57
我們各跑一遍喔，看這一題會得到什麼結論。

02:43:58 - 02:43:59
採一呢？

02:44:00 - 02:44:01
犯罪支配論呢？

02:44:03 - 02:44:04
犯罪支配論的重點是，

02:44:05 - 02:44:10
這個不作為的行為人，有沒有能力獨自阻止這個犯罪嘛。

02:44:11 - 02:44:13
所以你覺得丙

02:44:14 - 02:44:15
有沒有能力終止這個竊案？

02:44:16 - 02:44:18
當然有啊，他有上班的話那個小偷怎麼偷啊？

02:44:18 - 02:44:18
對不對？

02:44:19 - 02:44:21
所以如果照犯罪支配論

02:44:22 - 02:44:23
丙要論什麼？

02:44:23 - 02:44:24
正犯。

02:44:24 - 02:44:26
我再講一次，這個正犯通常是指什麼？

02:44:26 - 02:44:27
單獨正犯。

02:44:28 - 02:44:29
共同不起來啦，因為沒有犯意聯絡。

02:44:29 - 02:44:30
對嗎？

02:44:31 - 02:44:33
所以照犯罪支配論的話，

02:44:33 - 02:44:35
丙是正犯，

02:44:35 - 02:44:36
單獨正犯。

02:44:37 - 02:44:37
好，再來。

02:44:40 - 02:44:42
那如果採那個，

02:44:42 - 02:44:43
來，

02:44:44 - 02:44:46
如果採那個什麼，比如說，

02:44:46 - 02:44:47
主觀理論。

02:44:49 - 02:44:51
那是為了誰的利益不作為？

02:44:54 - 02:44:56
題目是不是說，丙對那個花瓶也有興趣？

02:44:57 - 02:44:58
很顯然是為了他自己的利益，

02:44:58 - 02:44:58
對不對？

02:44:59 - 02:45:01
所以照主觀理論的話，

02:45:41 - 02:45:43
丙論的也是正犯。

02:45:44 - 02:45:44
好吧,

02:45:44 - 02:45:45
照主觀理論呢,

02:45:45 - 02:45:46
論的也是正犯。

02:45:50 - 02:45:50
好。

02:45:51 - 02:45:53
第三個是正犯理論。

02:45:55 - 02:45:57
這一題採正犯理論要轉好幾個彎。

02:45:59 - 02:45:59
照正犯理論，

02:46:00 - 02:46:01
那幫助犯理論呢？

02:46:02 - 02:46:03
廢話，

02:46:03 - 02:46:04
不用多說嘛。

02:46:04 - 02:46:05
一定是幫助犯嘛，

02:46:05 - 02:46:05
對不對？

02:46:05 - 02:46:06
好，

02:46:06 - 02:46:09
最後，那採區別理論啊。

02:46:11 - 02:46:12
以區別理論來說，

02:46:13 - 02:46:15
你覺得那個警衛丙,

02:46:16 - 02:46:20
他違反的是對住戶財產的保護義務,

02:46:20 - 02:46:22
還是違反對他朋友,

02:46:22 - 02:46:24
這個人是他朋友嗎?

02:46:25 - 02:46:26
就是那個甲的。

02:46:26 - 02:46:29
丙是違反對住戶財產的保護義務，

02:46:30 - 02:46:33
還是違反對他人犯罪的監督義務。

02:46:35 - 02:46:37
警衛對別人的犯罪應該不會有監督義務吧。

02:46:37 - 02:46:38
警衛違反的應該是什麼呢？

02:46:39 - 02:46:40
對住戶的保護義務。

02:46:40 - 02:46:40
對不對？

02:46:41 - 02:46:43
所以這一題如果採區別理論的話，

02:46:43 - 02:46:45
論的也會是正犯。

02:46:46 - 02:46:46
瞭解吧？

02:46:46 - 02:46:47
也會是正犯。

02:46:47 - 02:46:49
所以各項操作下來大概是這樣子。

02:46:49 - 02:46:50
所以你會發現，

02:46:51 - 02:46:51
這一題啊，

02:46:53 - 02:46:54
竊取實務是幫助犯。

02:46:55 - 02:46:57
採學說的話，

02:46:58 - 02:46:59
除非你採四，

02:46:59 - 02:46:59
二幫助犯，

02:47:00 - 02:47:02
否則採其他學說，

02:47:02 - 02:47:03
丙都會是正犯，

02:47:04 - 02:47:05
單獨正犯。

02:47:05 - 02:47:06
這題主導。

02:47:06 - 02:47:08
根本法研所的難度，

02:47:08 - 02:47:09
他竟然考在警特式的，

02:47:09 - 02:47:11
所以這個是我覺得設計的還不錯的一個題目啊。

02:47:12 - 02:47:12
OK,

02:47:12 - 02:47:14
那不作為犯的話，

02:47:14 - 02:47:15
好了，

02:47:15 - 02:47:16
因為今天時間也超過了，

02:47:16 - 02:47:17
我們先上到這邊。

02:47:17 - 02:47:19
有些題目可能還有機會再講。

02:47:19 - 02:47:19
沒關係，

02:47:19 - 02:47:20
我們下次再說。

02:47:20 - 02:47:22
下次上課是禮拜一，

02:47:22 - 02:47:22
記得，

02:47:22 - 02:47:23
我們禮拜一晚上要上課喔。

02:47:23 - 02:47:24
好，

02:47:24 - 02:47:25
剩下我們下次再說。